Исламские финансы

Мухаммад Таки Усмани

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Об авторе

Муфтий Мухаммад Таки Усмани – на сегодняшний день один из ведущих исламских учёных. Эксперт в области исламской юриспруденции, экономики, хадисов и тасаввуфа.

Родился в городе Деобанд в 1362 году по хиджре (1943), получил диплом Дарс е Низами в Дар уль-Улум, г. Карачи Пакистан. После специализировался по исламской юриспруденции под руководством своего отца, выдающегося муфтия Мухаммада Шафи. С этого времени преподаёт хадисоведение и фикх в Дар уль-Улум, г. Карачи.

Является консультантом нескольких международных исламских финансовых учреждении, и сыграл ключевую роль в появлении исламских финансовых институтов. Муфтий Таки Усмани - заместитель председателя исламского совета по фикху Организации Исламская Конференция, г. Джидда.

В настоящее время является вице-президентом Дар уль-Улум, г. Карачи в Пакистане, где ведёт занятия по сборнику «Сахих Бухари», фикху и исламской экономике.

Настоящая книга является переводом книги «Islamic Finance» by Maulana Taqi Usmani

Содержание

1. Мушарака финансирование……6
1.1. Введение…….…… …...6
1.2. Концепция мушарака…….……...7
1.3. Основные правила мушарака…….……..9
1.4. Распределение прибыли……..……..9
1.5. Распределение убытков……..…….……10
1.6. Природа капитала…….…….……...11
1.7. Управление в мушараке…….…….……13
1.8. Расторжение договора мушарака…….…….……..13
2. Мудараба финансирование…….…….……15
2.1. Введение…….…….……..15
2.2. Бизнес мудараба…….…….……..16
2.3. Распределение прибылей…….……16
2.4. Расторжение договора мудараба…….……17
3. Сочетание мушарака и мудараба договоров…….……18
3.1. Введение…….……...18
3.2. Мушарака и мудараба как способ финансирования…… …….18
3.3. Финансирование проектов…… ……..19
3.4. Секьюритизация мушарака…… …….20
3.5. Финансирование одной транзакции…… ……...22
3.6. Финансирование оборотного капитала…… ……..23
3.7. Распределение только в валовой прибыли…… ……24
3.8. Управление мушарака счетом на основе ежедневного наблюдения за производством……25
3.9. Распределение прибыли на основе ежедневного наблюдения за производством подходит этому принципу……28
4. Некоторые возражения против финансирования на основе мушарака договоров……..29
4.1. Риск потерь…… ……...29
4.2. Мошенничество……30
4.3. Конфиденциальность бизнеса…….31
4.4. Не желание клиентов делиться прибылью…… ……31
5. Мушарака по шкале уменьшения……...…32
5.1. Введение……32
5.2. Финансирование жилья на основе мушарака договора по шкале уменьшения……...……34
5.3. Мушарака по шкале уменьшения в сфере услуг……...…37
5.4. Мушарака по шкале уменьшения в торговле……37
6. Мурабаха договор……...38
6.1. Введение……38
6.2. Некоторые основные правила торговой сделки……39
6.3. Баи 'муаджал (Продажа с отсрочкой платежа)……..42
6.4. Мурабаха……...43
6.5. Мурабаха как способ финансирования……..44
6.6. Основные особенности мурабаха финансирования……..44

7. Некоторые вопросы, связанные с мурабаха договорами……47
7.1. Введение……47
7.2. Современный капитализм……48
7.3. Использование ставки рефинансирования в качестве ориентира……51
7.4. Обещание приобрести товар……52
7.5. Обеспечение гарантией сделки по мурабаха договору…… ……55
7.6. Поручительство в мурабаха договорах……..……57
7.7. Компенсация за просроченный платеж……..58
7.8. Нет рефинансирования в мурабаха договорах……...63
7.9. Скидки на досрочный платеж……..63
7.10. Калькуляция себестоимости по мурабаха договору……...…..64
7.11. Предмет купли-продажи в мурабаха договорах……66
7.12. Реструктуризация платежей по мурабаха договору……..66
7.13. Секьюритизация мурабаха……...……67
7.14. Некоторые основные ошибки в мурабаха финансировании……...…67
7.15. Заключение……69
8. Иджара……..71
8.1. Введение……71
8.2. Основные правила лизинга……..72
8.3. Лизинг как способ финансирования……...…74
8.4. Предоставление в лизинг……75
8.5. Различные отношения сторон……....75
8.6. Расходы, связанные с собственностью……..76
8.7. Изменения арендных платежей в долгосрочных договорах……77
8.8. Штраф за просроченные платежи……...79
8.9. Расторжение арендного договора……...80
8.10. Страхование имущества……..80
8.11. Субаренда……..……82
8.12. Передача лизинга……..82
8.13. Секьюритизация иджара……..83
8.14. Хэд-лизинг……84
9. Салам и истисна……..84
9.1. Введение……84
9.2. Значение салам……..85
9.3. Условия салам……...…85
9.4. Салам как способ финансирования……87
9.5. Некоторые правила параллельного салам договора……..89
9.6. Истисна`……90
9.7. Разница между договорами истисна и салам……90
9.8. Разница между договорами истисна` и иджара……90
9.9. Время доставки……91
9.10. Истисна` как способ финансирования……91
10. Исламский инвестиционный фонд……..92
10.1. Введение……...……92
10.2. Акционерный фонд……...93
10.3. Условия при инвестировании в акций……95
10.4. Фондирование на основе иджара……98
10.5. Фондирование товаров……99

10.6. Фондирование мурабаха……100
10.7. Баи'-аль-даин……...……100
10.8. Смешанное фондирование……101
11. Концепция ограниченной ответственности…….....101
11.1. Введение……..101
11.2. Вакф……...…..103
11.3. Байтул-маль……104
11.4. Акционерное общество……..104
11.5. Наследство с долговыми обязательствами……...……105
Эффективность исламских банков - реалистичные оценки……...……107

1.Мушарака финансирование

1.1.Введение

'Мушарака', с арабского языка буквально означает «разделение». В контексте бизнеса и торговли означает, совместное предприятие, в котором все партнеры делят прибыль или убыток. Это идеальная альтернатива финансированию, основанному на проценте, с глубоким влиянием, как на производство, так и на распределение доходов. В современной капиталистической экономике, процент является единственным инструментом без разбора использующийся в финансировании всего. Так как ислам запрещает процент на инвестированный капитал, этот инструмент не может использоваться для предоставления средств. Таким образом, «мушарака» может играть жизненно важную роль в экономике, основанной на исламских принципах.

"Процент" предопределяет фиксированный доход по кредиту, независимо от полученной заемщиком прибыли/убытков, в то время как финансирование на основе 'мушарака' не предусматривает фиксированную ставку доходности. Скорее, прибыль по 'мушарака' договору основывается на фактической прибыли, полученной в совместном предприятии. Банк в займе, основанном на проценте, не несет убытки, в то время как в мушарака договоре банк может понести ущерб, если совместное предприятие не приносит «плодов». Ислам определяет процент как несправедливый инструмент финансирования, поскольку он приводит к несправедливости по отношению к заемщику. Если заемщик приобретает ущерб от своей деятельности, несправедливо со стороны кредитора требовать фиксированную ставку прибыли, а если заемщик получает очень высокую прибыль, несправедливо по отношению к кредитору, выплачивая ему лишь небольшую долю от прибыли, оставляя все остальное себе.

В современной экономической системе банки направляют деньги вкладчиков в виде кредитных средств для бизнеса. Если предприниматель, имея только десять миллионов тенге собственных средств, получает 90 миллионов тенге из банка и вкладывает в большой, выгодный проект, то это означает, что 90% проекта было создано на деньги вкладчиков, в то время как, только 10% создано на собственный капитал предпринимателя. Если этот проект принесет большую прибыль, лишь небольшая доля, т.е. 14 или 15% перейдет вкладчикам через банк, а все остальное принадлежит предпринимателю, у которого реальный вклад в проект не более чем 10%. Даже эта небольшая часть из 14 или 15% возвращается обратно предпринимателю путем реализации его продукции, так как расходы по выплате процентов по кредиту уже включены в себестоимость продукции. Конечным результатом является то, что вся прибыль предприятия присвоена лицами, чей собственный капитал не превышает и 10% от общего объема инвестиции, в то время как люди, владеющие 90% от инвестиций, получают не больше чем фиксированные ставки процентов, которые часто поглощаются повышением цен на продукты и товары. Напротив, если в форс-мажорной ситуации, предприниматель оказывается несостоятельным, понесенные убытки составляют не более 10%, а остальные 90% полностью приобретает банк, а в некоторых случаях и вкладчики. Таким образом, процентная ставка является основной причиной дисбаланса в

системе распределения, которая имеет постоянную тенденцию в пользу богатых и в ущерб интересам бедных слоев населения.

Наоборот, ислам имеет четко ограниченный принцип для банка. В соответствии с исламскими принципами, финансист должен определиться, чего он желает, выдавать кредиты заемщику для оказания помощи по гуманитарным соображениям или он хочет участвовать в его доходах. Если он хочет помочь заемщику, он должен отказаться от любого дохода от этого кредита, поскольку его цель заключается в оказании ему помощи. Однако если он хочет иметь долю в прибыли заемщика, необходимо, чтобы он также разделял и его убытки. Таким образом, доход от инвестиций в мушарака договоре связан с фактической прибылью бизнеса. Чем больше прибыль предприятия, тем выше доход банка. Если предприятие получает огромные прибыли, оно не может быть присвоено только предпринимателем, прибыль будет поделена между людьми, вкладчиками банка. Таким образом, мушарака договор имеет тенденцию в пользу простых людей, а не только богатых.
Это основная философия, которая объясняет, почему ислам предложил мушарака финансирование в качестве альтернативы финансированию, основанному на проценте. Без сомнения, мушарака в его полном объеме воплощает в себе целый ряд практических проблем в качестве универсального метода финансирования. Иногда предполагается, что мушарака договор, это старый инструмент, который не может идти в ногу с постоянно развивающейся необходимостью скорейшей транзакции. Однако эта презумпция может быть связана с отсутствием надлежащих знаний относительно принципов мушарака финансирования. На самом деле, в исламе не предусмотрены конкретные формы или процедуры для мушарака. Скорее, созданы некоторые общие принципы, которые могут вместить многочисленные формы и процедуры. Новые формы или процедуры в мушарака не могут быть отвергнуты лишь потому, что они не имеют прецедента в прошлом. На самом деле, каждая новая форма может быть приемлема по шариату, поскольку не нарушает основной принцип, закрепленный в священном Коране, сунне или консенсусе мусульманских правоведов. Таким образом, не обязательно, что бы мушарака договор воплощался только в своей традиционной, старой форме.

Настоящая глава содержит обсуждение основных принципов мушарака и каким образом этот вид финансирования может быть реализован в контексте современного бизнеса и торговли. Это обсуждение направлено на внедрение мушарака в качестве современного способа финансирования, в любом случае не нарушая основные принципы. Мушарака финансирование осуществляется со ссылкой на книги по исламскому праву, а также на основные проблемы, с которыми могут столкнуться при ее осуществлении в современной ситуации. Хотелось бы надеяться, что эта краткая дискуссия откроет новые горизонты мышления мусульманским правоведам и экономистам, и может поспособствовать реализации истинно исламской экономики.

1.2. Концепция мушарака

Мушарака является термином часто упоминающийся в контексте исламского способа финансирования. Коннотация этого термина является немного ограниченной, чем термин "ширках" более широко используемы в исламском

праве. Для ясности основной концепции, было бы уместно в самом начале, разъяснить значение каждого термина.

"Ширках" означает "разделения" и в терминологии исламского фикха есть два вида "ширках":

(1) Ширкат-уль-милк: Это значит, совместная собственность двух или более лиц, на ту или иную собственность. "Ширках" такого вида может осуществляться двумя различными способами: иногда вступает в действие по желанию одной из сторон. Например, если два или более лиц приобрели оборудование, оно будет в совместной собственности обоих, и отношения между ними в отношении этого имущества называется "ширкат-уль-милк". Здесь связь происходит по собственному выбору, так как они сами выбрали покупку оборудования совместно.

Но бывают случаи, когда такой вид "ширках" функционирует в автоматически без каких-либо мер, предпринятых сторонами. Например, после смерти человека, все его наследники наследуют его имущество, которое входит в их совместную собственность автоматически, как следствие смерти этого лица.

(2) Ширкат-уль-'акт: это второй тип "ширках", которое означает "партнерство осуществленное через взаимный договор". Для краткости также можно перевести как "совместное коммерческое предприятие".

Ширкат-уль-'акт далее подразделяется на три вида:

(I) Ширкат-уль-амвал, где все партнеры инвестируют часть капитала в коммерческое предприятие.

(II) Ширкат-уль-А'мал, где все партнеры совместно обязуются оказывать некоторые услуги, и плата, взимаемая с клиентов, распределяется между партнерами в соответствии с согласованными долями. Например, если два человека согласились взять на себя пошив одежды для клиентов при условии, что полученная оплата пойдет в общий пул, который будет распределен между ними независимо от размера фактически выполненной работы каждого из партнеров, это партнерство будет ширкат-уль-А'мал, который также называют "ширкат-ут-такаббул или ширкат-нас-санаи" или "ширкат-уль-абдан.

(III) Третий вид ширкат-уль-'акт является ширкат-уль-уджух. При этом партнеры не имеют инвестиций вообще. Все, что они делают то, что они покупают товары с отсроченной ценой и продают их по спот-цене. Прибыль распределяется между ними в согласованном соотношении.

Все эти модели "разделения" или партнерства, называются "ширках", в терминологии исламского фикха, а термин "мушарака" не возможно найти в книгах фикха. Термин мушарака был введен в последнее время теми, кто писал на тему исламских методов финансирования и оно обычно ограничивается определенным типом " ширках ", то есть, ширкат-уль-амвал, если два или более лиц инвестируют часть своего капитала в совместное коммерческое предприятие. Однако иногда

используется также ширкат-уль-а'мал где партнерство имеет место в бизнес-услугах.

Как видно из этой дискуссии, термин "ширках" имеет гораздо более широкое значение, чем термин "мушарака", использующийся на сегодня. Последнии ограничивается только "ширкат-уль-амвалом", в то время как первая включает в себя все виды совместной собственности и партнерства.

Поскольку "мушарака" более приемлем для нашего обсуждения, и это почти аналог "ширкат-уль-амвал", мы остановимся на нем, объяснив, в первую очередь, традиционную концепцию этого типа ширках, затем кратко опишем его применение к концепции финансирования в современном контексте.

1.3. Основные правила мушарака

Мушарака или ширкат-уль-амвал это отношения, установленные сторонами путем взаимного договора. Таким образом, само собой разумеется, что все необходимые компоненты для действительности контракта должны присутствовать и здесь. Например, стороны должны быть способны вступить в договор; договор должен осуществляться с личного согласия сторон без какого-либо принуждения, обмана или введения в заблуждения и т.д. и т.п.

Но есть определенные составляющие, которые свойственны договору "мушарака". Они кратко здесь:

1.4.Распределение прибыли

Доля в прибыли, распределяющаяся, между партнерами должна быть согласована во время заключения договора. Если доли не определены, договор является не действительным по шариату.

Соотношение прибыли для каждого из партнеров должна определяться пропорционально к фактической прибыли, приобретенной бизнесом, а не в пропорции к инвестированному капиталу партнеров. Партнерам не дозволено устанавливать фиксированную сумму, или любую ставку прибыли привязанную к инвестициям.

Поэтому, если «А» и «В» вступают в партнерство и между ними есть договоренность, что стороне «А» должно уделяться 10 000 тенге в месяц, так как это его доля в прибыли, а остальное стороне «В», партнерство является недействительным. Аналогичным образом, если есть соглашение между ними, что «А» будет получать 15% от своих инвестиций, договор является не действительным. Правильная основа для распределения, согласованный процент от фактически заработанной бизнесом прибыли.

Если в договоренности предусмотрена фиксированная сумма или определенный процент от инвестиций в отношении любого из партнеров, то в соглашении следует четко указать, что сумма подлежит окончательной корректировке в конце срока, то есть таким образом, что любая сумма, полученная одним из партнеров должна рассматриваться как "оплата в зачет" и будет скорректирована с фактической

прибыли которую он мог бы получить в конце срока. Но если нет фактически полученной прибыли, или меньше, чем ожидалось, сумму полученную партнером придется возвратить.

Необходимо ли, чтобы прибыль каждого партнера, соответствовала вложенному капиталу? Существует различия во мнениях среди мусульманских правоведов по этому вопросу.

По мнению имама Малика и имама аш-Шафи'и, необходимо для действительности мушарака, что бы каждый партнер получал прибыль именно в пропорции к своим инвестициям. Поэтому, если вложено 40% от общего объема капитала, он должен получить 40% прибыли. Любое соглашение, которое дает ему право на получение более или менее 40%, оказывает мушарака договор недействительным по шариату.

Напротив, по мнению имама Ахмада, доля прибыли может отличаться от доли в инвестициях, если оно согласовано между партнерами с их добровольного согласия. Таким образом, допустимо, чтобы партнер с 40% инвестиций, получал 60% или 70% прибыли, в то время как другие партнеры с 60% инвестиций, получали лишь 40% или 30%.

Третье мнение представлено имамом Абу Ханифа, которую можно считать золотой серединой между этими двумя мнениями, упомянутые ранее. Он постановил, что доля в прибыли может отличаться от доли в инвестициях при обычных условиях. Однако если партнер поставил непременное условие в договоре, что он не будет участвовать в работе, по договору мушарака, и останется пассивным учредителем в течение всего срока мушарака, то его доля прибыли не может быть больше, чем процент инвестиций.

1.5. Распределение убытков

Но в случае убытка, все мусульманские правоведы, единодушны в том, что каждый партнер несет потери в точности по отношению инвестициям. Поэтому, если партнер вложил 40% от капитала, то он должен приобретать 40% от убытков, не больше, не меньше, и любые условия сверх этого делают договор недействительным. Существует полный консенсус правоведов по этому вопросу.

Поэтому, по мнению имама аш-Шафи'и, процент доли партнера, как в прибылях, так и в убытках должен соответствовать проценту к его инвестициям. Но, согласно имаму Абу Ханифа и имаму Ахмаду, доля прибыли может отличаться от доли инвестиций в соответствии с соглашением партнеров, но потери должны быть разделены между ними точно в соответствии с долей капитала, вложенного каждым из них. Именно этот принцип, был упомянут в известной сентенции:

الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال

Распределение прибыли основано на согласии сторон, но убытки всегда определяются долями в инвестициях (примерный перевод)

1.6. Природа капитала

Большинство мусульманских правоведов считают, что капитальные вложения каждого из партнеров должно быть в ликвидном виде. Это означает, что договор мушарака может быть основан только на валюте, а не на товарах. Иными словами, доля капитала совместного предприятия должна быть в денежной форме. Ни одна из частей не может быть в товарах. Тем не менее, в этом отношении существуют различные мнения.

1. Имам Малик считает, что ликвидность капитала не является условием действительности мушарака, следовательно, допустимо, когда партнер вносит свой вклад в мушарака в товарах, но его доля должна быть определена на основе оценки в соответствии с рыночной ценой распространенной на дату договора. Эта точка зрения также принята некоторыми правоведами мазхаба Ханбали.

2. Имам Абу Ханифа и Имам Ахмад считают, что вклад в натуральной форме не является приемлемым в мушарака договорах. Их точка зрения основывается на двух причинах:

Во-первых, они утверждают, что товары каждого из партнеров всегда отличаются от товаров другого. Например, если «А» передает автомобиль для бизнеса, и «В» тоже вкладывает другой автомобиль, каждый из двух автомобилей является исключительной собственностью его первоначального владельца. Теперь, если автомобиль продан, то поступления от продажи должны идти к «А». «В» не имеет права претендовать на долю от продажи. Поэтому, так как имущество каждого партнера отличается от имущества другой стороны, партнерство не может реализовываться. Напротив, если капитал, вложенный каждым партнером в форме денежных средств, уставный капитал каждого из партнеров не отличается от другого, поскольку подразделения денег не отличаются, поэтому они будут рассматриваться в форме общего пула, таким образом, партнерство вступает в силу.

Во-вторых, по их мнению, существует ряд ситуаций, в договоре мушарака, где партнеры вынуждены прибегать к перераспределению долей в капитале для каждого партнера. Если акционерный капитал был в форме товаров, такое перераспределение не может произойти, так как товары могут быть проданы к этому времени. Если капитал выплачивается на основе его стоимости, сумма может увеличиться, и есть вероятность того, что партнер получит всю прибыль предприятия, из-за повышения стоимости товаров, которые он вложил, не оставляя ничего другим партнерам. И наоборот, если стоимость таких товаров снижается, партнер не может восстановить первоначально вложенный капитал.

3. Мнения имама аш-Шафи'и считается золотой серединой между двумя точками зрения, которые описаны выше. Он утверждает, что товары могут быть двух видов:

(1)Дауат-уль-амзал ذوات الامثال т.е. товары, которые в случае порчи, могут быть скомпенсированы аналогичным товаром по качеству и количеству,

например пшеница, рис и т.д. Если, испорчено 100 кг пшеницы, они легко могут быть заменены другими 100 кг. пшеницы того же качества.

(II) Дауат-уль-киимах ذوات القيمة т.е. товары, которые не могут быть компенсированы аналогичным товаром, например, крупный рогатый скот. Каждая корова, имеет свои особенности, которые не свойственны другой корове. Поэтому, например если пастух виновен в пропаже коровы принадлежащей кому-либо, он не сможет предоставить ему аналогичную корову. Скорее, он обязан оплатить ее стоимость.

Теперь, Имам аш-Шафи'и говорит о том, что товары первого рода (т.е. дауат-уль-амзал) могут быть внесены в мушарака в качестве доли партнера в капитале, в то время как товары второго рода (т.е. дауат-уль-киимах) не могут входить в состав акционерного капитала.

На этом различии, между дауат-уль-амзал и дауат-уль-киимах, имам аш-Шафи'и провел второе возражение по "партнерству товарами", вопрос так же был поднят и имамом Ахмадом. Ведь в случае дауат-уль-амзал, перераспределение капитала может осуществляться путем предоставления каждому партнеру аналогичных товаров, которые он вложил. Тем не менее, первое возражение еще остается без ответа со стороны имама аш-Шафи’и.

В целях удовлетворения этого возражения также имам Абу Ханифа говорит о том, что товары, подпадающие под категорию дауат-уль-амзал, могут входить в состав акционерного капитала только в случае, если товары каждого из партнеров были смешаны вместе, таким образом, что товар одного партнера, невозможно отличить от других.

Вкратце, если партнер желает участвовать в мушарака путем предоставления некоторых видов товаров, он может сделать это в соответствии с имамом Малик без каких-либо ограничений, и его доля в мушарака должна определяться на основе текущей рыночной стоимости товаров, распространенные на дату начала мушарака. По мнению имама аш-Шафи'и, однако, этот способ может функционировать, только если товар из категории дауат-уль-амзал.

По мнению имама Абу Ханифа, если товары дауат-уль-амзал, это может осуществиться путем смешивания товаров каждого партнера вместе. И если товары дауат-уль-киимах, то они не могут входить в состав акционерного капитала.

Кажется, что мнение имама Малика, является более простым и разумным, и отвечает потребностям современного бизнеса. Таким образом, эта точка зрения, может быть, приемлемой.

Мы можем заключить из выше изложенного, что капитал в мушарака может быть внесен как в денежной форме, так и в виде товаров. В последнем случае, рыночная стоимость товаров должна определять долю партнера в капитале.

1.7. Управление в мушараке

Обычный мушарака принцип является то, что каждый партнер имеет право принимать участие в управлении делами бизнеса и работать на предприятие. Однако партнеры могут договориться, что управление будет осуществлять только один из них, а другие партнеры не будут управлять бизнесом. Но в этом случае вкладчик имеет право на прибыль только в пределах своих инвестиций, а также доля прибыли, предоставляемая ему не должна превышать соотношения к его инвестициям, как это и обсуждалось ранее.

Однако если все партнеры согласны работать в совместном предприятии, каждый из них должен рассматриваться в качестве агента для других во всех вопросах связанных с бизнесом и любая работа одного из них в обычных делах должна быть уполномочена всеми партнерами.

1.8. Расторжение договора мушарака

Мушарака прекращает свою деятельность в любом из следующих событий:

(1) Каждый партнер имеет право расторгнуть мушарака в любое время после предоставления партнеру уведомления по этому случаю, в соответствии с которым мушарака расторгается.
В этом случае, если имущество мушарака находится в форме наличных денег, все будет распределено на пропорциональной основе между партнерами. Но если активы не ликвидные, партнеры могут договориться о ликвидации активов или об их распределении или разделе между партнерами. Если есть разногласия между партнерами в этом вопросе, т.е. один партнер ходатайствует о ликвидации, а другой хочет раздела или распределения неликвидных активов, последнее должно быть предпочтительным, поскольку после прекращения мушарака, все активы находятся в совместной собственности партнеров, а также совладелец имеет право требовать раздела активов, и никто не может заставить ликвидировать активы. Однако если активы являются такими, что они не могут быть разделены, например, машины, то они должны быть проданы, а поступления от продаж должны быть распределены.

(2) Если какой-либо один из партнеров умирает в течении периода мушарака, договор мушарака с ним приостанавливается. Его наследники в этом случае имеют возможность либо получить долю от бизнеса, или продолжать договор мушарака.

(3) Если один из партнеров становится неспособным осуществлять коммерческие сделки, мушарака приостанавливается. Завершение мушарака без закрытия бизнеса, если один из партнеров желает расторгнуть мушарака договор, а другой партнер или партнеры хотели бы продолжить бизнес, эта цель может быть достигнута по взаимному согласию. Партнеры, которые хотят работать, то дело могут приобрести долю партнера, который желает расторжения, поскольку прекращение мушарака с одним партнером не означает прекращения его действия между другими партнерами.
Однако в этом случае цена доли партнера должна быть определена на основе взаимного согласия, а если имеется спор по поводу оценки акций и партнеры не

могут выработать согласованную цену, покидающий партнер может заставить других партнеров ликвидировать активы или распределить.

Возникает вопрос о том могут ли партнеры договориться, при входе в договор мушарака, об условии, что ликвидация или разделения бизнеса не должна быть осуществлена при условии, если только все партнеры, или большинство из них не желают этого сделать, и что одному партнеру, который хочет выйти из партнерства придется продать свою долю другим партнерам не навязывая им ликвидацию или раздел активов.

Большинство традиционных книг исламского фикха, похоже, отмалчиваются по этому вопросу. Однако, как представляется, нет никаких ограничений с точки зрения шариата, если партнеры согласятся на такие условия в самом начале мушарака контракта. Это явно разрешают некоторые правоведы мазхаба Ханбали. Это условие может быть оправданным, особенно в современной ситуации, на том основании, что характер деятельности, в большинстве случаев сегодня, требует непрерывности для ее успеха, ликвидация или разделение активов по просьбе одного партнера только может нанести непоправимый ущерб другим партнерам.

Если в какой-либо бизнес вложен большой капитал, которые инвестированы в долгосрочный проект, и один из партнеров стремится к ликвидации в только «зародившемся» проекте, это может оказаться губительным для партнеров, и экономическому росту всего общества, если предоставить ему такую власть. Следовательно, такое условие представляется оправданным, и оно может быть поддержано общим принципом, закрепленным Пророком (с.а.с.) в своем знаменитом хадисе:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Все условия, согласованные мусульманами являются дозволенными, за исключением условий, которые позволяют то, что запрещено или запрещают, то, что является законным (примерный перевод)

До сих пор основная концепция ширкат-уль-амвал или мушарака в ее первоначальном виде и традиционном смысле были обобщены.
Сейчас мы находимся в состоянии обсуждать некоторые основные вопросы, связанные с его применение в современных условиях, как утвержденный вид финансирования. Но, похоже, более уместно обсуждать эти вопросы, дав вступительный отчет для мудараба, что является еще одним типом распределения прибыли и типичным способом финансирования. Поскольку правила финансирования в обоих мушарака и мудараба схожи, и вопросы, связанные с их применением взаимосвязаны, будет более полезным обсудить концепцию мудараба, прежде чем приступать к этим вопросам.

2. Мудараба

2.1. Введение

"Мудараба" представляет собой особый вид партнерства, где один из партнеров предоставляет денежные средства другому для инвестирования в коммерческое предприятие. Инвестиций поступают от первого партнера, которого называют "рабб-уль-маль", в то время как управление и работа является исключительной компетенцией другого, которого называют "мудариб".

Разницу между мушарака и мудараба можно обобщить следующим образом:

(1) инвестиции в мушарака исходят от всех партнеров, а в мудараба, за инвестиции несет ответственность рабб-уль-маль.

(2) В мушарака, все партнеры могут участвовать в управлении предприятием и могут работать на предприятие, а в мудараба, рабб-уль-маль не имеет права участвовать в управлении, которое осуществляется только мударибом.

(3) В мушарака все партнеры разделяют потери в соотношении к своим инвестициям, а в мудараба потери, если таковые имели место, направлены только к рабб-уль-маль потому что, мудариб не вкладывал ничего. Его потери ограничиваются тем, что его труд прошел напрасно, и его работа не принесла ему каких-либо плодов. Однако этот принцип при условии, что мудариб работал с должной осмотрительностью, которая обычно необходима для деятельности такого типа. Если халатность и неправильное управление мудариба доказана, то он несет ответственность за ущерб, причиненный в следствии его небрежности или преступления.

(4) ответственность партнеров в мушарака, как правило, ограничена. Таким образом, если обязательства бизнеса превышают его активы и бизнес идет в процесс ликвидации, все превышающие обязательства, распределяются пропорционально на всех партнеров. Однако если все партнеры договорились, что партнеры не несут ответственность за какие-либо задолженности в ходе деятельности, то ответственность за превышающие обязательства несет только, тот партнер, который приобрел задолженность, нарушая вышеуказанное условие. Вопреки этому является случай мудараба. Здесь если рабб-уль-маль не позволил мударибу влезать в долги от его имени, то ответственность рабб-уль-маля ограничивается его инвестициями.

(5) В мушарака, как только партнеры смешивают свои средства в общий пул, все активы мушарака становятся совместной собственностью всех в зависимости от доли к инвестициям. Таким образом, каждый из них может воспользоваться стоимостью активов, даже если прибыль от продажи не начисляется.
При мудараба иная ситуация. При этом все товары, приобретаемые мударибом исключительно, принадлежат рабб-уль-маль, и мудариб может заработать свою долю в прибыли только в случае, если он продает товары с наценкой. Поэтому он не имеет право требовать долю в активах, даже если их стоимость возросла.

2.2. Бизнес мудараба

Рабб-уль-маль может определить конкретный бизнес для мудариба, в этом случае он будет вкладывать деньги только в данный бизнес. Это называется аль-мудараба аль-мукаяддах (ограниченная мудараба). Но если он предоставил мударибу выбор, воплощать любые бизнес идеи, мударибу будет разрешено вкладывать, деньги в любой бизнес который он сочтет подходящим. Этот тип мудараба называется "аль-мудараба аль-мутлаках" (неограниченная мудараба)

Рабб-уль-маль может заключить контракт мудараба с более чем одним лицом в результате одной операции. Это означает, что он может предлагать свои деньги как стороне «А» так и стороне «В», так что каждый из них может выступать для него в качестве мудариба и капитал мудараба должен быть использован ими совместно, а доля мудариба должна распределяться между ними в соответствии с согласованной пропорцией. В данном случае оба мудариба должны управлять бизнесом, как партнеры.

Мударибам может быть позволено, проводить любые операции в ходе обычной бизнес деятельности. Однако если они желают провести что-либо экстраординарное, они не могут осуществить этого без специального разрешения от рабб-уль-маля.

2.3. Распределение прибылей

Необходимо для действительности контракта мудараба, чтобы стороны согласились, в самом начале, на определенную долю от фактической прибыли, на которую имеет право каждый из них. По шариату не предписано никакой особой ставки, а скорее, она оставлена для взаимного согласования сторонами. Они могут делить прибыль в равных пропорциях, также они могут выделить различные пропорции как рабб-уль-маль, так и мударибу. Однако не возможно выделить фиксированную сумму прибыли для одной из сторон, также нельзя определять долю в виде ставки привязанной к капиталу. Например, если капитал 100 000 тг. они не могут утвердить, что 10 000 тг. от прибыли должна быть долей мудариба, так же не возможно чтобы 20% капитала уделялось рабб-уль-малю. Однако они могут договориться о том, что 40% от фактической прибыли будет принадлежать мударибу и 60% рабб-уль-малю, или наоборот.

Допускается также в различных ситуациях согласовывать различные пропорции. Рабб-уль-маль может сказать мударибу: "Если торговля пшеницей, вы будете получать 50% прибыли, а если вы торгуете мукой, вы получите 33% от прибыли". Кроме того, он может сказать: "Если вы делаете бизнес в своем городе, вы будете иметь право на 30% от прибыли, а если вы делаете это в другом городе, ваша доля будет составлять 50% от прибыли.

Помимо согласованной доли прибыли, как это определено в описанном выше порядке, мудариб не может претендовать на периодические выплаты в виде заработной платы или вознаграждение за работу, проделанную по мудараба проекту.

Все школы исламского фикха единодушны по этому вопросу. Однако, имам Ахмад позволил мударибу списывать его ежедневные расходы на питание за счет мудараба.

Правоведы мазхаба имама Абу Ханифа ограничили это право мудариба, позволив применять это право только в ситуации, когда он находится в командировке за пределами своего родного города. В этом случае он может требовать компенсацию за его личные расходы, проживание, питание и т.д., но он не вправе получать суточные, когда он находится в своем родном городе. Если бизнес понес потери в одной операции и получил прибыль в других операциях, прибыль должна быть использована для компенсации потерь в первой инстанции, а затем часть прибыли, которая осталась должна быть распределена между сторонами в соответствии с согласованными долями.

2.4. Расторжение договора мудараба

Мудараба договор, может быть расторгнут любой стороной в любое время. Единственным условием является предоставление уведомления другой стороне. Если все активы мудараба находятся в наличной форме в момент прекращения договора, а часть прибыли была заработана на основную сумму, то она должна быть распределена между сторонами в соответствии с согласованными долями. Однако, если активы мудараба не в денежной форме, мударибу должна быть предоставлена возможность продать и ликвидировать их, так чтобы возможно было определить фактическую прибыль.

Существует различие во мнениях среди мусульманских правоведов по поводу вопроса, может ли мудараба договор просуществовать в течение определенного периода, так чтобы после этого периода автоматически аннулировать договор. ханафиты и ханбалиты считают, что мудараба или иной термин может быть ограничен, например один год, шесть месяцев, и т.д., после чего договор придет к концу без предварительного уведомления. Напротив, шафииты и правовая школа маликитов считают, что мудараба не может быть ограничен конкретным отрезком времени.

Однако это различие во мнениях относятся только к максимальным срокам по договору мудараба. Может ли минимальный срок также устанавливаться сторонами, до которого мудараба не может быть прекращен? Не утвердительный ответ на этот вопрос можно найти в книгах исламского фикха, но из общих принципов, перечисленных в нем, можно утверждать, что такой лимит не может быть установлен, и каждая сторона имеет право расторгнуть контракт по своему желанию.

Эта неограниченная власть сторон расторгнуть мудараба по своему произволу может создать определенные трудности в контексте нынешних условий, поскольку большинству коммерческим предприятиям сегодня требуется время, чтобы принести какие-либо «плоды». Они также требуют постоянные, большие усилия. Таким образом, эти действия могут привести к нежелательным последствиям для проекта, если рабб-уль-маль прекращает мудараба в самом начале бизнеса. Для мудариба это шаг назад, поскольку он не заработал ничего, несмотря на все его усилия. Поэтому, если стороны не договорятся, при заключении мудараба контракта, что ни одна сторона не должна прекращать его действие в течение указанного периода, за исключением особо оговоренных случаев, это не нарушает

принципы шариата, особенно в свете известных хадисов, уже процитированных выше, в котором говорится:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Все условия, согласованные мусульманами являются дозволенными, за исключением условий, которые позволяют то, что запрещено или запрещают, то, что является законным (примерный перевод)

3. Сочетание мушарака и мудараба

3.1. Введение

Договор мудараба обычно предполагает, что мудариб ничего не вкладывает. Он отвечает только за управление, а все инвестиции исходят от рабб-уль-маля. Но могут возникнуть ситуации, когда мудариб тоже хочет вложить часть своих денег в мудараба бизнес. В таких случаях мушарака и мудараба сочетаются вместе. Например, «А» предоставил «В» 100 000 тг. в договоре мудараба. «В» добавил 50 000 тг. из собственного кармана, с разрешения «А». Этот тип партнерства будет рассматриваться как сочетание мушарака и мудараба. Здесь мудариб может выделить для себя определенный процент прибыли за счет своих инвестиций, так как это его доля, и в то же время он может получить другой процент за его управление и работу в качестве мудариба. Основа для распределения прибыли в приведенном выше примере будет то, что «В», получает треть фактической прибыли за счет своих инвестиций, а оставшиеся две трети прибыли распределяются между ними поровну. Однако стороны могут договориться о любой другой пропорции. Единственным условием является то, что вкладчик не должен получать больше процентов, чем долю от его инвестиций.

Таким образом, в вышеуказанном примере, «А» не может выделить для себя более чем двух третей от общего объема прибыли, поскольку он не инвестировал более чем двух третей от общего капитала. Кратко о том, что они могут договориться о любой пропорции. Если бы они договорились о том, что общая прибыль распределяется поровну, то это означает, что одна треть прибыли переходит к стороне «В» в качестве прибыли от инвестиций, а одна четвертая часть оставшихся двух третей переходят к нему, как мударибу. Остальное будет уделяться стороне «А» как "рабб-уль-малю".

3.2. Мушарака и мудараба как способ финансирования

В предыдущих разделах разъяснена, традиционная концепция и основные принципы шариата, регулирующие мушарака и мудараба. Уместно теперь, обсудить, как эти инструменты могут использоваться для целей финансирования в контексте современной торговли и промышленности.

Концепция мушарака и мудараба предусмотренные в книгах исламского фикха в целом предполагает, что эти контракты предназначены для финансирования совместного предприятия, где все партнеры участвуют в бизнесе с самого его

основания и продолжают быть партнерами до конца, пока все активы не будут ликвидированы. Вряд ли можно найти в традиционных книгах исламского фикха концепцию ведения бизнеса, когда партнеры присоединяются и/или покидают предприятие без ущерба касательно непрерывности бизнеса. Очевидно, что классическая книга исламского фикха написана в среде, где крупные коммерческие предприятия не имелись, и коммерческая деятельность не была столь сложной, как сегодня. Таким образом, концепция в целом не останавливается на вопросе ведения бизнеса в таких ситуациях.

Однако это не означает, что концепция мушарака и мудараба не может быть использована для финансирования ведения бизнеса. Концепция мушарака и мудараба основана на некоторых основных принципах. Пока эти принципы полностью применимы, но детальный расклад об их применении может меняться время от времени. Давайте посмотрим на эти основные принципы, перед тем как остановиться подробно:

(1) Финансирование за счет мушарака и мудараба никогда не означало предоставление денег. Это означает участие в бизнесе, а в случае мушарака участие в активах предприятия, в соответствии с долями финансирующей стороны.

(2) инвестор / финансист должен нести потери, понесенные бизнесом по мере его финансирования.

(3) партнеры свободны в выборе, чтобы определить, с обоюдного согласия, долю прибыли, выделенных для каждого из них, которые могут отличаться от долей в инвестициях. Однако партнер, который отказался от ответственности участия в работе по бизнесу не может требовать больше, чем процент своих инвестиций.

(4) потери каждого партнера должны быть ровны долям в инвестициях. С учетом этих общих принципов, мы обсудим, то, как мушарака и мудараба применяется в различных секторах финансирования:

3.3. **Финансирование проектов**

В случае финансирования проекта, традиционные методы мушарака или мудараба можно легко принять. Если финансист желает финансировать весь проект, может вступить в действие форма мудараба. Если инвестиции исходят от обеих сторон, можно использовать форму мушарака. В этом случае, если ответственность за руководство несет одна из сторон, в то время как инвестиции исходят от обеих, сочетание мушарака и мудараба могут быть приведены в действие в соответствии с уже обсуждавшимися правилами.

Мушарака или мудараба осуществленная с самого начала проекта, не доставит каких-либо проблем в связи с оценкой капитала. Аналогичным образом, распределение прибыли, в соответствии с обычными стандартами бухгалтерского учета не должно вызывать трудности. Однако если финансист желает выйти из мушарака, в то время как другая сторона желает продолжать бизнес, последние могут приобрести долю предыдущего по согласованной цене. Таким образом,

финансирование, может вернуть сумму, которую он вложил с начисленной прибылью, если предприятие имеет прибыль. Основа для определения цены на его долю подробно описывается в дальнейшем абзаце (при обсуждении финансировании оборотного капитала).

С другой стороны, предприниматель может продолжить бизнес, своими силами или продав долю первого финансиста другому человеку, который может заменить финансиста.
Поскольку финансовые учреждения обычно не хотят оставаться партнером по конкретным проектам, они могут продать свою долю другим партнерам по проекту, как указано выше. Если продажа доли на основе единовременности не представляется возможным по причине отсутствия ликвидности в проекте, доля финансиста может быть разделена на более мелкие подразделения и каждое подразделение может быть реализовано после соответствующего интервала. После продажи подразделения, доля финансиста в проекте сводится к степени его инвестициям, а при продаже всех подразделений, финансист выходит из проекта полностью.

3.4. **Секьюритизация мушарака**

Мушарака является способом финансирования, где секьюритизация проводится легко, особенно в случае крупных проектов, где требуются огромные суммы, а ограниченное количество инвесторов не могут позволить себе вложения средств. Каждому вкладчику может быть выдан мушарака сертификат, который представляет его долевую собственность в активах мушарака, а после начала проекта за счет приобретения материальных неликвидных активов, мушарака сертификаты можно рассматривать в качестве оборотных инструментов и их можно реализовывать на вторичном рынке. Однако торговля сертификатами не допускается, когда все активы мушарака по-прежнему находятся в ликвидном виде (т. е. в виде наличности или дебиторской задолженности, или полученные авансы).

Для правильного понимания этого вопроса, следует отметить, что вложение в мушарака отличается от предоставления кредита. Облигация, выпущенная в виде свидетельства по кредиту, не имеет ничего общего с реальным бизнесом. Облигация это ссуда, которую следует выплачивать облигация держателю в любом случае, и в основном с процентом. Мушарака сертификат, напротив, представляет собой прямую пропорциональную собственность владельца на активы проекта. Если все активы в совместном проекте в ликвидной форме, сертификат будет представлять собой определенную долю денег принадлежащие проекту. Например, выпущены сто сертификатов, каждая имеющая значение в один миллион тенге. Это означает, что общая стоимость проекта 100 миллионов тенге. Если на эти деньги ничего не приобретено, каждый сертификат представляет один миллион тенге. В данном случае этот сертификат не может быть продан на рынке, за исключением по номинальной стоимости, потому что если один сертификат продается за более чем один миллион тенге, то это не дозволено по шариату, поскольку, когда деньги обмениваются на деньги, обе суммы должны быть равны. Любой излишек от одной из сторон является рибой.

Однако, когда деньги, вложены в покупку неликвидных активов, например земля, здание, оборудование, сырье, мебель и т.д. мушарака сертификаты будут представлять их владельцам долевую собственность на эти активы. Таким образом, в приведенном выше примере один сертификат будет претендовать на сотую долю в этих активах. В этом случае по шариату разрешено продавать сертификаты на вторичном рынке по любой цене, согласованной между сторонами, которая может быть больше, чем номинальная стоимость сертификата, поскольку предметом продажи является доля в материальных активах, а не только в деньгах. Поэтому сертификаты могут быть приняты, как и любые другие товары, которые могут быть проданы с прибылью или с убытком.

В большинстве случаев активы проекта смешаны в ликвидные и неликвидные активы. Это происходит, когда партнер обратил часть вложенных денег в основные фонды или сырье, а остальные деньги все еще ликвидные. Или проект, после конвертации всех денег в неликвидные активы продал некоторые из них и получил от продажи выручку в денежной форме. В некоторых случаях цена продажи, возможно, установилась благодаря клиентам, которые еще не произвели оплату за товары. Эти суммы, будучи задолженностью, также рассматриваются как ликвидные деньги. Возникает вопрос о правилах по шариату в ситуации, когда активы проекта являются смесью ликвидных и неликвидных активов, могут ли мушарака сертификаты таких проектов реализовываться на рынке? Мнения современных мусульманских правоведов отличаются по этому вопросу. Согласно традиционной правовой школе шафиитов, этот тип сертификата не может быть продан. Их классическое мнение то, что активы не продаются когда имеет место сочетание ликвидных и неликвидных активов, пока неликвидная часть бизнеса не будет отделена и продана.

Ханафиты, однако, придерживаются мнения, что, когда есть сочетания ликвидных и неликвидных активов, можно продавать, если сумма больше, суммы ликвидных активов, в таком случае деньги, полученные от продажи равны к первоначальной сумме, а излишки будут приняты на неликвидные активы, принадлежащие компании.

Предположим, что проект мушарака содержит 40% неликвидных активов т.е. машины, арматуры и т.д., и 60% ликвидных активов, т.е. денежные средства и дебиторская задолженность. Теперь каждый мушарака сертификат с номинальной стоимостью 100 тенге представляет 60 тенге от суммы ликвидных активов, и 40 тенге сумма от неликвидных активов. Этот сертификат может быть продан по любой цене более чем 60 тенге. Если он продается, по 110 тенге это будет означать, что 60 тенге от стоимости сочетается с 60 тенге составляющие сертификат, и 50 тенге причитается к пропорциональной доле неликвидных активов. Но никогда не будет позволено продавать сертификаты по цене 60 тенге или меньше, потому что в случае 60 тенге оно только покроет первоначальную сумму в 60 тенге, не говоря уже о других активах.

По мнению ханафитов в целом, нет предусмотренной, определенной доли в неликвидных активах. Поэтому, даже если неликвидные активы составляют менее 50%, торговля ею согласно вышеприведенной формуле допускается.

Однако большинство современных ученых, в том числе правовая школа шафиитов, позволили продавать часть активов только тогда, когда неликвидные активы предприятия более чем 50%. Таким образом, для действительности торговли мушарака сертификатами в рамках мнения всех школ, необходимо, чтобы портфель мушарака состоял из неликвидных активов более чем на 50% от его общей стоимости. Однако если соответствовать мнению ханафитов, торговля дозволена, даже если неликвидные активы составляют менее 50%, но размер неликвидных активов, не должен быть незначительным.

3.5. Финансирование одной транзакции

Мушарака и мудараба могут быть легко использованы для финансирования одной транзакции. Помимо удовлетворения ежедневных потребностей мелких торговцев, эти инструменты могут быть использованы для финансирования импорта и экспорта. Импортер может обратиться финансисту для финансирования его транзакции, по импорту на основе мушарака или мудараба. Банки могут также использовать эти инструменты для финансирования импорта. Если аккредитив был открыт без какого-либо запаса денег, может быть принята форма мудараба, и если аккредитив открыт с некоторым запасом, форма мушарака или комбинация обеих инструментов является подходящим. После того как импортируемые товары оформляются из порта, их доходы от продаж могут быть разделены импортером и финансистом в соответствии с предварительно согласованными долями.

В этом случае право собственности финансиста на импортируемые товары должны быть в соответствии с его инвестициями. Здесь мушарака может быть ограничена оговоренным сроком, и если импортируемые товары не проданы на рынке до истечения срока, импортер может сам приобрести долю финансист, оставляя себя единственным владельцем товаров. Тем не менее, продажа доли в этом случае должна происходить по рыночному курсу или по цене, согласованной между сторонами на дату продажи, а не по заранее согласованной цене на момент вступления в мушарака. Если цена согласована предварительно, финансист не может заставить клиента / импортера выкупить товары.

Аналогичным образом, использовать мушарака еще проще в случае финансирования экспорта. Экспортер имеет конкретный заказ из-за рубежа. Цена, по которой товар будет экспортироваться, известна заранее, и финансисту легко рассчитать ожидаемую прибыль. Он может финансировать его на основе мушарака или мудараба, и может делить сумму экспортного счета на заранее согласованном проценте. Для того чтобы обезопасить себя от небрежности со стороны экспортеров, финансист может поставить условие, что он будет нести ответственность, как экспортер, за экспорт товаров в полном соответствии с условиями аккредитива. В этом случае, если будут найдены некоторые расхождения, экспортер сам несет ответственность, а финансист пользуется иммунитетом от любых убытков в результате таких расхождений, поскольку это вызвано небрежностью экспортера. Однако, будучи партнером экспортера, финансист будет нести ответственность за любой ущерб, который может быть

причинен по какой-либо причине, кроме халатности или проступка со стороны экспортера.

3.6. Финансирование оборотного капитала

Где финансы необходимы для оборотных средств, инструмент мушарака может быть использован в следующем порядке:

Капитал в управляемом бизнесе может быть оценен с обоюдного согласия. Уже упоминалось при обсуждении традиционной концепции мушарака, что нет необходимости, в соответствии с имамом Маликом, чтобы капитал мушарака вносился в денежной форме. Неликвидные активы могут также входить в капитал на основе оценки. Эта точка зрения может быть применена и здесь. Таким образом, стоимость бизнеса можно рассматривать как инвестиции лиц, которые ищут финансирование, а сумма, выданная финансистом, может рассматриваться в качестве его доли в инвестициях. Мушарака может ограничиваться определенным периодом, один год и шесть месяцев или менее. Обе стороны согласны на определенный процент от прибыли уделять финансисту, который не должен превышать процент от инвестиций, потому что он не будет участвовать в управлении бизнесом. По истечению срока, все ликвидные и неликвидные активы предприятия переоцениваются, а прибыль может быть распределена на основе этой оценки.

Хотя, в соответствии с традиционной концепцией, прибыль не может быть определена, пока не будут ликвидированы все активы предприятия, но оценка активов может рассматриваться как "конструктивная ликвидации" по взаимному согласию сторон, потому что нет конкретного запрета в шариате. Это может также означать, что рабочий партнер приобрел долю финансиста в активах предприятия, и цена его доли была определена на основе оценки, имея в виду долю прибыли выделенные для него в соответствии с условиями мушарака.

Например, общая стоимость бизнеса стороны «А» 30 единиц. Сторона «В» финансирует еще на 20 единиц, в результате чего общая стоимость 50 единиц; 40% профинансировано стороной «В», и 60% стороной «А». Решено, что «В» должен получить 20% от фактической прибыли. В конце срока, общая стоимость бизнеса возросла до 100 единиц. Теперь, если доля «В» выкупается стороной «А», он должен выплатить ему 40 единиц, потому что он владеет 40% активов предприятия. Но для того чтобы отражать согласованное соотношение прибыли в стоимость его доли, формула цены будет другой. Любое увеличение стоимости бизнеса должна быть разделена между сторонами в соотношении 20% и 80%, так как этот показатель был определен в договоре с целью распределения прибыли.

С увеличением стоимость бизнеса составляет 50 единиц, эти 50 единиц делятся в соотношении 20-80, понимая под этим, что 10 единиц заработаны стороной «В». Эти подразделения будут добавлены к его первоначальным 20 единицам, и цена его доли составит 30 единиц.
В случае потери, однако, любое сокращение общей стоимости активов должна быть разделена между ними именно в соответствии их инвестициям, т. е. в соотношении 40/60. Поэтому, если стоимость бизнеса снизилась, в приведенном

выше примере, на 10 единиц сокращения общего числа единиц до 40, потерю в 4 единицы должен понести «В» (40% потерь). 4 единицы должны быть вычтены из его первоначальных 20 единиц, и стоимость его доли, определяется как 16 единиц.

3.7. Распределение только в валовой прибыли

Финансирование на основе мушарака в соответствии с вышеуказанной процедурой может быть затруднена в бизнесе с большим числом основных средств, в частности, в промышленности, потому что оценка всех активов, удорожание и амортизация может создать проблему учета, создав основу для споров. В таких случаях мушарака может применяться по-другому.

Основные трудности в этих случаях возникают при расчете косвенных расходов, таких как амортизация техники, зарплата сотрудников и т.д. Для того, чтобы решить эту проблему, стороны могут договориться о принципе, что, вместо чистой прибыли, стороны будут распределять валовую прибыль между собой, то есть косвенные расходы не должны вычитываться. Это означает, что все косвенные расходы покрываются промышленником, и только прямые расходы (такие как сырье, прямые трудовые расходы, электричество и т.д.) должны быть за счет мушарака. Но поскольку промышленник предлагает свое оборудование, здание и персонал в мушарака добровольно, процент его прибыли может быть увеличен, чтобы справедливо компенсировать его расходы.

Этот порядок может быть оправдан на том основании, что клиенты финансовых учреждений не ограничиваются финансированием только из одного финансового института. Их техника, персонал и т.д. могут участвовать и в других бизнес проектах, которые не являются предметом мушарака, и в таком случае полная стоимость этих расходов не может быть приписана мушарака проекту.

Возьмем практически пример. Допустим хлопкоочистительный завод имеет здание стоимостью 22 млн.тенге, установки и механизмы оценены в 2 миллиона тенге и сотрудникам выплачивается 50 000 тенге в месяц. Завод стремится привлечь финансирование на сумму 5 000 000 тенге на основе мушарака сроком на один год. Это означает, что по истечению года мушарака будет прекращена, и прибыль, начисленная на тот момент, будет распределяться между сторонами в соответствии с согласованными долями. При определении прибыли, все прямые расходы будут вычитаться из дохода. Прямые расходы могут включать в себя следующее:

1. Сумма, потраченная на покупку сырья

2. Заработная плата сотрудников непосредственно участвовавших в переработке сырья

3. Расходы по электроэнергии, потребляемой в процессе работы

4. Счета за другие услуги, непосредственно связанные с мушаракой

Что касается привлеченных в проект здания, машин и зарплаты других сотрудников, то очевидно, что они предназначены не только для бизнеса в

мушараке, потому что мушарака проект был рассчитан на год, а здания и машины приобретены для гораздо более длительного срока, где хлопкоочистительный завод будет использовать их в своих целях, которые не подпадают под мушарака. Таким образом, вся стоимость здания и оборудования, не может быть покрыта краткосрочной мушаракой. Только амортизация, начисленная зданию и механизмам в течение срока действия мушарака, входит в расходы. Однако в практическом плане, очень трудно определить стоимость амортизации, что может также вызвать споры. Таким образом, существует два практических путей решения этой проблемы.

Во-первых, стороны могут договориться о том, что мушарака портфель будет оплачивать клиенту согласованную арендную плату для использования машин и здания. Эта рента будет выплачена ему из мушарака фонда, независимо получает ли бизнес прибыль или нет.
Второй вариант заключается в том, что прибыль клиента увеличивается вместо того, чтобы оплачивать ему аренду.
С точки зрения шариата, это оправдано, по аналогии с мудараба в услугах, которое позволительно, по мнению имама Ахмада бен Ханбала رحمه الله تعالى

3.8. Управление мушарака счетом на основе ежедневного наблюдения за производством

Многие финансовые учреждения финансируют оборотный капитал предприятия путем открытия текущего счета для них, откуда клиенты получают различные суммы в разных промежутках времени, но в то же время они продолжают возвращать количество излишков. Таким образом, процесс дебета и кредита продолжается до срока погашения, а проценты начисляются на основе ежедневных наблюдений за производством.
Может ли такая договоренность реализоваться в рамках мушараки или мударабы способов финансирования? Очевидно, будучи новым явлением, прямого ответа на этот вопрос не найти в классических произведениях исламского фикха. Однако с учетом основных принципов мушарака, для этой цели могут быть предложены следующие процедуры:

(I) определенный процент от фактической прибыли должен быть выделен для менеджмента.

(II) оставшаяся часть прибыли должна быть выделена для инвесторов.

(III) потери, если таковые имеются, должны покрываться за счет инвесторов, только в точных пропорциях к их инвестициям.

(IV) средний остаток суммы взносов, внесенных на счет мушарака, рассчитывается на основе ежедневных наблюдений за производством, считается как акционерный капитал финансиста.

(V) прибыль, полученная в конце срока, подсчитывается на основе ежедневных наблюдений за производством, и должна быть распределена соответственно.

Если такая договоренность будет согласована между сторонами, то оно не нарушает основной принцип мушарака. Однако это предложение требует дальнейшего рассмотрения и исследования экспертами по исламскому праву. Практически, это означает, что стороны согласны с принципом, когда прибыль, начисленная по мушарака в конце срока, будет разделена на капитал, использованный за сутки, которая в свою очередь приведет к средней прибыли, полученной от каждого тенге за сутки. Сумма средней прибыли на 1 тенге за сутки умножается на количество дней каждого инвестора вложившего деньги в бизнес, которая определяет его право на прибыль на основе ежедневного производства.

Некоторые современные ученые не позволяют использовать этот метод расчета прибыли на том основании, что это всего лишь предположительный метод, который не отражает фактическую прибыль, действительно полученную партнером мушарака. Потому что бизнес, может, иметь огромные прибыли в течение периода, когда некоторые инвесторы не вкладывали в дело вообще, либо вкладывали очень незначительные инвестиций, но по этому методу они рассматриваются наравне с другими инвесторами, которые вкладывали огромные инвестиции в бизнес за этот период. С другой стороны, бизнес, возможно, имеет большие потери в период, когда кто-то из инвесторов вкладывал большие суммы. Тем не менее, он будет разделять свои убытки с другими инвесторами, которые не вкладывали инвестиции в этот период или их размер инвестиций был незначительным.

Этот аргумент, может быть, отвергнут на том основании, что в мушарака нет необходимости, чтобы партнер имел прибыль только от своих собственных денег. Когда мушарака пул начинает функционировать, прибыль, начисленная на совместный пул - заработана всеми участниками, независимо использовались ли его деньги или не использовались в той или иной сделке. Это особенно справедливо в отношении ханафитов, которые не считают это необходимым условием для действительности мушарака, чтобы денежные взносы партнеров обязательно смешивались. Это означает, что если сторона «А» заключила контракт на условиях мушарака со стороной «В», но до сих пор не вложил деньги в общий пул, он будет по-прежнему иметь право на долю в прибыли от операции осуществленной стороной «В» в контракте по мушарака. Хотя его правом на долю в прибыли является инвестированный капитал, но факт остается фактом, даже если средства не использовались, деньги выделенные стороной «А» на более позднем этапе может быть использованы для другой сделки. Предположим, «А» и «В» заключили мушарака договор на сумму 100 000 тг.

Они согласились, что каждый из них должен вложить 50 000 тг., и прибыль будет распределяться между ними поровну. Инвестор «А» еще не инвестировал 50 000 тг. в общий пул. Инвестор «В» провел выгодную сделку, приобрел два кондиционера в рамках договора мушарака за 50 000 тг. вложенные им самим и продал их за 60 000 тг., таким образом, полученная прибыль 10 000 тг. Инвестор «А» внес свою долю 50 000 тг. после этой сделки. Партнеры приобрели два холодильника на эти средства, которые были проданы по цене не более 48 000 тг. т.е. эта сделка привела

к ущербу в 2 000 тг. Несмотря на то, что сделка, осуществленная путем денег стороны «А» привела к потерям в 2 000 тг. в то время как выгодная сделка с кондиционерами полностью профинансирована на деньги стороны «В», в которую сторона «А» не вкладывала, инвестор «А» имеет право на долю в прибыли в первой сделке. Потери в 2 000 тг. во второй сделке компенсируются из прибыли в первой сделке тем самым, снижая совокупную прибыль до 8000 тг. Прибыль 8 000 тг. будет разделена между партнерами поровну. Это означает, что сторона «А» получит 4 000 тг., даже если сделка, осуществленная за счет его денег, привела к потерям.

Причина в том, что мушарака договор заключается между сторонами, и все последующие операции, осуществленные по мушарака, принадлежат к совместному пулу, независимо от того, кого деньги использовались в них. Каждый партнер является участником каждой сделки.

Возможные возражения на выше указанные объяснение может быть то, что в выше приведенном примере, сторона «А» взяла на себя обязательство предоставить 50 000 тг. и было известно заранее, что он будет сотрудничать в мушарака с этой суммой. Но в предлагаемом текущем счете в мушарака, где партнеры вступают, и выходят каждый день, никто не брал на себя обязательство выделить какую-либо конкретную сумму. Таким образом, капитал каждого партнера неизвестен на момент вступления в мушарака, который определяет мушарака договор недействительным.

Ответ на выше указанное возражение в том, что классические ученые исламского фикха имеют разные мнения о том, что необходимо ли для действительности мушарака, что бы капитал был предварительно известен партнерам. Ученые правовой школы Абу Ханифа единодушны в том, что оно не является предварительным условием. Аль-Касани, известный правовед ханафит, пишет:

واما العلم بمقدار راس المال وقت العقد،فليس بشرط
لجواز الشركة بالاموال عندنا.وعند الشافعي شرط...
ولنا ان الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لا فضاء
ها الى المنازعة، لانه يعلم مقداره ظاهرا وغالبا لا ن
الدراهم والدنانير توزنان وقت اشراء فيعلم مقدارها فلا
يودى الى جهالة مقدار الربح وقت القسمة

Согласно нашему мазхабу Абу Ханифа, не является условием для действительности мушарака, чтобы сумма капитала была известна, пока это утверждение соответствует мнению имама аш-Шафи’и. Наш аргумент, что джахала (неопределенность) само по себе не делает договор недействительным, пока оно не приведет к спорам. И неопределенность в капитале во время мушарака договора не

приводит к спорам, так как общеизвестно, когда товары приобретаются в рамках мушарака, поэтому оно не приведет к неопределенности в прибыли в момент распределения долей. (Badai‘-us-sanai‘ v.6 p.63)

Поэтому, из вышеизложенного ясно следует, что даже если сумма капитала не известна на момент заключения мушарака, договор остается в силе. Единственным условием является то, что она не должна приводить к неопределенности в момент распределения прибыли.

3.9. Распределение прибыли на основе ежедневного наблюдения за производством подходит этому принципу

Концепцию управления договором мушарака, где партнеры иногда забирают определенные суммы, а иногда вкладывают новые деньги и где прибыль рассчитывается на основе ежедневного наблюдения за производством, не найти в классических книгах исламского фикха. Но только этот факт не может определить новое соглашение как недействительное по шариату, поскольку оно не нарушает основной принцип мушарака. В предлагаемой системе, все партнеры обращаются по номиналу. Прибыль каждого партнера рассчитывается на основе периода, в который его деньги обращались в общем пуле. Нет сомнений в том, что совокупная прибыль, начисленная для пула, порождена от совместного использования различных сумм, которые внесены участниками в разные периоды. Поэтому, если все взаимно согласны на распространение прибыли на основе ежедневного наблюдения за производством, нет никаких предписаний по шариату, что делать этого недопустимо, скорее, оно осуществляется в рамках общего руководства от святого пророка (с.а.с.) в его знаменитом хадисе процитированном в этой книге не раз:

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا اواحل حراما

Мусульмане должны выполнять условия договора, если только эти условия не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено (примерный перевод)

2. Если распределение прибыли на основе ежедневного наблюдения за производством не принято, то для бизнеса это означает, что партнер не в состоянии получать какие-либо суммы, а также вкладывать новые суммы в совместный пул. Таким же образом, никто не в состоянии вкладывать в совместный пул, за исключением на дату нового соглашения. Эта договоренность является абсолютно невозможной в случае вкладов в банки и финансовые учреждения, в которых счета проводятся по дебиту и кредиту для вкладчиков по нескольку раз в день. Отказ от концепции ежедневного производства вынуждает инвесторов ждать в течение нескольких месяцев, прежде чем они сдадут на хранение свои деньги на прибыльный счет. Это препятствует использованию накопленных средств на развития промышленности и торговли, и будет держать руль финансовой деятельности в «заклиненном» состоянии в течение длительного времени. Не существует другого решения этой проблемы, за исключением применения метода ежедневного производства для расчета прибыли, и поскольку нет конкретного

предписания шариата против этого метода, то и нет никаких причин, отказываться.

4. Некоторые возражения против финансирования на основе мушарака

Давайте теперь рассмотрим некоторые возражения появившиеся с практической точки зрения в отношении использования мушарака как способа финансирования.

4.1. Риск потер

Утверждается, что соглашение по мушарака с большей вероятностью перекладывает убытки предприятия на банк финансисту. Эти убытки также отражаются на вкладчиках (депозиторы). Вкладчики, при этом постоянно подвергаются риску потерь, и не хотят хранить свои деньги в банках и финансовых учреждениях, таким образом, их сбережения либо бездействуют или будут использоваться в операциях за пределами банковских каналов, которые не способствуют экономическому развитию на макро уровне.

Этот аргумент, однако, неверен. До этапа финансирования на основе мушарака, банки и финансовые учреждения изучают целесообразность предлагаемого бизнеса, для которого необходимы средства. Даже в нынешней системе на основе процентного кредитования банки не предоставляют кредиты каждому заявителю. Они изучают потенциальные возможности бизнеса, и если они посчитают, что бизнес не рентабельный, они отказываются от предоставления кредита. В случае мушарака, они должны выполнить это исследование с большей глубиной и осторожностью.

Кроме того, ни один банк или финансовое учреждение не может ограничиться одним контрактом мушарака. Там всегда есть диверсифицированный мушарака портфель. Если банк профинансировал 100 своих клиентов на основе мушарака, после изучения рентабельности предложения по каждому из проектов, трудно себе представить, что все эти мушарака-договора или большинство из них приведет к убыткам. После принятия надлежащих мер и должного внимания, потери сводятся к минимуму. Но, с другой стороны, мушарака контракты, как ожидается, дают больше прибыли, чем кредиты, основанные на процентах, так как фактическая прибыль распределяется между клиентом и банком. Таким образом, в целом мушарака портфель является надежно-рентабельным, и вероятность ущерба для всего портфеля является лишь теоретической возможностью, которая не должна препятствовать вкладчикам. Эта теоретическая возможность ущерба в финансовом учреждении, гораздо меньше, чем вероятность ущерба в акционерном обществе, бизнес которого ограничен одним не диверсифицированным сектором коммерческой деятельностью. Тем не менее, люди покупают акции, а возможность потерять все не удерживает их от инвестирования в эти акции. Банки и финансовые учреждения гораздо сильнее, потому что их мушарака деятельность настолько диверсифицирована, что любые возможные потери в одном мушарака контракте более чем компенсирован ростом прибыли, полученных от других мушарака контрактов.

Помимо этого, исламская экономика должна создать ментальность, которая считает, что любая прибыль это награда за риски связанные с бизнесом. Этот риск может быть сведен к минимуму с помощью специалистов и диверсификации

портфеля, где он становится чисто гипотетическим или всего лишь теоретическим риском. Но нет никакой возможности для устранения этой угрозы полностью. Тот, кто хочет зарабатывать хорошо, должен согласиться с этим минимальным риском. Поскольку это понимание уже есть в случае обычной компании в форме акционерного общества, никто не возражает, когда деньги акционеров приносят убытки. Проблему создает система, которая отделяет банкинг и финансирование от нормальной торговой деятельности, и которая заставила людей поверить, что банки и финансовые учреждения имеют дело только с деньгами и документами, и что они не имеют ничего общего с реальным результатом, возникающим в торговле и промышленности. Поэтому утверждено, что они заслуживают фиксированного возврата средств, в любом случае. Такое отделение сектора финансирования от сектора торговли и промышленности несет большой вред экономике на макро уровне. Очевидно, когда мы говорим исламский банкинг, мы никогда не подразумеваем, что он будет следовать этой традиционной системе в каждом направлении. Ислам имеет свои собственные ценности и принципы, которые не верят, что финансирование должно быть отдельным от торговли и промышленности. После того как исламскую систему поймут, люди будут инвестировать средства в финансовый сектор, несмотря на теоретически риск убытков, с большей готовностью, чем инвестировать средства в прибыльные акционерные общества.

4.2. Мошенничество

Другое опасение в отношении финансирования по мушарака является то, что «не чистые на руку» клиенты могут воспользоваться инструментом мушарака, не возвращая финансисту ничего. Они всегда могут показывать, что предприятие не имеет прибыли. Более того, они могут утверждать, что они имеют убыток в этом случае не только прибыль, но и основная сумма ставится под угрозу. Без сомнения, это является действительно опасностью, особенно в обществах, где коррупция является обычным делом. Однако решить эту проблему не так уж и сложно, как это обычно считается или преувеличивается.

Если все банки в стране работают на чисто исламских шаблонах с тщательной поддержкой со стороны центрального банка и правительства, проблему мошенничества не трудно преодолеть. Прежде всего, должна осуществляться хорошо продуманная система проверки в соответствии, с которым счета всех клиентов, в полной мере сохранены и должным образом контролируются. Уже обсуждалось, что прибыль можно рассчитать только на основе валовой прибыли. Это уменьшит возможность возникновения споров и незаконного присвоения. Однако, если любое правонарушение, нечестность или небрежность выясняется по отношению к клиенту, он будет подвергнут карательным мерам, и может лишиться кредитования от любого банка в этой стране, по крайней мере, в течение определенного периода.

Эти меры послужат мощным сдерживающим фактором против сокрытия фактической прибыли или совершать любые другие действия непрозрачности. В противном случае также, клиенты банка не могут позволить себе показать искусственные убытки постоянно, потому что во многих случаях он будет против своих собственных интересов. Правда, что даже после принятия всех этих мер

предосторожности, останется вероятность, что некоторые случаи, когда нечестные клиенты могут преуспеть в своих злых намерениях, но карательные меры и общая атмосфера бизнеса будет постепенно сокращать число таких случаев (даже в экономике основанной на процентах, неплательщики всегда создают проблему безнадежных долгов). Но это не должно приниматься в качестве оправдания, или как предлог для отказа от всей системы мушарака финансирования.

Несомненно, опасения исходящие от мошенничества является более суровыми, для исламских банков и финансовых учреждений, работающих в изоляции от основного потока обычных банков. Они имеют не большую поддержку от правительств и центральных банков. Они не могут изменить систему, не могут навязывать собственные законы и правила. Однако они не должны забывать, что являются не только коммерческим институтом. Они были созданы, чтобы внедрить новую банковскую систему, которая имеет свою собственную философию. Они обязаны поощрять эту новую систему, даже если они столкнутся с мошенничеством, которое сократит размер прибыли в некоторой степени. Следовательно, они должны начать использовать инструмент мушарака, по крайней мере, на выборочной основе. Каждый банк имеет ряд клиентов, порядочность которых не вызывает никакого сомнения. Исламские банки должны, по крайней мере, начать их финансирование на основе истинного мушарака. Это поможет установлению хорошего прецедента на рынке, и побудит другие страны последовать этому примеру. Кроме того, есть некоторые сектора, где финансирование мушарака можно использовать легко. Например, использование мушарака инструментов для финансирования экспорта, где не много места для мошенничества. Экспортер имеет специальный заказ из-за рубежа. Цена договорная. Стоимость не трудно определить. Платежи, как правило, обеспечены аккредитивом. Платежи осуществляются через банк. В таких случаях не существует никаких оснований, для не применения мушарака механизмов. Аналогичным образом, финансирование импорта может быть также проведено на основе мушарака с некоторыми мерами предосторожности, как описано ранее в этой главе.

4.3. Конфиденциальность бизнеса

Еще одно критическое замечание в отношении мушарака является то, что, делая финансиста партнером по бизнесу клиента, он может раскрыть все аспекты бизнеса, и об этом могут узнать другие трейдеры.

Однако решение этой проблемы очень просто. Клиент при входе в мушарака контракт, может предъявить условие, что финансист не будет вмешиваться в управление делами, и он не будет разглашать какую-либо информацию о бизнесе без предварительного согласия клиента. Такие соглашения о сохранении конфиденциальной информации всегда гарантированы престижем института, особенно банки и финансовые институты, где весь бизнес основан на конфиденциальности.

4.4. Не желание клиентов делиться прибылью

Много раз, упоминалось, что клиенты не желают делиться с банками фактической прибылью своего бизнеса. Поведение клиентов таким образом, базируется на двух

причинах:

1. Они полагают, что банк не имеет права на долю в фактической прибыли, которая может быть существенным, так как банк не имеет ничего общего с менеджментом или управлением бизнеса и почему они (клиенты), должны делить плоды своего труда с банком, который только предоставляет финансовые средства. Клиенты также утверждают, что обычные банки довольствуются скудной процентной ставкой, также должны поступать и исламские банки.

2. Даже если выше сказанное не является фактором, клиенты боятся раскрывать свои истинные доходы в банках, так как информация также передается в налоговые органы и налоговое бремя клиентов увеличивается.

Решение первой причины, хотя и не легко, но и не является трудным либо невозможным. Такие клиенты должны быть убеждены и уверены с помощью доказательств присутствующие в Коране, что заимствование на основе процентов - смертный грех, при условии, что нет острой необходимости в таких заимствованиях. Просто расширение бизнеса не является острой необходимостью. Заключая законное (т.е. в рамках шариата) соглашение по получению средств для бизнеса, путем мушарака контракта, они не только получат довольство Аллаха, но и законную прибыль для себя, также как и для исламского банка.

Что касается второй причины все, что можно сказать это то, что в некоторых мусульманских странах, действительно ставки налогов являются высокими и несправедливыми. Исламские банки, как и их клиенты должны лоббировать свои интересы и бороться за изменение законов, которые препятствуют прогрессу развития исламских банков. Правительствам следует также попытаться оценить тот факт, что если ставки налогообложения являются разумными и налогоплательщики убеждены в том, что они извлекут пользу от честной оплаты налогов, это приведет к увеличению, а не уменьшению, государственных доходов.

5. Мушарака по шкале уменьшения.

5.1. Введение

Другая форма мушарака договоров, разработанные в недалеком прошлом, является «мушарака по шкале уменьшения». Согласно этой концепции, финансист и его клиент, либо участвуют в совместной собственности на имущество или оборудование, либо в совместном коммерческом предприятии. Доля финансиста в свою очередь разделена на несколько частей и под этим понимается, что клиент будет выкупать капитал финансиста периодически, по частям, тем самым, увеличивая свою долю до тех пор, пока весь капитал финансиста не перейдет к клиенту.

Мушарака по шкале уменьшения исходя из выше указанной концепции в различных сделках принимает различные формы. Некоторые примеры приведены ниже:

1. В основном используется в финансировании жилья. Клиент желает купить дом,

но он не имеет достаточно средств. Он обращается в банк, который согласен принять участие вместе с ним в приобретении необходимого жилья. 20% от стоимости вносит клиент и 80% банк. Таким образом, банк владеет 80% дома, клиент владеет 20%. После совместного приобретения имущества, клиент использует дом для решения своих жилищных проблем и платит арендную плату банку за использование клиентом доли банка в этом имуществе. В то же время доля банка далее разделена на восемь равных частей, каждая часть представляет право на владение домом в размере 10%. Клиент обещает банку, что он выкупит одну часть через три месяца. Соответственно, после первого срока в три месяца он покупает одну часть от доли банка, заплатив 1/10 от стоимости жилья. Этот взнос снижает долю, банка с 80% до 70%. Следовательно, арендная плата, выплачиваемая банку также уменьшается в пропорциональном соотношении. В конце второго срока, он выкупает другую часть, увеличивает свою доли в имуществе к 40% и сокращает долю финансиста до 60%, и соответственно арендная плата корректируется к этой пропорций. Этот процесс продолжается в течение двух лет, клиент выкупает долю банка полностью, сокращая ее до "ноля", тем самым увеличивает свою долю до 100%.
Этот механизм позволяет банку требовать арендную плату в соответствии с его долей в собственности на имущество, и в то же время позволяет ему периодически получать по частям основную сумму, продавая свою долю клиенту.

2. Сторона 'А' хочет приобрести автомобиль, чтобы использовать его для предоставления транспортных услуг в качестве такси и получать доход, но у него не хватает средств. Сторона 'В' согласна принять участие в покупке автомобиля, следовательно, оба они приобретают автомобиль совместно. 80% от стоимости оплачивается стороной 'В' и 20% вносит сторона 'А'. После приобретения автомобиля, он используется для обеспечения транспортных услуг для пассажиров, где ежедневная чистая прибыль составляет 10 000 тг. Так как сторона 'В' имеет 80%-ю долю от автомобиля, согласованно, что 80% от выручки отдается ему и остальные 20% переходят стороне 'А', который имеет 20%-ю долю. Это означает, что каждый день 8 000 тг. - заработок стороны "В" и 2 000 стороны "А". В то же время, далее доля стороны "В" делится на восемь частей. Через три месяца сторона 'А' выкупает одну часть от доли стороны ' В '. Следовательно, доля стороны ' В ' сокращена до 70%, а доля стороны 'А' увеличивается до 30% т.е. таким образом, начиная с этого времени, сторона 'А' имеет право на 3 000 тг. от ежедневного дохода, а сторона "В" на 7 000 тг. Этот процесс будет продолжаться по истечению двух лет, пока автомобиль полностью не будет принадлежать стороне "А", а сторона "В" не вернет свои первоначальные инвестиций наряду с доходами, как указано выше.

3. Сторона "А" желает начать бизнес по продаже одежды, но не хватает средств для этого бизнеса. Сторона 'В' соглашается участвовать с ним в течение определенного периода, скажем, двух лет. 40% от инвестиций предоставила сторона "А" и 60% сторона 'В'. Оба начали бизнес на основе мушарака договора. Доли в прибыли, выделяемых на каждого из них четко согласованы. Однако в то же время доля в бизнесе стороны 'В' делится на шесть равных частей и сторона 'А' приобретает эти части на постепенной основе, по окончанию двух лет, сторона "В" выходит из бизнеса, оставив его единоличным владельцем бутика по продаже одежды.

Анализ с точки зрения шариата показывает, что этот договор состоит из композиций различных сделок, которые начинают включаться на различных этапах. Таким образом, каждая из вышеупомянутых три форм мушарака договоров по шкале уменьшения обсуждаются ниже в свете исламских принципов:

5.2. Финансирование жилья на основе мушарака договора по шкале уменьшения

Предлагаемый механизм состоит из следующих операций:

1. Создание совместной собственности на имущество (ширкат-уль-милк).

2. Передача доли банка в аренду клиенту.

3. Обещание клиента на приобретение доли банка.

4. Фактически выкуп доли по частям на разных стадиях.

5. Корректировка арендной платы в соответствии с остающейся долей банка.

Позвольте мне обсудить каждый компонент более детально.

I) первый шаг в приведенном выше раскладе это создание совместной собственности на имущество. Как уже было указано в начале этой статьи, что "ширкат-уль-милк" (совместная собственность) может вступить в функционирование разными путями, в том числе совместное приобретение имущества сторонами. Это утвердительно разрешено всеми мазхабами. Поэтому нет мнения против создания совместной собственности.

II) Вторая часть этого механизма то, что банк сдает в аренду свою долю в недвижимости клиенту и получает доход в виде ренты. Этот механизм также приемлем, поскольку нет никакого разногласия среди мусульманских правоведов о правомерности передачи в лизинг неделимой доли в собственности от партнера партнеру. Если неделимая доля передается в аренду третьей стороне, о его допустимости имеются разные мнения среди мусульманских правоведов. Имам Абу Ханифа и имам Зуфар считают, что неделимая доля не может передаваться в аренду третьей стороне, в то время как имам Малик и имам аш-Шафи'и, Абу Юсуф и Мухаммад ибн Хасан считают, что неделимая доля может передаваться в аренду любому лицу. Но так как имущество сдается в аренду партнером самому себе, все они единодушны в действительности иджара договора (договор аренды).

III) Третий шаг в указанной договоренности о том, что клиент постепенно выкупает неделимую долю финансиста. Эта сделка также допускается. Если неделимая доля касается и участка земли и здания, продажа этих объектов разрешается в соответствии со всеми мазхабами. Аналогичным образом, если неделимая доля в недвижимости продана партнеру, это также единогласно разрешено всеми мусульманскими правоведами. Однако существует различие во мнениях, если доля продается третьей стороне.

Как видно из вышеизложенных трех пунктов, каждая сделка, указанная выше является законной, но вопрос в том, можно ли объединить эти пункты в едино. Ответом является то, что если все эти операции были бы объединены, делая каждую из них условием другому, то это не разрешено по шариату, потому что хорошо установленная норма в исламской правовой системе то, что одна сделка не может быть предварительным условием для другой. Тем не менее, предложенная схема предполагает, вместо того, чтобы делать две сделки условными друг другу, здесь должно быть одностороннее обещание со стороны клиента, во-первых, принять долю банка в аренду и оплачивать согласованную ренту, а во-вторых, приобретение различных частей от доли банка в недвижимости на разных стадиях. Это приводит нас к четвертому вопросу, возможность обеспечения правовой санкцией обещаний такого рода.

IV) Считается, что обещание сделать что-либо только моральное обязательство обещавшего, которое не возможно осуществить принудительно через суд. Тем не менее, существует ряд мусульманских правоведов, которые полагают, что обещание может быть принудительно осуществлено в судебном порядке, и суд может заставить обещавшего выполнить свое обещание, особенно, в контексте коммерческой деятельности. Некоторые правоведы мазхабов Малики и Абу Ханифа, в частности, заявили, что обещание может быть осуществлено через суд, если это необходимо. Правоведы-ханафиты приняли эту точку зрения в отношении специфических продаж так называемых «Баи-бильуафа». Баи-бильуафа это специальное соглашение о продаже недвижимости в соответствии, с которым покупатель обещает продавцу, позднее вернуть ему недвижимость по этой цене, т.е. он будет перепродавать ему недвижимость. Это предложение было популярным в странах центральной Азии, также правоведы-ханафиты высказали мнение, что если перепродажа недвижимости первоначальному продавцу является предусловием при первоначальной продаже, то эта сделка не допустима. Однако если первая продажа осуществляется без каких-либо условий, но после осуществления продажи, покупатель обещает продать дом, когда продавец предлагает ему ту же цену, это обещание является приемлемой и она создает не только моральное обязательство, но и исполнения права первоначального продавца. Мусульманские правоведы, позволяющие эту договоренность, основывали свое мнение на принципе",

قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس

(обещание может быть принуждено к исполнению на момент потребности)
(примерный перевод)

Даже если обещание сделано до первой продажи, после чего продажа была осуществлена без каких-либо условностей, то это также одобрено некоторым правоведами-ханафитами.

Можно возразить, если обещание по перепродаже предприняты до вступления в фактическую продажу, оно практически означает поставить условия о продаже самому себе, так как обещание согласовано и заключено между сторонами во

время продажи, и поэтому, даже если продажа без условностей, оно должно рассматриваться как условное, поскольку обещание в соглашении предшествовало ему.

Возражению можно ответить, что есть большая разница между установлением условий при продаже и принятия отдельного обещания, не делая его условием. Если условий четко указаны на момент продажи, то это означает, что продажа будет действительной, только если выполнены условия, понимая под этим, что, если условия не выполнятся в будущем, в настоящем времени продажа станет недействительной. Это делает сделку на продажу в будущем зависящей от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти. Это приводит к неопределенности (Гарар) в сделке, которая полностью запрещена по шариату.

И наоборот, если продажа без каких-либо условностей, но одна из сторон отдельно обещала сделать что-либо, то продажа не может считаться зависящей от обстоятельств или обусловленная выполнением обещания. Договор вступит в силу независимо от того, выполнит ли свои обещания обещавший. Даже если обещавший заемщик откажется от своего обещания, продажа остается в силе. Наиболее эффективный способ добиться обещания, это принудить заемщика через суд выполнить обещание и, если заемщик не в состоянии выполнить обещание, можно потребовать фактический ущерб, который был причинен по причине не выполнения обязательств.

Это ясно показывает, что отдельное и независимое обещание на приобретение не делает первоначальный договор условным. Таким образом, оно может функционировать.
На основе этого анализа, мушарака договор по шкале уменьшения может использоваться для финансирования недвижимости при следующих условиях:

а) Соглашение о совместной покупке, аренде и продаже различных частей от доли банка не должны быть вместе в одном договоре. Тем не менее, совместное приобретение и договор аренды могут быть объединены в один документ в соответствии, с которым банк соглашается сдавать в аренду свою долю клиенту, после совместной покупки. Это допускается, поскольку, как указано в соответствующей главе, иджара договор может осуществляться на более поздней дате. В то же время клиент может подписать одностороннее обещание о приобретении доли банка периодически по частям и банк может гарантировать что, когда клиент будет приобретать его долю, аренда оставшихся частей будет сокращена соответственно.

б) На момент приобретения каждой части от доли, продажа должна быть осуществлена путем обмена оферты на акцепт, на определенную дату.

с) Было бы предпочтительнее, чтобы приобретение клиентом различных частей от доли осуществлялось на основе рыночной стоимости на дату приобретения этой части, но также допустимо, когда цена согласована в обещаний выкупить недвижимость, подписанная клиентом.

5.3. Мушарака по шкале уменьшения в сфере услуг

Приведенный выше второй пример по мушарака договору по шкале уменьшения является совместное приобретение автомобиля с целью получения дохода, используя его в качестве такси. Этот механизм состоит из следующих компонентов:

I) Создание совместной собственности на такси в форме ширкат уль-милк. Как уже говорилось это разрешено по шариату.

II) Мушарака в доходе полученной от эксплуатаций такси. Это также позволено как упоминалось ранее в этой главе.

III) Выкуп различных частей от доли банка клиентом. Это опять таки условие, уже подробно изложенное в случае финансирования недвижимости. Однако есть небольшая разница между финансированием недвижимости и в соглашений описанным в этом примере. Такси, при эксплуатаций, как правило, обесценивается с течением времени, следовательно, амортизацию стоимости такси необходимо иметь в виду при определении цены различных частей от доли банка.

5.4. Мушарака по шкале уменьшения в торговле

Третий пример мушарака договора по шкале уменьшения, как указано выше, банк предоставляет 60% капитала для старта бизнеса по продаже одежды, например. Этот механизм состоит только из двух компонентов:

1) Во-первых, договор является простым, мушарака по шкале уменьшения, где два партнера инвестируют различные суммы капитала в совместное предприятие. Очевидно, это допустимо с учетом условий мушарака уже изложенные ранее в этой главе.

2) Выкуп различных частей от доли банка. Может быть, в виде отдельного и независимого обещания клиента. Требования шариата относительно этого обещания такое же, как поясняется в случае финансирования недвижимости с одной очень существенной разницей. Здесь цены на части от доли банка не могут быть фиксированными в обещаний купить, потому что если цена устанавливается заранее на момент вступления в мушарака контракт, это практически означает, что клиент гарантирует возврат основной суммы банка с прибылью или без, которая запрещена в случае мушарака. Таким образом, существуют два варианта для банка установить цену на долю, которая будет приобретена клиентом. Одним из вариантов является то, что он соглашается продавать части от доли на основе оценки стоимости предприятия на момент приобретения каждой части. Если стоимость бизнеса возросла, то цена будет выше, и если она снизилась, цена будет ниже. Такая оценка может быть проведена экспертом в соответствии с общепризнанными принципами оценки бизнеса, личность которого может быть согласована между сторонами при подписании договора по обещанию выкупить недвижимость. Второй вариант заключается в том, что банк позволяет клиенту продавать эти части любому по любой цене, но в то же время он предлагает специальную цену для клиента, то есть, если он находит покупателя, который предложит более высокую цену, он может продать ему, но если он хочет, вернуть недвижимость банку, последний будет приобретать его по заранее установленной цене.

Хотя эти опции соответствуют принципам шариата, второй вариант не представляется возможным для банка, так как это приведет к новым партнерам в мушарака, которые приведут в беспорядок все договоренности, таким образом, разрушая цели мушарака по шкале уменьшения, в котором банк хочет получить свои деньги обратно в течение определенного периода. Таким образом, для реализации цели мушарака договора, по шкале уменьшения, только первый вариант носит практический характер.

6. Мурабаха

6.1. Введение

Большинство исламских банков и финансовых учреждений используют "мурабаха", как исламскую модель финансирования, а также большая часть финансовых операций основана на "мурабаха" договорах. Поэтому этот термин сегодня принят в экономических кругах как метод банковских операций, в то время как первоначальная концепция "мурабаха" финансирования отличается от этого предположения.

"Мурабаха", по сути, является термином исламского фикха, и оно относится к

определенному виду продаж, не имеющего ничего общего с финансированием в его первоначальном смысле. Если продавец согласовал с покупателем предоставить ему определенный товар с определенной добавленной наценкой к его стоимости, это называется "мурабаха сделка". Основным компонентом "мурабаха" договора является то, что продавец раскрывает фактические расходы по приобретению товара, а затем добавляет определенную наценку. Эта наценка может быть в виде суммы или может быть основана на процентах.

Оплата в мурабаха договорах может производиться сразу или в последующие сроки. Таким образом, мурабаха не обязательно подразумевает только концепцию отсроченных платежей, как полагают некоторые люди, кто не знаком с исламским правом и те, кто слышал о мурабаха только в связи с банковскими операциями.

"Мурабаха", в своей первоначальной исламской коннотации, просто торговая сделка. Единственной особенностью, отличающей ее от других видов продаж, является то, что продавец в мурабаха договорах прямо указывает покупателю, сколько стоит товар и сколько он будет взимать в дополнение к стоимости.

Если человек продает товар, без ссылки на первоначальную стоимость товара, это не мурабаха, даже если он зарабатывает какую-нибудь прибыль, потому что продажа не основана на концепций "cost-plus". В этом случае, продажу называют "мусауамах".
Это фактический смысл термина "мурабаха", которая ясна и проста. Тем не менее, этот вид продажи в настоящее время используется исламскими банками и финансовыми учреждениями как способ финансирования, с добавлением некоторых других концепции. Но законность таких операций зависит от некоторых условий, которые должны соблюдаться, чтобы быть в рамках шариата.

Для того чтобы понять эти условия правильно, необходимо, в первую очередь, понять, что мурабаха это торговая сделка со всеми вытекающими последствиями, и что здесь также должны присутствовать все основные компоненты для законности торговой сделки. Таким образом, обсуждение этой темы начнется с некоторых основных правил продаж, без которых продажа не может быть признанна законной по шариату. Затем мы рассмотрим некоторые особые правила, в частности, регулирующие торговую сделку по мурабаха договору, и, в конце концов, будет разъяснен правильный порядок использования мурабаха договора как приемлемый способ финансирования.

6.2. Некоторые основные правила торговой сделки

"Продажа" определена шариатом, как "обмен ценного предмета на другой ценный предмет, с обоюдного согласия сторон". Исламское право постановила огромное количество правил, регулирующие договор купли-продажи, а также мусульманские правоведы, для их детальной разработки написали большое количество книг, в многочисленных томах. Что касается этой статьи, то суммируем только те правила, которые являются более актуальными для сделок в мурабаха договорах, которые проводятся финансовыми учреждениями:

1. Предмет продажи должен существовать материально на момент продажи. Таким образом, товары, которых еще нет, не могут продаваться. Если продана несуществующая вещь, даже по взаимному согласию, продажа в соответствии с шариатом, является недействительной.
Пример: Сторона «А» продает не рожденного теленка стороне «В». Продажа является недействительной.

2. Предмет продажи на момент сделки должен быть в собственности продавца. Поэтому не может продаваться то, что не является собственностью продавца. Если он продает что-то без права собственности на этот товар, продажа, является недействительной.
Пример: Сторона «А» продает автомобиль стороне «В», который в настоящее время принадлежит стороне «С», но «А» надеется, что он купит у «С» и в дальнейшем доставит его стороне «В». Продажа является недействительной, поскольку автомобиль не принадлежит стороне «А» на момент сделки.

3. Предмет продажи должен быть физически или конструктивно во владений продавца, когда он продает ее другому лицу.
"Конструктивное владение" означает ситуацию, когда владелец еще не получил товар физический, но товар в его владений, и все права и обязательства по товару переданы ему, в том числе и риск деструкций.

Примеры:
(I) «А» купил автомобиль у «В». «В» еще не доставил автомобиль к «А» или его агенту. «А» не сможет продать машину «С». Если он осуществит продажу, до доставки автомобиля, продажа, является недействительной.

(II) «А» приобрел машину от «В». После, «В» поставил автомобиль в гараж, и позволил ему забрать автомобиль в любое удобное ему время. Таким образом, автомобиль переходит к «А». Автомобиль находится в конструктивном владении «А». И если он продаст машину «С» без физического владения товаром, продажа является действительной.

Пояснение 1:
Суть правил, упомянутых в пунктах 1-3 в том, что человек может продавать товар, если:
(а) товар существует материально.
(б) является собственностью продавца.
(С) товар находится в физическом или конструктивном владении продавца.

Пояснение 2:
Существует большая разница между фактической продажей и просто обещанием продать. Фактическая продажа не может осуществиться, пока не будут выполнены три выше указанные условия. Однако кто-то может пообещать продать что-либо, чем он пока не владеет или не имеет право собственности. Это обещание на обещавшего, изначально создает только моральное обязательство выполнить свое обещание, которое, как правило, не оправдано. Тем не менее, в определенных ситуациях, особенно когда такое обещание обременено с некоторой

ответственностью, оно может быть приведено в исполнение через суд. В таких случаях суд может заставить обещавшего выполнить свое обещание, то есть для осуществления сделки, и если он не сделает этого, суд может приказать ему оплатить фактические убытки, понесенные в связи с не состоятельностью обещавшего.

Но фактическая продажа должна быть осуществлена, после того как товары будут у продавца. Это требует отдельной оферты и акцепта, и если продажа осуществляется, таким образом, правовые последствия по сделке не последуют.

Исключение:
Правила упомянутые в пунктах 1-3, находятся в не утвержденном состоянии в связи с двумя типами договоров купли-продажи, а именно:
(A) Баи 'Салам
(B) Истисна'
Правила этих двух видов договоров будут обсуждены позже в отдельной главе.

4. Продажа должна быть безотлагательной (мгновенной) и безусловной. Таким образом, продажа, перенесенная на более поздний срок или продажа, зависящая от непредвиденных обстоятельств в будущем, является недействительной. Если стороны желают осуществить сделку по продаже законно, они должны произвести продажу заново, когда будущее наступит или произойдет непредвиденное обстоятельство.

Примеры:
(а) Первого января «А» говорит «В»: "Я продам вам свою машину первого февраля". Продажа, является недействительной, так как сделка перенесена на более поздний срок.
(б) «А» говорит «В»: "Если партия «Ак жол» победит на выборах, моя машина будет продана вам". Продажа, является недействительной, поскольку зависит от будущих событий.

5. Предмет продажи должен быть собственностью имеющей цену. Таким образом, вещь, не имеющая ценности, не может быть продана или приобретена.

6. Предмет продажи не должен быть вещью, которая запрещена по шариату, свинина, вино и т.д.

7. Предмет продажи должен быть четко известен и конкретно определен для покупателя.

Пояснение:
Предмет продажи может быть определен либо прямым указанием на товар или подробными спецификациями, которые могут отличить ее от других вещей.

Пример:
Есть жилое здание, в котором много квартир одного и того же типа. «А» владелец здания говорит «В», "Я продаю вам одну из этих квартир "; «В» соглашается.

Продажа, является недействительной, пока квартира, предназначенная для продажи, ясно не указана покупателем.

8. Доставка проданного товара покупателю должна осуществиться без сомнений, и вне зависимости от непредвиденных обстоятельств или случайностей. Пример: «А» продает свою машину, украденную не известными лицами, а покупатель приобретает его в надежде, что ему удастся вернуть автомобиль. Продажа, является недействительной.

9. Определенность в цене необходимое условие для законности сделки. Если цена не определена, продажа недействительна.

Пример: «А» говорит «В»: "Если вы оплатите в течений месяца, то цена 50 тг. Но если вы оплатите через два месяца, то цена 55 тг." «В» соглашается. Так как цена не определена, продажа является недействительной, пока сторонами на момент продажи не будет согласован один из двух вариантов.

10. Продажа должна быть безусловной. Продажа с дополнительными условиями является недействительной, если условия не общепризнанны как часть сделки.

Пример:
(1) «А» покупает автомобиль у «В» с условием, что «В» примет на работу его сына. Продажа с условием, следовательно, недействительна.

Пример:
(2) «А» покупает холодильник у «В», с условием, что «В» гарантирует бесплатный сервис в течение 2 лет. Условие, общепризнано как часть сделки, является действительной, а продажа законной.

6.3. Баи 'муаджал (Продажа с отсрочкой платежа)

1. Продажа, в которой стороны договорились, что оплата за товар будет отсрочена, называется "баи 'муаджал".

2. "Баи 'муаджал" является действительным, если срок оплаты устанавливается точно.

3. Точное время оплаты может устанавливаться либо на конкретную дату, или путем указания периода, например три месяца, но дата не может устанавливаться с учетом будущих событий, точная дата которых не известна или не определена. Если срок платежа неизвестен или не определен, продажа, является недействительной.

4. Если конкретный срок для оплаты установлен: один месяц, отсчет производится с момента поставки, если стороны не договорились об ином.

5. Цена с отсрочкой платежа может быть больше, чем цена за наличный расчет, но она должна быть зафиксирована на момент продажи.

6. Как только цена утверждена, она не может быть уменьшена в случае досрочного платежа, и не может быть увеличена в случае задержки платежа.

7. Для того чтобы покупатель оперативно выполнял обязательства по кредиту, по инициативе продавца покупатель может дать обещание, что в случае невыполнения обязательств, он сделает пожертвование на какую-то определенную сумму на благотворительные цели. В этом случае продавец может получать такие суммы от покупателя, не для того чтобы сделать ее частью своего дохода, а для использования этих денег в благотворительных целях от имени покупателя. Подробное обсуждение этого вопроса позже в этой главе.

8. Если товар продан в рассрочку, продавец может выдвинуть условие покупателю, что в случае его не состоятельности оплачивать рассрочку согласно графику погашения, не оплаченная сумма, просроченные платежи становятся обязательными к уплате, незамедлительно.

9. В целях обеспечения кредита, продавец может попросить предоставить покупателя обеспечения, в форме залога на любой имеющийся в собственности актив.

10. Со стороны продавца покупателю также может быть предложено, подписать вексель (торговый или переводной), но вексель не может быть продан третьему лицу по цене отличающейся от ее номинальной стоимости.

6.4.Мурабаха

1. Мурабаха это особый вид торговой сделки, где продавец раскрывает стоимость проданного товара, и продает его другому лицу, добавляя торговую наценку.

2. Прибыль в мурабаха договоре может быть начислена на основе взаимного согласия: либо единой суммой, либо через согласованное процентное соотношение к цене.

3. Все расходы, понесенные продавцом при приобретении товаров, такие как грузовые перевозки, таможенное оформление и т.д. должны быть включены в себестоимость, а наценка может применяться на совокупные расходы. Однако текущие расходы по бизнесу, такие как заработная плата персонала, аренда помещения и т.д. не могут быть включены в стоимость отдельной операции.

4. Мурабаха является действительным только тогда, когда установлена точная стоимость товара. Если точная стоимость не установлена, товар не может быть продан на основе мурабаха договора. В этом случае товар продается на основе договора мусауамах (торг) т.е. без какой-либо ссылки на стоимость или наценке / норма прибыли. Цена товара в таких случаях определяется в единой сумме по взаимному согласию.

Пример (1) «А» купил туфли за 10 000 тг. Он хочет, продать их на основе мурабаха с 10% наценкой. Точная стоимость известна. Мурабаха сделка действительна.

Пример (2) «А» приобрел костюм с туфлями вместе за единую цену 50 000 тг. «А» может продать костюм, включая обувь на основе мурабаха. Но он не может продать туфли отдельно на основе мурабаха, потому что цена туфлей неизвестна. Если он хочет продать туфли отдельно, он должен продать их за единую стоимость без ссылки на первоначальную цену и наценку.

6.5. Мурабаха как способ финансирования

Мурабаха по происхождению это особый вид торговой сделки, а не способ финансирования. Как обсуждалось в первой главе мудараба или мушарака являются идеальным способом финансирования в соответствии с шариатом. Однако, с точки зрения текущей экономики, существуют определенные практические трудности в использовании мудараба и мушарака инструментов в некоторых областях финансирования. Таким образом, современные эксперты по шариату позволяют при соблюдении определенных правил, использовать мурабаха договор как способ финансирования с отсроченным платежом. Но есть два важных момента в этой связи, которые должны быть в полной мере прояснены:

1. Никогда не следует забывать, что изначально мурабаха не является способом финансирования. Это просто инструмент чтобы не использовать "процент" и не является идеальным инструментом для осуществления реальной экономической цели ислама. Таким образом, этот инструмент должен использоваться в качестве транзитного шага в процессе исламизации экономики, и его использование должно ограничиваться теми случаями, где мудараба или мушарака финансирование являются практически не осуществимыми.

2. Вторым важным моментом является то, что мурабаха сделка не возникнет, если просто заменить слово "процент" на слово "прибыль"/"наценка". В действительности, мурабаха как способ финансирования, одобрен учеными с некоторыми условиями. Пока эти условия не выполнены полностью, мурабаха не допустимо. В самом деле, соблюдая эти условия, можно провести четкую грань различия между кредитом основанном на проценте и сделкой на основе мурабаха. Если не учитывать эти условия, то сделка становится недействительной в соответствии с шариатом.

6.6. Основные особенности мурабаха финансирования

1. Мурабаха не кредит, выданный под проценты. Это продажа товара в рассрочку, которая включает согласованную прибыль, добавленную к стоимости товара.

2. Будучи торговой сделкой, а не кредитом, мурабаха должен соответствовать всем правилам особенно ранее перечисленные в этой главе, которые необходимы для действительности торговой сделки.

3. Мурабаха не может быть использован как способ финансирования за исключением случаев, когда клиент нуждается в средствах на покупку некоторых товаров. Например, если ему требуются средства для закупки хлопка в качестве сырья для хлопкоочистительного завода, банк может продать ему хлопка на основе мурабаха договора. Но там, где средства необходимы для других целей, мурабаха не может быть осуществлено, например, оплата за товары которые уже приобретены или счета за электроэнергию и другие коммунальные услуги или для выплаты зарплаты сотрудников, поскольку мурабаха требует реальной продажи товаров, а не только выдачу кредита.

4. Товар должен быть в собственности банка, прежде чем банк продаст товар клиенту.

5. Товар должен войти во владение банка, будь то физическое или конструктивное, в том смысле, что все риски по товару, хотя и на короткий период должны быть на ответственности банка.

6. Лучший способ для мурабаха финансирования, в соответствии с шариатом, в том, что финансист покупает товар и оставляет его у себя или покупает через третье лицо, назначенное в качестве агента, прежде чем товар будет продан клиенту. Однако в исключительных случаях, когда по некоторым причинам купить товар прямо от поставщика практически невозможно, также допустимо, что самого клиента нанимают в качестве агента, чтобы купить товар. В этом случае клиент в первую очередь покупает товар от имени банка и принимает его во владение. Затем он покупает товар у банка на основе рассроченного платежа. В первом случае он владеет товаром в качестве агента банка. В этом качестве он является лишь ответственным за приобретение и передачу товара банку, а право собственности и все риски по товару, на ответственности банка. Но когда клиент приобретает товар у банка, право собственности, а также риски по товару, передаются клиенту.

7. Как упоминалось ранее, договор купли-продажи не может произойти, пока товар не перешел в собственность продавца, но продавец может пообещать продать товар кому-либо, даже если товар не находится в его владении. Это правило то же применимо к мурабаха финансированию.

8. В свете указанных выше принципов, финансовое учреждение может использовать договор купли-продажи мурабаха как способ финансирования, приняв следующий порядок:

Во-первых: клиент и банк подписывают полное соглашение, согласно которому банк обещает продать клиенту товары и клиент обещает выкупать эти товары на основе рассроченного платежа с согласованной наценкой к стоимости. Данное соглашение может предусматривать лимит, до которого объект может быть выкуплен.

Во-вторых: когда покупателю требуется специфический товар, банк назначает

клиента в качестве своего агента для приобретения товара от своего имени, а также соглашение о посредничестве, подписывается обеими сторонами.

В-третьих: клиент, покупая от имени банка, принимает товар в распоряжение в качестве агента этого банка.

В-четвертых: клиент информирует банк, что он купил товар от его имени, и в то же время, делает предложение по приобретению товара у банка (обмен оферты и акцепта).

В-пятых: банк принимает предложение и в соответствии с заключенным договором купли-продажи право собственности, а также риски связанные с товаром передаются клиенту (обмен оферты и акцепта).
Все эти пять этапов, необходимы для осуществления действительности мурабаха договора. Если банк покупает товар непосредственно у поставщика (что предпочтительнее), то нет необходимости в агентском соглашений. В этом случае, второй этап отпадает, а на третьем этапе банк покупает товар у поставщика, и на четвертом этапе ограничивается предложением на приобретение со стороны клиента. ***Наиболее важным элементом сделки является то, что товар должен оставаться в распоряжении банка в период между третьим и пятым этапом.*** Это единственная отличительная черта мурабаха договора, от транзакций основанной на проценте. Следовательно, следует соблюдать все правила с должной осмотрительностью, в противном случае мурабаха сделка недействительна в соответствии с шариатом.

9. Также необходимое условие для действительности мурабаха договора, чтобы товар приобретался от третьей стороны. Покупка товара от самого клиента на основе соглашения об обратном выкупе не допускается в шариате. Так как мурабаха, на основе соглашения об обратном выкупе не более чем сделка основанная на процентах.

10. Вышеуказанные процедуры мурабаха финансирования это комплексные транзакций, где стороны вовлечены имея разные возможности на различных этапах.

(A) на первом этапе, обещание банка и клиента о продаже и покупке товара в будущем. Это не является фактической продажей. Это всего лишь обещание осуществить продажу в будущем на основе мурабаха финансирования.

(B) на втором этапе, отношения между сторонами складываются как между принципалом и агентом.

(C) на третьем этапе, отношения между банком и поставщиком складываются как между покупателем и продавцом.

(D) на четвертом и пятом этапе, отношения покупателя и продавца вступают в действие как между банком и клиентом, и, поскольку продажа осуществляется на

основе рассроченного платежа, одновременно между ними возникает также отношения в качестве заемщика и кредитора.
Все эти процедуры следует соблюдать и осуществлять каждое правило на соответствующем этапе, со всеми косвенными последствиями, и эти различные процедуры никогда не должны быть перепутанными или смешанными друг с другом.

11. Банк может требовать от клиента предоставить залог для гарантий периодических платежей. Также может требовать подписать вексель, но это должно происходить после фактической продажи, т.е. на пятом этапе. Причина в том, что вексель является подписанным документом заемщика в пользу его кредитора, но отношения в качестве заемщика и кредитора между банком и клиентом начинается только на пятом этапе, после того как между ними произойдет фактическая продажа.

12. В случае не своевременного выполнения обязательств со стороны покупателя, цена на товар не может быть увеличена. Однако если он в договоре взял обязательство, что в случае не своевременной оплаты по платежам он согласен выплатить сумму на благотворительные цели в качестве штрафа, как указано в пункте 7 правил баи муаджал, он обязан заплатить сумму в качестве пени за просрочку. Однако это часть денег покупателя не должны стать частью дохода продавца/банка. Финансист обязан потратить их на благотворительные цели от имени покупателя, как это будет разъяснено позже в деталях.

7. Некоторые вопросы, связанные с договором мурабаха

7.1. Введение

Основная концепция мурабаха финансирования уже разъяснена. Теперь предлагается обсудить ряд актуальных вопросов с учетом основных принципов ислама и их практической применимости в мурабаха сделках, потому что без правильного понимания этих вопросов, концепция может оставаться неоднозначной и ее практическое применение может быть подвержена ошибкам и неправильному пониманию.

Различие в цене между наличным расчетом и продажей в кредит. Главным вопросом касательно мурабаха финансирования является то, что при использовании его в качестве механизма финансирования, оно всегда осуществляется на основе рассроченного платежа. Банк покупает товар за наличный расчет и продает клиенту в кредит. При реализации товаров в кредит, во внимание принимается период, в котором стоимость товара должна быть оплачена клиентом, и цена товара повышается соответственно этому периоду. Чем дольше срок погашения платежей по мурабаха договору, тем выше цена. Поэтому цена в мурабаха сделках, как это практикуется исламскими банками, всегда выше, чем рыночная цена. Если клиент имеет возможность приобрести тот же товар на рынке за наличный расчет, он платит гораздо меньше, чем в мурабаха сделке по рассроченному платежу. Возникает вопрос, допустимо ли увеличение цены товара при продаже в кредит по сравнению с продажей за наличный расчет. Некоторые утверждают, что увеличение цены при продаже в кредит, будучи вознаграждением,

за время, предоставленное покупателю, должно рассматриваться аналогично с начисленными процентами по кредиту, поскольку в обоих случаях дополнительные суммы взимаются за отсрочку в оплате. На этом основании они утверждают, что мурабаха сделки, которые практикуют исламские банки, не отличаются, по сути, от кредитов основанных на проценте выдаваемые обычными банками.

Этот аргумент, логичный на первый взгляд, основан на не правильном пониманий принципов шариата, касательно запрещения рибы. Для правильного понимания концепции следует иметь в виду следующее:

7.2. Современный капитализм

Современная капиталистическая теория не проводит различия между деньгами и товаром по этой же теорий проводятся коммерческие сделки. В случае обмена денег и товаров, оба обмениваются по номиналу. Оба могут продаваться. И товары и деньги могут продаваться за любую согласованную цену. Можно продать доллар за два доллара сразу на месте или в кредит, так же, можно продать товар стоимостью в один доллар за два доллара. Единственное условие, сделка должна быть по обоюдному согласию.

Однако, исламские принципы, не согласны с этой теорией. В соответствии с исламскими принципами, деньги и товары имеют разные характеристики, и поэтому они рассматриваются по-разному. Основные отличия между деньгами и товаром следующие:

(а) Деньги не имеют действительной полезности. Они не могут использоваться для выполнения потребностей человека напрямую. Деньги могут использоваться только для приобретения товаров или услуг. Товары, в отличие от денег, имеют действительную полезность. Они могут использоваться непосредственно, без обмена их на другие вещи.

(б) Товары могут быть разного качества, а деньги не имеют качества за исключением того, что являются мерой стоимости, или средством обмена. Таким образом, все единицы денег, того же номинала, 100% равны друг другу. Старая и грязная банкнота в 1 000 тг. имеет такую же ценность, что и новая банкнота, в отличие от товаров, которые по качеству могут быть разными, и, очевидно, старый и подержанный автомобилей, может быть гораздо меньше по стоимости, чем новый автомобиль.

(с) В товарах; сделки по купли-продажи осуществляются на конкретно известный товар, или, по крайней мере, на товары с точно указанными спецификациям. Если «А» приобрел конкретно выбранный автомобиль, указав ее, и продавец согласился, «А» заслуживает того, чтобы получить именно этот автомобиль. Продавец не может заставить его принять поставку другого автомобиля, хотя того же типа или качества. Продавец может продать другой автомобиль покупателю, только если покупатель согласен, т.е. первая сделка отменяется, и новая сделка по новому автомобилю осуществляется по взаимному согласию.

Деньги, напротив, не могут быть указаны при обмене. Если «А» приобрел товар у «В», продемонстрировав ему банкноту в 1 000 тг. он все еще может оплатить товар другой банкнотой того же номинала, и «В» не может утверждать, что он примет только первую банкноту, которая была ему показана.

С учетом этих различий ислам рассматривает деньги и товары по-разному. Поскольку деньги не имеют действительной полезности, а являются лишь средством обмена, которые не различаются по качеству, обмен денежной единицы на другую единицу одного достоинства может быть осуществлен только по номинальной стоимости. Если банкнота в 1 000 тг. обменивается на другую банкноту казахстанских тенге, банкнота должна иметь значение в 1 000 тг. Не больше не меньше 1 000 тг., потому что банкнота не имеет ни действительной полезности, ни особого качества (юридически признанного), поэтому любое увеличение или уменьшение в пользу одной из сторон не допускается по шариату.
В случае обычных товаров ситуация иначе. Так как они имеют действительную полезность и разнообразное качество, собственник вправе продать их по любой желаемой цене, все зависит от спроса и предложения. Если продавец не использует мошенничество или введение в заблуждение, с согласия покупателя он может продать товар выше рыночной цены. Если покупатель согласен купить товар по завышенной цене, излишек, начисленный, на товар вполне допустим для продавца. Если продавец может продать свой товар по более высокой цене за наличный расчет, он также может взимать более высокую цену, продавая в кредит, лишь при условии, что он не обманывает покупателя, не вынуждает его к покупке, и покупатель согласен выкупать по такой цене по собственному желанию.
Иногда утверждают, так как увеличение цены в операциях за наличный расчет не является рассроченным платежом, допустимо продавать за эту цену, а в продаже на основе рассроченных платежей, увеличение в цене является компенсацией за рассроченный платеж, т.е. аналогично к процентному финансированию. Этот аргумент также основан на ошибочном мнений. Это предположение не верно. Любая избыточная сумма, начисленная за несвоевременную выплату – риба, только тогда, когда предмет сделки денежные средства, по обе стороны. Но если товар продается в обмен на деньги, продавец, при установлении цены, может принимать во внимание различные факторы, включая дату платежа. Продавец, являясь владельцем товара, который имеет «действительную пользу» может взимать более высокую цену, а покупатель может согласиться выкупить товар на этих условиях в силу различных причин, например:
(A) его магазин ближе к покупателю, и он не желает идти на рынок.

(B) покупатель более всех доверяет этому продавцу, нежели другим, в том, что он продаст ему необходимую вещь без дефектов.

(C) продавец имеет большой спрос на этот товар, но в продаже товара отдает предпочтение только этому покупателю.

(D) магазин продавца чище и удобнее, чем другие магазины

(E) продавец более вежлив в обращении, чем другие.

Эти и другие аналогичные конкурентные преимущества играют свою роль в установлений более высокой цены. Таким же образом, если продавец повышает цену, потому что дает своему клиенту товар в кредит, и если в сделке нет обмана, а покупатель принимает эти условия, то это не запрещено шариатом, потому что, независимо от причин роста в цене, это цена товара, а не денег. Правда, что, увеличивая цену на товар, продавец компенсирует время по рассроченному платежу, но так как цена зафиксирована, она относится к товару, а не ко времени. Поэтому, если покупатель не оплатил в установленные сроки, цена останется неизменной и не может быть увеличена по инициативе продавца. Если бы она была привязана ко времени, возможно, было бы увеличить цену, когда продавец позволяет увеличить время платежа.

Говоря иначе, как указывалось выше, поскольку деньги могут обмениваться только по номинальной стоимости, любой прирост на капитал в кредитной сделке (деньги в обмен на деньги) не привязан ничему, кроме как к времени. Поэтому, если заемщику предоставили больше времени на погашение кредита, от него требуется больше денег. Напротив, продавая товар в кредит, время не является исключительным фактором при установлении цены. Цена устанавливается на товар, а не на предоставленное время по кредиту. Однако время может действовать как вспомогательный фактор для определения цены товара, как и любой другой из выше упомянутых факторов, но в этом случае время является частью стоимости товара.

Результат этого обсуждения то, что, когда деньги обмениваются на деньги, не допускается излишек, прирост, ни в сделке по наличному расчету, ни в кредит, но если товар продается за деньги, цена, согласованная сторонами может быть выше, чем рыночная цена, как за наличный расчет, так и в кредитной сделке. Срок платежа может действовать как вспомогательный фактор для определения стоимости товара, но в обмене деньги за деньги срок погашения кредита не может действовать в качестве единственной, исключительной основы для прироста капитала.

Эта позиция одобрено единогласно всеми четырьмя мазхабами и большинством мусульманских правоведов. Они утверждают, что если продавец определяет две разные цены одну за наличный расчет, другую для продажи в кредит, стоимость товара в кредит станет выше, чем цена за наличный расчет, это допустимо по шариату. Единственным условием является то, что в момент фактической продажи, один из двух вариантов должен быть определен, в сделке не должна присутствовать никакая двусмысленность. Например, позволено продавцу, в момент заключения сделки, сказать покупателю: "Если вы приобретете, товар за наличный расчет, то цена 100 тг. а если вы приобретете в кредит на шесть месяцев, то цена 110 тг." Но покупатель обязан выбрать один из двух вариантов. Он должен сказать, что он намерен выкупать в кредит по цене 110 тг. Таким образом, на момент фактической продажи, цена известна обеим сторонам.

Однако если один из двух вариантов не определен, продажа не действительна. Это может произойти в тех сделках с рассроченным платежом, в которой установлены различные цены при различных сроках погашения. В этом случае продавец

оформляет прейскурант цен в соответствии с графиком платежей. Например, 1 000 тг. взимается за кредит на 3 месяца, 1 100 тг. в кредит на 6 месяцев, 1 200 тг. за 9 месяцев и так далее. Покупатель приобрел товар без указания срока погашения кредита, исходя из предположения, что он будет оплачивать кредит, так как это ему будет удобно. Эта сделка является недействительной, поскольку время платежа, а также цена, не определена. Но если он выбирает один из этих вариантов и говорит, например, что он покупает товар на 6 месяцев по цене 1 100 тг., сделка является действительной.

Здесь необходимо отметить еще один момент. Если в сделке продавец ввел условие, что в случае просрочки платежа, он взимает 10% годовых в качестве штрафа, то это полностью запрещено, потому что предъявленное условие, не входит в цену, это процент, начисленный на долг.
Практическая разница между двумя ситуациями в том, что если дополнительная сумма является частью цены, то эта сумма начисляется только один раз. Если покупатель не оплатил эту сумму во время, продавец не может начислить другую дополнительную сумму. Цена остается прежней. И наоборот, если дополнительная сумма не является частью цены, она будет продолжать увеличиваться с периода просроченной даты.

7.3. Использование ставки рефинансирования в качестве ориентира

Многие финансовые учреждения определяют прибыль или наценку по мурабаха договорам на основе текущей процентной ставки, в качестве критерия в основном используют LIBOR (Inter-bank offered rate in London). Например, если LIBOR - 6%, они определяют наценку по мурабаха договорам равную к ставке LIBOR или на несколько процентов выше, чем LIBOR. Эта практика часто подвергается критике на том основании, что прибыль, основанная на процентной ставке должна быть запрещена, потому что является процентом как таковым.
Нет сомнений, что использование процентной ставки для определения халал (дозволенной) прибыли, нежелательна. Это, безусловно, делает сделку похожей на финансирование основанное на процентах, по крайней мере, по описанию, и с учетом категорического запрещения процентов, такое очевидное сходство следует избегать, насколько это возможно. Но не следует игнорировать тот факт, что наиболее важным требованием для действительности мурабаха финансирования это то, что он является договором купли-продажи со всеми необходимыми составляющими и последствиями. Если в сделке по мурабаха соблюдены все условия, перечисленные в этой главе, и используется процентная ставка в качестве ориентира для определения прибыли по мурабаха договору то от этого сделка не становиться недействительной, харам или запрещенной, потому что сделка не содержит процентной ставки. Ставка процента была использована только в качестве индикатора или в качестве ориентира. Для полного понимания разберем один пример.
«А» и «В» два брата. «А» торгует спиртными напитками, которые полностью запрещены по шариату. «В» будучи практикующим мусульманином, против бизнеса «А» и начинает свой бизнес по продаже безалкогольных напитков, но он хочет, чтобы его бизнес, приносил также много прибыли, как и «А» получает путем торговли вином, поэтому он решил, что установит такую же ставку прибыли,

как и «А» при продаже спиртных напитков. Таким образом, он связал свою ставку прибыли по курсу, используемый в запрещенном бизнесе. Возникает вопрос об уместности такого подхода в определении уровня прибыли, но, очевидно, никто не может сказать, что прибыль, взимаемая в его халал бизнесе - харам, потому что он использовал в качестве ориентира ставку прибыли ликероводочного бизнеса.

Кроме того, поскольку сделка по мурабаха договору основана на исламских принципах и выполняет все необходимые требования, то ставка прибыли, определяемая исходя из процентной ставки, не влечет сделку в харам.

Тем не менее, верно, что исламские банки и финансовые учреждения должны избавиться от этой практики как можно скорее, потому что, во-первых, процентная ставка становиться идеальным инструментом для халал бизнеса, что в свою очередь нежелательно, а во-вторых, не имея влияния на систему распределения, не продвигает основную философию исламской экономики. Таким образом, исламские банки и финансовые учреждения должны стремиться к разработке своего собственного ориентира. Это может быть осуществлено путем создания собственного межбанковского рынка, основанного на исламских принципах. Цель может быть достигнута путем создания общего фонда, который инвестирует в активы таких инструментов, как мушарака, иджара т.д. Если большинство активов фонда в материальной форме, например арендованное имущество или оборудование, доли в коммерческих фирмах и т.д. эти доли могут продаваться и приобретаться на основе их фактической стоимости определяемой на периодической основе. Банки, имеющие избыточную ликвидность, могут приобретать эти доли, а когда они нуждаются в ликвидности, они в силе реализовывать их. Этот порядок может создать межбанковский рынок, и стоимость доли может служить в качестве индикатора для определения прибыли в мурабаха договорах и лизинге.

7.4. Обещание приобрести товар

Еще один важный вопрос в мурабаха финансировании, который является предметом дискуссии между современными учеными то, что банк/финансист не может вступить в фактическую продажу на момент, когда клиент заявляет банку о предоставлений ему мурабаха финансирования, потому что на этом этапе необходимые товары не принадлежат банку, и, как указывалось выше, никто не может продать товар пока товар не принадлежит ему, также не может осуществить продажу заранее. Следовательно, он обязан приобрести товар у поставщика, затем после физического или конструктивного владения товаром он может продать его клиенту. С другой стороны, когда клиент не обязан приобрести товар после его приобретения финансистом у поставщика, финансист может столкнуться с ситуацией, когда он несет огромные расходы на приобретение товара, а клиент отказывается от покупки. Это может быть редким товаром, на который не имеется большого спроса на рынке, и очень трудно будет сбыть его. В этом случае финансист может понести огромные убытки.

Решение этой задачи в природе мурабаха договора, требование от клиента подписать обещание купить товар, когда банк приобретет товар для клиента. Это одностороннее обещание со стороны клиента, вместо двустороннего договора о

форвардной продаже. Будучи односторонним обещанием, оно отличается от двустороннего форвардного контракта.
Это решение подвергается возражению в том, что одностороннее обещание создает моральное обязательство, которое в соответствии с шариатом не может осуществиться через суд. Это подводит нас к вопросу, можно ли одностороннее обещание принудить к исполнению по шариату. В целом складывается впечатление, что это не так, но прежде чем принять такое мнение, мы должны рассмотреть его в свете первоначальных источников шариата.
Тщательное изучение соответствующих материалов в книгах по исламскому праву показывает, что фукаха' (мусульманские правоведы) имеют разные мнения по этому вопросу. Их мнения можно обобщить следующим образом:

1. Многие из них считают, что "выполнение обещания" это благородное качество, и целесообразно для обещавшего соблюдать его, и его нарушение требует осуждения, но оно не является обязательным (уаджип), не требует исполнения через суд. Эта точка зрения присутствует у имама Абу Ханифа, имама аш-Шафи'и, имама Ахмада и у некоторых правоведов мазхаба имама Малика. Вместе с тем, как будет описано ниже, многие ученые ханафиты и маликиты и некоторые правоведы мазхаба аш-Шафи'и' не разделяют эту точку зрения.

2. Целый ряд мусульманских правоведов считают, что выполнение обещания является обязательным и, обещавши, находится под моральным, а также юридическим обязательством выполнить свое обещание. По их словам, обещание может быть осуществлено через суд. Эта точка зрения приписывается Самуре б. Джундубу رضى الله عنه известному сподвижнику святого Пророка ﷺ, Умару б. Абдул Азизу, Хасану аль-Басри, Саиду б. аль-Ашуа, Исхаку б. Рахуаи и имаму аль-Бухари. То же самое, по мнению некоторых правоведов мазхаба Малики, этой точке зрения отдали предпочтение Ибн-аль-'Араби и Ибн-аль-Шат, и одобрено аль-Газали, известным правоведом мазхаба аш-Шафи'и, который утверждал, что обещание, является обязательным. То же самое, по мнению Ибн Шубрума. Третье мнение представлено некоторыми правоведами-маликитами. Которые утверждают, что в обычных условиях, обещание не является обязательным, но если, обещавши, дал обещание нести некоторые расходы или в обещаний взял на себя работу или ответственность, оно является обязательным для него, за которое он может быть принужден выполнить это в судебном порядке.
Некоторые современные правоведы утверждают, что ученые, которые приняли обязательный характер обещания сделали это только в связи с односторонними подарками или другими добровольными платежами, но никто из них не принял обязательный характер обещания чтобы осуществлять двусторонние коммерческие или финансовые сделки. Однако на основе тщательного изучения, это замечание не представляется правильным, потому что правоведы-маликиты и ханафиты позволили осуществлять «баи-бильуафа» на основе обязательного обещания. Баи-бильуафа это специальное соглашение о продаже недвижимости в соответствии, с которым покупатель обещает продавцу, позднее вернуть ему недвижимость по этой цене, т.е. он будет перепродавать ему недвижимость. Вопрос о действительности «баи-бильуафа» уже подробно рассматривался в первой главе, где было разъяснено использование мушарака договора по шкале уменьшения для финансирования недвижимости. Суть дискуссии в том, что если продавец

устанавливает условие о выкупе при первоначальной продаже, это сделка не действительна, однако, если стороны заключили первоначальную продажу безоговорочно, но продавец подписал отдельное и независимое обещание по выкупу проданного имущества, это обещание будет обязательным для исполнения, и за не исполнение обещания он может быть привлечен выполнить его в судебном порядке. Обязательный характер обещания в этом случае признан правоведами обеих мазхабов как Малики, так и Ханафи.
Очевидно, что это обещание не связано с подарком. Это обещание осуществить продажу в будущем. Тем не менее, правоведы мазхабов Малики и Ханафи приняли ее в качестве обязательного к исполнению, вплоть до судебного разбирательства. Это является ярким доказательством того, что правоведы, которые считают обещание обязательным к исполнению, не ограничивают обещание в рамках подарков и т.д. Тот же принцип применим, по их мнению, к выполнению обещаний, в соответствии с которым обещавши обязуется заключить двусторонний договор в будущем.

В действительности, священный Коран и сунна пророка ﷺ имеют особое отношение к выполнению обещаний. В священном Коране говорится:

واوفو با لعهد ان العهد كان مسولا(بنى اسرائيل:٣٤)

, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят (17: 34)

يا ايها الذين امنو لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند
الله ان تقولوا مالا تفعلون(الصف : ٢،٣)

О те, кто уверовал! Почему говорите вы то, чего не делаете?
Великую ненависть вызывает у Аллаха то, что говорите вы то, чего не делаете! (“Ряды”, 2 - 3)

Имам Абу Бакр аль-Джасас сказал, что этот аят из священного Корана указывает, что если кто берет на себя обязательство сделать что-то, независимо от того, является ли это договором или нет, оно обязательно к исполнению. Святой пророк ﷺ, сказал:

آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان

Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает (свое обещание), а когда ему доверяются, то он предает

Это лишь один пример. Существует большое количество хадисов пророка ﷺ, где он обязывает выполнять обещания, и четко запрещает нарушать обещание, за исключением уважительных причин.

Таким образом, как видно из этих запретов, выполнения обещания является обязательным. Однако вопрос в том, является ли обещание принудительным в случае отказа в судебном порядке или нет, зависит от характера обещания. Есть, конечно, некоторые виды обещания, которые не могут быть осуществлены через суд. Например, во время участия сторон в обещаний по бракосочетанию. Эти обещания создают моральное обязательство сторон, но они явно не могут быть

осуществлены через суд. Но в коммерческих сделках, когда одна из сторон дала обещание безоговорочно продать или купить что-нибудь, а другая сторона понесла обязательство по этой причине, нет никаких причин не принуждать к выполнению такие виды обещания. Таким образом, на основе четких предписаний ислама, если стороны согласились, что данное обещание будет обязательным по отношению к обещавшему, то оно подлежит исполнению, даже в принудительном порядке.

Вопрос не относится только к мурабаха договорам. Если обещание не подлежит исполнению в коммерческих сделках, то коммерческая деятельность может понести серьезный ущерб. Если кто-либо заказывает трейдеру определенные товары и обещает закупить их, на основе чего трейдер импортирует из-за рубежа за большие деньги, как может быть разрешено заказчику товаров отказываться от приобретения? В священном Коране или сунне не существует запрета на принудительное исполнение обещания.

Именно на этих основаниях Академия Исламского Фикха г. Джидда сделала обещание в коммерческих отношениях обязательным по отношению к обещавшему с соблюдением следующих условий,

(A) Сделанное обещание должно быть односторонним.

(B) Обещание должно иметь причину, которое состоит из какой-либо ответственности.

(C) Если обещание по приобретению чего-либо, то фактическая продажа должна проводиться в назначенное время путем обмена оферты и акцепта. Само по себе просто обещание не следует рассматривать как заключенную продажу.

(D) Если обещавший отказывается от своих обещаний, то суд может принудить его либо купить товар или оплатить фактический ущерб продавца. Фактические убытки состоят из фактических денежных потерь, понесенные продавцом, но без прибыли.

Исходя из этого, допускается, что клиент обещает банку купить товар, после того как тот приобретет его у поставщика. Это обещание является обязательным для него, и может взыскиваться через суд в выше приведенном порядке. Это обещание не ведет к фактической продаже. Фактическая продажа состоится, после того как банк приобретет товар, для которого будет необходим обмен оферты и акцепта.

7.5. Обеспечение гарантией сделки по мурабаха договору

Еще один вопрос относительно мурабаха финансирования это то, что оплата по мурабаха договору осуществляется траншами после заключения сделки. Продавец/банк естественно желает быть уверенным, чтобы стоимость товара была выплачена в срок. Для этой цели, банк может потребовать от клиента предоставить гарантию (обеспечение). Гарантия может быть в форме залога, закладной или поручительства. Следует иметь в виду некоторые основные правила гарантий.

(1) Право на предоставление гарантий можно заявить там, где сделка создает обязательство или долг. Гарантия не может требоваться от человека, который не несет ответственности и долговых обязательств. Как указывалось выше, процедура мурабаха финансирования включает различные операции, осуществляемые на разных стадиях. На раннем этапе сделки, клиент еще не приобретает долг. Только после того как банк продает товар в кредит, отношения вступают в силу в качестве кредитора и заемщика. Таким образом, надлежащий путь по сделке мурабаха это когда банк требует обеспечение по кредиту после того, как он действительно продал товар клиенту, потому что на этом этапе клиент берет на себя ответственность в виде кредита. Однако, также допустимо, когда клиент предоставляет гарантию в виде активов на ранних стадиях, но после того, как определяется цена по мурабаха договору. В этом случае, все риски по предоставленному залогу переходят финансисту, под этим понимается, если залог поврежден до фактической сделки по мурабаха, банк должен будет либо выплатить рыночную стоимость заложенного актива, и отменить соглашение по мурабаха или продать товар, требуемый клиентом и компенсировать рыночную стоимость заложенного актива с помощью проданного имущества.

(2) Кроме того, допустимо, когда сам объект сделки является обеспечением по кредиту. Некоторые ученые считают, что это возможно только после того как покупателю доставлен товар, и не раньше. Это означает, что покупатель примет доставку товара, в физической или конструктивной форме, затем возвращает его в качестве залога, так что сделка с гарантийным обеспечением отличается от сделки купли-продажи.

Таким образом, не обязательно, чтобы покупатель принял поставку проданного имущества, прежде чем он предъявит его в качестве залога по кредиту. Единственное обязательное условие следует указывать время в соответствии, с которым имущество переводится в качестве залога по кредиту, поскольку с этого момента времени, на имущество распространяются иные правила. Например, «А» продал автомобиль «В» на 1 января по цене 500 000 тг. Подлежащие к уплате до 30-го июня. «А» попросил «В» обеспечить гарантией оплату в установленный срок. Автомобиль еще не доставили к «В» и он предложил «А», что автомобиль будет в залоге в качестве обеспечения от 2-го января. Если автомобиль поврежден по каким-то причинам до 2-го января договор купли-продажи будет прекращен, и «В» ничего не будет оплачивать. Но если автомобиль поврежден после второго января, договор не прекращается, но он будет регулироваться правилами, которые используются при повреждений залога. По словам правоведов мазхаба имама Абу Ханифа, в этом случае продавец несет потери в связи повреждением автомобиля, в размере его рыночной стоимости или при продажной стоимости.

Это, по мнению ученых мазхаба имама Абу Ханифа. Правоведы мазхаба имамов аш-Шафи'и и Ханбали считают, что если автомобиль поврежден по халатности залогодержателя, он несет потери, в соответствии с ее рыночной ценой, но если автомобиль поврежден не по его вине, он не несет ответственности, а покупатель несет ответственность за потери, и ему придется оплатить полную стоимость.
Как видно из выше приведенного примера, что владение автомобилем стороны «А» как продавца имеет отличительные действия и последствия, от его ответственности

в качестве залогодержателя, и в связи с этими правилами необходимо, чтобы время, когда автомобиль переходит в качестве залога должно быть четко определено. В противном случае не определенность рождает спор и делает залог по кредиту недействительным.

7.6. Поручительство в мурабаха договорах

Продавец в мурабаха финансирований может также потребовать от покупателя/клиента предоставить гарантию третьего лица. В случае неисполнения обязательств по кредиту в установленный срок, продавец может обратиться к гаранту, который будет обязан оплатить гарантированную сумму. Правила шариата в отношении гарантии в полной мере рассмотрены в книгах по исламскому фикху. Тем не менее, хотелось бы отметить два актуальных вопросов в контексте исламского банкинга.

Гарант в современной коммерческой атмосфере обычно не гарантирует платеж без платы за эту услугу, взимаемой с заемщика. Классическая литература по фикху почти единодушна в том, что гарантия является добровольным актом, и за гарантию не может, взиматься оплата. Гарант может требовать только фактические расходы, понесенные в связи оформлением гарантии, но гарантия сама по себе должна быть бесплатной. Причина этого запрета в том, что лицо, выдавшее деньги другому лицу в качестве займа не может взимать плату за продвижение этого кредита, поскольку оно подпадает под определение риба или процент который в свою очередь запрещен. Гарант является основой запрета, потому что он не выдает этого кредита. Он просто берет на себя обязательство выплатить определенную сумму от имени заемщика в случае, если заемщик не состоятелен, осуществить платеж. Если лицо, которое реально платит деньги, не может взимать плату за это действие, как лицо, которое лишь обязалось оплатить и в реальных условиях не оплачивает ничего, может взимать плату за эту услугу?

Предположим, «A» занял 100 долларов США у «B», который попросили его предоставить гарант по сделке. «C» говорит «A»: "Я погашу вашу задолженность перед «B» прямо сейчас, но вы должны будете заплатить мне 110 долларов через определенное время". Очевидно 10 долларов взимаемые с «A» будучи начисленным процентом, не допускаются. Тогда «D» обращается к «A» и говорит: "Я выступаю в качестве гаранта для вас, но вы должны будете заплатить мне 10 долларов за эту услугу". Если мы позволим взимать плату за гарантию то, на каком оснований «C» не может взимать 10 долл. США, несмотря на то, что он, фактически готов оплатить сумму а «D» может взимать 10 долл. США, несмотря на то, что он просто взял на себя обязательство выплатить долг при условий, если «A» не в состоянии сделать этого. По-видимому, это несправедливость, классические мусульманские правоведы запретили взимать плату за гарантию, так как и «C» и «D», в приведенном выше примере, стоят на одном и том же уровне.

Однако некоторые современные ученые рассматривают эту проблему с иной точки зрения. Они считают, что гарантия стала необходимостью, особенно в области международной торговли, где продавцы и покупатели не знакомы друг с другом, и оплата товара покупателем, не может произойти одновременно с поставкой товара. Там должен быть посредник, который в состояний гарантировать оплату. Крайне

трудно найти гаранта, который может предоставить эту услугу бесплатно в необходимом количестве. С учетом этих реалий, некоторые ученые нашего времени приняли иной подход. Они говорят, что запрет на взимание гарантийной суммы не основан на каком-либо конкретном предписаний священного Корана или сунны пророка ﷺ. Он произошел от запрета рибы. Кроме того, гарантия в прошлом была простой. В коммерческой активности сегодняшнего дня, гаранту иногда требуется ряд исследований. Поэтому высказывается мнение, что запрет на гарантийные суммы следует пересмотреть с учетом этой перспективы. Вопрос по-прежнему нуждается в дальнейших исследованиях и должен быть выдвинут на повестку дня перед большим форумом ученых.

7.7. Компенсация за просроченный платеж

Еще одна проблема в мурабаха финансирований это, когда клиент не выполняет обязательства к установленной дате, цена не может быть увеличена. В кредитах основанных на проценте, сумма кредита продолжает увеличиваться в соответствии с периодом неисполнения обязательства. Но в мурабаха финансирований, так как цена фиксирована, она не может быть увеличена. Это ограничение иногда используется недобросовестными клиентами, которые сознательно избегают уплаты кредита к установленной дате, потому что они знают, что им не придется выплачивать дополнительную сумму в виде начисленной пени по кредиту.

Эта характеристика мурабаха финансирования не должна создавать большой проблемы в стране, где все банки и финансовые институты работают по исламским принципам, потому что правительство и центральный банк могут разработать такую систему, где мошенничество может быть подвергнуто наказанию, в виде лишения возможности получения каких-либо средств из любого финансового учреждения. Эта система может служить сдерживающим фактором в отношении преднамеренного злоупотребления доверием. Однако в тех странах, где исламские банки и финансовые учреждения, работают в отрыве от большинства финансовых учреждений управляемых на основе процентного кредитования, такая система вряд ли даст результат, потому что даже если клиент лишен возможности прибегнуть к средствам от исламских банков, он может обратиться в обычные банки.

Для того чтобы решить эту проблему, некоторые современные ученые полагают, что на клиентов, которые намеренно не оплачивают кредит, следует возложить ответственность по выплате компенсации исламскому банку за ущерб, причиненный по причине просроченного платежа. Они полагают, что размер этой компенсации может быть равен прибыли, которую банк выплачивает своим вкладчикам в требуемый период. Например, заемщик не оплачивал кредит три месяца. Если банк в этот период выдавал своим вкладчикам прибыль в размере 5%, то заемщик должен оплатить более 5% в качестве компенсации по потерям банка. Тем не менее, ученые которые позволяют эту компенсацию, также утвердили следующие условия:

(а) неплательщику следует предоставлять льготный период не менее одного месяца после просроченной даты в течение, которого ему предоставляются еженедельные уведомления, что он должен оплатить кредит, в противном случае он будет вынужден выплатить компенсацию.

(б) Если окажется, что клиент просрочил платеж не намеренно, а из-за не состоятельности (бедности), от него не возможно требовать компенсацию. В действительности, ему следует предоставить временную отсрочку по выплате кредита, потому что в священном Коране прямо указывается,

وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسرة

А если кто в тягости, то – ожидание до облегчения… (2:280)

(с) компенсация допускается только, если в исламском банке на инвестиционный счет начислялась прибыль для распределения среди вкладчиков. Если инвестиционный счет в банке не получал прибыли в период просроченного платежа, от клиента не возможно требовать компенсацию.

Эта концепция, однако, на сегодняшний день не принята большинством ученых (включая автора). По мнению этих ученых, это предложение не соответствует принципам шариата, и не способна решить проблему просроченных платежей.

Прежде всего, любая дополнительная сумма, принятая от заемщика - риба. Во времена джахилий (до ислама) люди практиковали взимание дополнительных сумм с заемщиков, когда те не успевали выплатить долг к установленному сроку, они утверждали следующее,

اما ان تقضي واما ان تربي

Либо ты выплатишь задолженность или выплачиваемая сумма увеличится.

Вышеупомянутое предложение о выплате компенсаций кредитору/продавцу напоминает такое же отношение.

Можно утверждать, что вышеупомянутое предложение теоретический отличается от практики джахилий в том, что концепция предоставляет заемщику льготный период продолжительностью в один месяц, чтобы убедиться, по какой причине он уклоняется от предоставлений платежа. И если по причине временной не состоятельности, то клиент освобождается от выплаты компенсации. Однако при практическом применений этой концепции, эти условия вряд ли будут выполнятся, потому что каждый заемщик может утверждать, что он не выплачивает кредит из-за его финансовых проблем, и очень трудно для финансового учреждения провести расследование по поводу финансового положения каждого клиента, с целью проверить в состоянии ли он выплачивать кредит. Если клиент не объявлялся банкротом или неплатежеспособным, банки обычно предполагают, что каждый такой клиент в состоянии выплачивать кредит. Очевидно, что несостоятельность - это редкое явление, и в этой редкой ситуации, даже банки, основанные на процентах, обычно не могут взыскать кредит со стороны заемщика. Таким образом, предложенная выше концепция не имеет никаких практических и конструктивных различий отделяющих исламское финансирование от финансирования, основанного на процентах.

То же касательно льготного периода, который также иногда практикуется обычными банками. И опять же в практическом плане, нет никакой существенной разницы между процентом и компенсацией взимаемой за просроченный платеж.

Утверждают, в пользу начисления компенсации, что святой пророк ﷺ осуждал лиц, которые задерживают выплату по своим долгам без уважительной причины. В известном хадисе сказано:

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه

Состоятельный человек, который задерживает выплату своего долга заслуживает наказания (примерный перевод)

Довод основан на том, что святой пророк ﷺ позволил наказывать таких людей. Наказания могут быть различного рода, включая наложение денежного штрафа. Но этот аргумент игнорирует тот факт, что даже если предположим, наложение денежного штрафа допускается по шариату, это обвинение предъявляется судом и обычно штраф выплачивается правительству. Никто не может допускать ситуацию, когда потерпевшая сторона налагает штраф по своему собственному усмотрению (для своего собственного блага), без постановления суда компетентного принимать такого рода решения.

Более того, если за просроченный платеж определено наказание, с заемщика следует взыскать этот штраф, даже если за этот период на инвестиционный депозит банка не начислялась прибыль, потому что вина неплательщика установлена, и это не связано с прибылью по инвестиционному депозиту банка.

В действительности, предложение о компенсации, которая равна ставке прибыли по инвестиционному депозиту, основана на концепции «издержки связанные с кредитными деньгами». Эта концепция не соответствует принципам шариата. Ислам не признает издержки по инвестированному капиталу, так как деньги не имеют заранее определенного дохода. Всегда присутствует возможность приобрести ущерб, или получить прибыль. И именно этот риск потерь дает право получать доход по инвестициям.

Заслуживает внимания еще один момент. Тот, кто просрочил оплату долга, более схож с вором или узурпатором. А наказание, которому подвергается вор очень суровое, ампутация руки, но от него никогда не потребуют выплатить дополнительную сумму, с целью скомпенсировать потерпевшей стороне кражу. Аналогичным образом, если человек узурпировал деньги другого человека, он может подвергнуться наказанию в виде таазир, но нет мусульманских правоведов, которые когда-либо принуждали к денежному штрафу, с целью компенсаций.
Имам аш-Шафи'и считает, что если кто-то узурпировал землю другого человека, ему придется выплатить плату за аренду земли по рыночной цене. Но если он присвоил деньги, он вернет равную сумму денег и не более.

Все эти правила доказывают, что издержки связанные с кредитными деньгами никогда не будут признаны по шариату, поскольку, как указывалось выше, инвестированные деньги не имеют предопределенного дохода, ни какую-либо действительную полезность.

Исходя из сказанного выше, идея взыскания компенсаций с неплательщика не утверждена большинством современных ученых. Вопрос подробно обсуждался на ежегодной сессии Академии Исламского Фикха г. Джидда, где принято решение, что по шариату такого рода компенсация не допускается.

Все эти доводы связаны с недопустимостью предлагаемой компенсации по шариату. Теперь следует отметить, что это предложение не решает проблему неплатежей вообще. Наоборот, оно может побудить заемщиков к совершению столько просроченных платежей, сколько желают. Причина в том, что, согласно этому предложению, неплательщик обязан выплатить компенсацию равную к доходу по депозитам за период не выполнений обязательств по кредиту. Очевидно, что сумма прибыли, начисляемая на депозиты всегда меньше, чем сумма прибыли, выплачиваемая клиентом в сделке по мурабаха договору. Таким образом, клиент после неисполнения обязательств по кредиту выплачивает, гораздо меньше, чем он будет выплачивать, соответствуя графику погашения. Поэтому он охотно пойдет на выплату требуемой компенсаций. Предположим, что ставка прибыли, согласованная по мурабаха договору на шесть месяцев составляет 15% годовых и ставка прибыли объявленная вкладчикам составляет 10% годовых. Это означает, что если клиент не оплачивает кредит 6 месяцев подряд, тогда после этой даты в течений 6 месяцев он должен выплачивать компенсацию в размере 10% годовых, это значительно меньше, чем первоначальный мурабаха договор (т.е. 15%). Конечно, клиент будет стараться играть роль неплательщика, так как кредит можно продлить еще на шесть месяцев при меньшей ставке.

Следовательно, это предложение, не только противоречит шариату, но и вообще не решает проблему просроченных платежей. Альтернативное предложение. Теперь возникает вопрос, как банки и финансовые учреждения могут решить эту проблему. Если с неплательщика ничего не будет взиматься, для мошенника возникает большой стимул не оплачивать кредит непрерывно. Вот ответ на этот вопрос:

Мы уже упоминали о том, что реальное решение этой проблемы это создание системы, где неплательщики несут наказание, в виде лишения возможности пользоваться финансовыми инструментами в будущем. Однако, как описано ранее, такая система может функционировать только там, где вся банковская система основана на исламских принципах, или исламские банки уделяют должное внимание защите от мошенничества. Поэтому, до того времени, когда будет достигнута эта цель, нам понадобиться другой альтернативный путь.

Для этой цели было высказано предположение о том, что клиент, при заключении договора по мурабаха финансированию должен взять на себя обязательство, что в случае, если он просрочит оплату кредита сверх установленного срока, то выплатит определенную сумму в благотворительный фонд представленный банком. Следует гарантировать, что ни одна из частей от этой суммы не будет составлять доход банка. Вся начисленная сумма должна использоваться исключительно в благотворительных целях, одобренных шариатом. Банк может также из этого благотворительного фонда предоставлять беспроцентные займы нуждающимся лицам.

Это предложение основано на постановлении, выданном некоторыми учеными мазхаба имама Малика, которые постановили, что если от заемщика требуют выплатить дополнительную сумму в случае неисполнения обязательства, это не разрешено шариатом, поскольку эта сумма - начисленные проценты. Вместе с тем,

чтобы обеспечить кредитора своевременной оплатой, заемщик может взять на себя обязательство, что в случае просрочки по кредиту выплатит некоторую сумму на благотворительность. Это, по сути, своего рода «ямин» (обет), является добровольным актом со стороны заемщиков, в виде сдерживающего фактора от случаев мошенничества. Как правило, такие "клятвы" создают моральную или религиозную обязанность и не имеют юридической силы. Однако некоторые правоведы мазхаба имама Малика, позволили придавать таким обязанностям юридическую силу, и нет ничего в Коране или сунне пророка ﷺ которое запрещало бы принудительное исполнение «обета» через суд. Таким образом, в случае реальной необходимости, эту точку зрения можно принять. Но при осуществлении этого предложения, следует соблюдать следующее.

1. Это предложение предназначено только для оказания влияния на заемщиков с целью своевременной оплаты согласованных взносов по кредиту, а не увеличение дохода кредитора/финансиста, или компенсирование его издержек. Следовательно, следует гарантировать, что ни одна из частей от этой суммы не будет составлять доходы банка или будет направлена на покрытие каких-либо расходов банка.

2. Поскольку выплачиваемый штраф не входит в активы банка, в виде дохода, а идет на благотворительность, сумма штрафа, добровольно одобренная заемщиком, может быть в любом количестве. Штраф также может быть определен на основе годовых процентов. Таким образом, штраф может служить реальным сдерживающим фактором в отношении преднамеренного уклонения от своевременной оплаты кредита, в отличие от выше упомянутого предложение о компенсации, которое, как было объяснено ранее, склонно поощрять просроченные платежи.

3. Поскольку штрафные санкций это добровольная клятва, осуществляемая клиентом, а не пеня, взимаемая банком, то договор должен отражать эту концепцию. Таким образом, тщательное предложение штрафной санкций следует сформулировать по следующей схеме,
"Клиент обязуется, что в случае нарушения графика погашения выданного ему кредита в соответствии с настоящим договором, он обязан выплатить благотворительному фонду/счету утвержденный банком/финансистом сумму рассчитанную на основе ...% годовых за каждый день просрочки, пока клиент не предоставил доказательство приемлемое для банка/финансиста, что несоответствие платежей по кредиту к графику погашения было вызвано по причине несостоятельности или других не зависящих от клиента факторов".

4. Будучи клятвой сделать благотворительный акт, первоначально клиенту допускалось, предоставлять предусмотренные суммы на любые благотворительные цели по своему собственному выбору, но для того чтобы быть уверенным, что клиент выплатит сумму финансист/банк в обязательном порядке предлагает клиенту свой благотворительный счет или фонд. Это предложение не нарушает принципов шариата. Тем не менее, необходимо чтобы банк или финансовое учреждение имел отдельный фонд или, по крайней мере, отдельный счет для этой цели и суммы, зачисленные на этот счет должны быть, потрачены в четко определенные благотворительные цели известные клиенту/заемщику.

Это предложение в настоящее время успешно реализуется в большинстве исламских финансовых учреждений.

7.8. Нет рефинансирования в мурабаха договорах

Другое правило, которое следует помнить и в полной мере выполнять это то, что мурабаха сделка не может быть рефинансирована на более поздний период. В финансирований основанном на проценте, если заемщик банка не в состояний выплачивать кредит в установленный срок по какой-либо причине, он может обратиться в банк с заявлением о рефинансировании долга. Если банк соглашается, то с этого времени кредитная сделка вступает в силу на новых взаимно оговоренных условиях, где применяется новая процентная ставка. Это фактически означает, что еще один кредит повторно выдается на ту же сумму.

Некоторые исламские банки или финансовые учреждения, которые имеют не правильное представление концепций мурабаха финансирования, используют его лишь в качестве способа финансирования аналогично кредитованию основанном на проценте, и в мурабаха договорах они также применяют концепцию рефинансирования по кредиту. Если клиент заявляет продлить срок погашения кредита, банк пересматривает срок платежа с дополнительной наценкой взимаемой с клиента, которая практически означает, что еще один отдельный мурабаха договор оформляется на тот же товар. Эта практика полностью противоречит установленным принципам шариата.

Следует четко понимать, что мурабаха сделка это не кредит. Это договор купли-продажи, платеж по которой рассрочен до определенной даты. После того как товар продан, товар переходит в собственность клиента. Товар не в собственности продавца. На что продавец может законно претендовать то это на согласованную цену, которая становится задолженностью покупателя. Таким образом, нет никакой необходимости осуществлять иную сделку на тот же товар, между теми же сторонами. Рефинансирование долга в мурабаха договорах является ничем иным как просто процентом, потому что это соглашение позволяет взимать дополнительную сумму по задолженности созданной мурабаха договором.

7.9. Скидки на досрочный платеж

Иногда заемщик желает погасить долг заранее. В этом случае он хочет получить скидку по уже согласованному рассроченному платежу. Допустимо ли предоставление скидки при досрочном погашений кредита? Этот вопрос детально обсужден классическими правоведами. В исламской литературе по правоведению именуется как "ضع و تعجل" (предоставь скидку и получи (долг) в ближайшее время). Раннее некоторые правоведы считали такую договоренность допустимой, но большинство мусульманских правоведов, в том числе четыре признанных школ по исламской юриспруденции не позволяют, когда скидка предоставляется при условий досрочного платежа.

Точка зрения тех, которые позволяют этот довод, основана на следующем хадисе,

Абдулла ибн رضى الله عنه сообщил, что когда евреи племени Бану Надир были изгнаны из Медины (по причине заговора с их стороны), некоторые люди обратились святому пророку ﷺ и сказали: "Вы приказали нас выгнать, но некоторые люди должны нам некий долг, который еще не выплачен". Тогда пророк ﷺ сказал им (т. е. евреям которые предоставляли кредиты)

ضعوا وتعجلوا

Предоставьте скидку и получите (свой долг) в ближайшее время (примерный перевод)
Большинство мусульманских правоведов, однако, не рассматривают этот хадис достоверным. Даже имам аль-Байхаки, который сообщил этот хадис в своей книге, прямо признал, что это хадис со слабым повествованием.

Даже если хадис достоверный, изгнание Бану Надир произошло на второй год после Хиджры, когда риба еще не была запрещена.
Кроме того, аль-Уакиди упомянул, что Бану Надир занимались предоставлением ростовщических кредитов. Возможно, если хадис и достоверный, то пророк ﷺ скорее всего предлагает отказаться от процента и получить только основной долг, потому что аль-Уакиди имеет сообщение что Саллам б. Аби Хукаик, еврей из племени Бану Надир, предоставил восемьдесят динаров Усаиду ибн Худаиру رضى الله عنه на один год с наценкой 40 динаров. Таким образом, Усаид задолжал ему 120 динаров по истечению одного года. После этого договора, он выплатил основную сумму 80 динаров и Саллам снял с него ответственность за остальные деньги.

По этим причинам, большинство правоведов считают, что если досрочный платеж обусловлен скидкой то, это не допустимо. Однако если скидка не принята, в виде условий по досрочному платежу, и кредитор по доброй воле предоставляет эту самую скидку то, это допустимо.

Той же точки зрения придерживается Академия по Исламскому Праву.
Это означает, что в мурабаха сделке осуществляемой исламским банком или финансовым учреждением, скидка не может оговариваться при заключений договора, и клиент не может требовать ее. Однако, если банк или финансовое учреждение предоставляет скидку по своему собственному усмотрению, это не вызывает возражений, особенно если клиент нуждающийся человек. Например, если несостоятельный фермер приобрел трактор или сельскохозяйственные приспособления на основе мурабаха договора, банку следует добровольно предоставить скидку.

7.10. Калькуляция себестоимости по мурабаха договору

Уже упоминалось, что мурабаха сделка предусматривает концепцию продажи с наценкой, следовательно, сделка осуществляется только тогда, когда продавец установит точную стоимость товара, которую он желает продать. Если точная стоимость не установлена, не возможно провести мурабаха сделку. В этом случае

продажу следует осуществлять на основе договора мусавамах (т.е. продажа без учета стоимости).

Этот принцип приводит к еще одному правилу: мурабаха сделка должна основываться на той же валюте, по которой продавец купил товар у поставщика. Если продавец приобрел товар в тенге, дальнейшая продажа конечному покупателю также должна осуществляться в тенге, и если первая покупка произошла в долларах, цена мурабаха договора также утверждается в долларах, так чтобы установить точную цену.

Однако в случае международной торговли, трудно осуществить обе сделки в той же валюте. Если товар, предназначенный для продажи клиенту, импортируется из иностранного государства, в то время как конечный покупатель находится в Казахстане, цена первой сделки должна быть определена в иностранной валюте, а цена второй продажи определяется в тенге.

У этой ситуаций есть два способа решения. Во-первых, если конечный покупатель согласен и законы страны позволяют, то цена во второй продаже может устанавливаться в долларах.
Во-вторых, если продавец для закупа товаров, обменивал казахстанские тенге на доллары то, точное количество казахстанских тенге использованных при обмене на доллары, могут быть приняты за основу в определении себестоимости, и уже к этой цене можно добавить прибыль по мурабаха сделке.
В некоторых случаях банк покупает товары из-за границы с возможностью оплаты через три месяца или рассроченным платежом, и реализует товары своим клиентам. Поскольку банк выплачивает в долларах то, на тот момент, когда товар продается клиенту эквивалентная сумма в казахстанских тенге не определена. В связи с колебанием обменного курса валют возможно банку придется выплатить больше, чем это предполагалось во время заключения мурабаха договора. Например, курс доллара США на момент заключения мурабаха договора был 120 тенге за один доллар. Цена в мурабаха договоре устанавливалась в соответствии с этим курсом валют, но когда банк собрался выплатить поставщику, курс доллара увеличился до 150 тенге за один доллар, таким образом, стоимость товара для банка увеличилась на 25 %. В целях решения этой ситуации некоторые финансовые учреждения ставят условие в мурабаха договорах, что в случае колебания курса валют, клиент несет дополнительные затраты. Согласно классическим мусульманским правоведам, мурабаха договор, основанный на этих условиях, не допустим, так как это приводит к неопределенности в цене на момент продажи. Такая неопределенность продолжается в течений всего срока договора. Такая неопределенность делает сделку недействительной. Таким образом, для банка по этому вопросу существуют следующие варианты решения:

(А) банк должен приобрести данный товар на основе аккредитива и рассчитаться с поставщиком до осуществления продажи покупателю. В данном случае колебание валютных курсов не влияет на сделку. Цену по мурабаха договору можно определить на основе рыночного курса долл. США в день, когда банк рассчитался с поставщиком.

(B) Банк вычисляет цену по мурабаха договору в долларах США, а не в тенге, с тем, чтобы клиент выплачивал рассроченные платежи по мурабаха договору в долларах. В этом случае риск колебания курса валют несет покупатель.

(C) Вместо мурабаха договора, можно заключить договор мусавамах (продажа без учета расходов по приобретению товара продавцом), и цену можно установить учитывая ожидаемые колебания курсов валют.

7.11. Предмет купли-продажи в мурабаха договорах

Все товары, которые могут быть предметом купли-продажи с наценкой могут являться предметом сделки по мурабаха договору, потому что это особый вид купли-продажи. Таким образом, доля (акций и т.д.) в компаний (соответствующая принципам шариата) может быть продана или приобретена на основе мурабаха договора, поскольку в соответствии с исламскими принципами, акции компании представляют собой долевую собственность владельца в активах компании. Если активы компании можно продавать с начисленной наценкой то, его акции могут быть проданы по мурабаха договору. Но, само собой разумеется, что сделка должна соответствовать всем основным условиям. Таким образом, продавцу следует сначала приобрести акции в собственность, и только после продавать их. Соглашение об обратном выкупе или продажа акций без права собственности на эти акций не допускаются вообще.

И наоборот, мурабаха договор не применяется на те товары, которые не являются предметом купли-продажи, например не возможно осуществить мурабаха договор, где предметом продажи является валюта. Валюту можно продать на основе рассроченного платежа, но по рыночному курсу на дату заключения сделки. Кроме того, коммерческие документы представляющие дебиторскую задолженность владельца не могут быть реализованными или приобретенными за исключением только по номинальной стоимости, и поэтому в отношении таких документов мурабаха договор не осуществляется. Аналогичным образом, любой документ, дающий право на получение определенной суммы денег от эмитента не может быть предметом договора. Здесь единственный способ купли-продажи это продать по номинальной стоимости.

7.12. Реструктуризация платежей по мурабаха договору

Если покупатель/клиент в мурабаха финансирований не в состоянии выплачивать касательно утвержденному графику погашения долга, он иногда просит продавца/банк реструктурировать платежи. В обычных банках кредиты, как правило, пересматриваются на основе дополнительного процента. В договоре по мурабаха финансированию это невозможно. Если и возможно то, без дополнительной суммы предъявляемой для реструктуризации. Сумма мурабаха договора остается неизменной в той же валюте.

Некоторые исламские банки предлагают реструктуризацию мурабаха сделки в твердой валюте, отличной от той, по которой состоялась первоначальная продажа. Это предложение позволяет возместить банку посредством оценки стоимости твердой валюты. Это предложение не допустимо. Реструктуризация всегда должна, производится на основе той же суммы в той же валюте. Однако в момент оплаты

покупатель с согласия продавца может расплатиться в другой валюте на основе обменного курса на тот же день (т.е. в день оплаты), а не по курсу на дату заключения сделки.

7.13. Секьюритизация мурабаха

Мурабаха является сделкой, которая не может быть секьюритизирована для создания оборотного инструмента, который можно продать или купить на вторичном рынке. Причина очевидна. Если покупатель/клиент в мурабаха договоре подписывает документ, в качестве доказательства имеющегося долга перед продавцом/финансистом, документ от его имени представлять денежную дебиторскую задолженность. Иными словами, это деньги причитающиеся с него. Поэтому передача этого документа третьему лицу означает передачу денег. Как уже разъяснено, когда деньги обмениваются на деньги (в той же валюте) передача должна быть равноценной. Деньги нельзя приобретать или реализовать за более низкую или более высокую цену. Таким образом, документ представляющий денежное обязательство, вытекающее из мурабаха сделки, не может создать оборотный инструмент. Если осуществляется передача документа, то только по номинальной стоимости. Однако если имеет место смешанный портфель, состоящий из целого ряда сделок как мушарака, иджара и мурабаха то с этого портфеля можно выпускать оборотные сертификаты, более подробно обсуждается в главе "исламские фонды".

7.14. Некоторые основные ошибки в мурабаха финансирований

После объяснения концепции мурабаха и ее соответствующих вопросов, было бы уместно остановиться на некоторых основных ошибках, которые часто совершают финансовые учреждения при практическом применении этой концепции.

1. Первая и главная ошибка, считать, что мурабаха финансирование это универсальный инструмент, который можно использовать для всех видов финансирования, предлагаемых обычными банками основанных на процентном финансирований. В рамках этого ложного предположения, некоторые финансовые учреждения применяют мурабаха договор для финансирования накладных расходов фирмы или компании, такие как выплата заработной платы сотрудников, оплата счетов за электроэнергию и т.д., и выплата долгов другой стороны. Такая практика является абсолютно неприемлемой, потому что мурабаха финансирование можно использовать только тогда, когда клиент намерен приобрести товар, предназначенный для него. Если средства необходимы для других целей, они не привлекаются с помощью мурабаха сделки. В таких случаях есть другие способы финансирования, такие как мушарака, лизинг и т.д.

2. В некоторых случаях клиенты оформляют сделку по мурабаха договору, чтобы просто получить средства. Они не намеревались использовать эти средства для приобретения конкретного товара. Они просто желают получить средства для неопределенных целей, но чтобы соответствовать требованиям официальных документов они называют фиктивные товары. Получив деньги, они используют их на любые цели по своему усмотрению.
Очевидно, это фиктивная сделка, и исламский финансист должен тщательно разобраться в этом. Это их обязанность, чтобы убедиться, что клиент

действительно намерен приобрести товар, где можно использовать мурабаха договор. Эта сделка должна проходить одобрение уполномоченного лица. Тогда будут предприняты все необходимые шаги, подтверждая, что сделка является подлинной. Например:

(а) Вместо того, чтобы выдавать средства на руки клиенту, выплачивать следует непосредственно поставщику.

(б) Если необходимо выдать средства клиенту для приобретения товара от имени финансиста, его приобретение должно подтверждаться счет-фактурой или другим аналогичным документом, которые он должен представить финансисту.

(с) Если ни один из двух выше указанных требований не возможно выполнить, финансовому учреждению следует организовать физический осмотр приобретенного товара.
Во всяком случае, исламское финансовое учреждение обязано убедиться, что мурабаха договор - подлинная и реальная сделка с фактической продажей, а не кредит, основанный на процентах под «маской» ислама.

3. В некоторых случаях продажа товара клиенту производится до фактического приобретения товара от поставщика. Эта ошибка всегда совершается в операциях, где все документы по мурабаха сделке подписываются в одно и то же время, не принимая во внимание его различные этапы. Некоторые учреждения имеют только один договор по мурабаха сделке, который подписывается сторонами в момент выплаты денег, а в некоторых случаях, во время утверждения объекта продажи. Это полностью противоречит финансированию основанном на принципах мурабаха. Как уже было описано в этой статье, соглашение на основе мурабаха представляет собой пакет различных договоров, которые вступают в силу один за другим при соответствующем этапе. Эти этапы в полной мере описаны ранее при обсуждении концепции «мурабаха финансирование». Без соблюдения основных особенностей по мурабаха финансированию, вся сделка превращается в просто заем выданный под проценты. Простая замена номенклатуры не делает договор законным по шариату.

Представители Совета банка по надзору на соответствие шариату (Кредитный комитет), при одобрений сделки на соответствие шариату, должны убедиться, что все этапы соблюдены.

4. При осуществлений международных сделок с товарами часто прибегают к управлению ликвидностью. Некоторые исламские банки считают, что эти операции, будучи основанными, на активах, легко можно заключить на основе мурабаха договора, игнорируя тот факт, что эти операции, не соответствуют принципам шариата. Во многих случаях они являются фиктивными операциями, где не происходит фактической доставки товара. Стороны в конечном итоге выплачивают лишь разницу по цене. В некоторых случаях участвуют реальные товары, но на условиях форвардной или кратковременной продажи, которые не допускаются по шариату. Даже если операция ограничена сделкой основанной на

спот цене, то следует сформулировать ее на основе исламских принципов мурабаха, выполнив все необходимые условия уже упомянутые в этой книге.

5. Некоторые финансовые учреждения, осуществляют мурабаха договор на товары уже приобретенные клиентом у третьей стороны. Так как товар приобретен клиентом, он не может быть приобретен снова от одного и того же поставщика. Если товар приобретен банком у клиента и продан ему назад, это система обратного выкупа, которая не допускается по шариату, особенно в мурабаха сделке. На самом деле, если клиент уже купил товар, и обратился в банк с заявлением выделить средства, то он желает использовать эти средства на другие цели. Во всяком случае, исламский банк не может профинансировать его на основе мурабаха договора. Мурабаха сделка осуществляется, только если клиент пока еще не приобрел товар.

7.15. Заключение

Из вышеизложенного обсуждения различных аспектов договора мурабаха, можно сделать следующие выводы которые следует помнить:

1. По происхождению мурабаха сделка не является способом финансирования. Это обычная продажа на основе, стоимость товара плюс наценка. Однако, после совмещения с концепцией отсроченного платежа, мурабаха была предложена для использования в качестве способа финансирования в тех случаях, когда клиент намерен приобрести товар. Таким образом, мурабаха финансирование не следует рассматриваться как идеальную исламскую модель финансирования или универсальным инструментом для всех видов финансирования. Это следует рассматривать как переходный шаг на пути к идеальной исламской системе финансирования основанной на мушарака или мудараба. Иными словами его применение должно быть ограничено теми областями, где мушарака или мудараба не может функционировать.

2. При предоставлений средств, уполномоченному лицу следует убедиться в том, что клиент действительно намерен приобрести товар, который может быть предметом мурабаха договора. Никогда не следует рассматривать договор формально, не имея реальной основы.

3. Мурабаха договор не используется для покрытия накладных расходов, оплаты счетов или погашения задолженности клиента, также не используется для покупки валюты.

4. Одно из главных условий для законности мурабаха договора, чтобы товар вступил в собственность банка физическое или конструктивное владение, прежде чем банк продаст товар клиенту на основе мурабаха сделки. Здесь должно присутствовать время, в котором риск по товару приобретает банк. Не имея товар в собственности или, не взяв на себя риск по товару, хотя и на короткое время сделка не является приемлемой по шариату и прибыль, получаемая от этой сделки, не является халяльной.

5. Лучший способ произвести мурабаха сделку это, когда банк сам приобретает товар непосредственно у поставщика, и после доставки продает его клиенту на основе мурабаха договора. Участие клиента в качестве агента (посредник) в приобретений товара от имени банка, делает договоренность сомнительной. Именно по этой причине некоторые Советы по надзору на соответствие шариату запрещают данный способ, кроме как в случаях, когда в принципе приобрести товар без посредника невозможно. Таким образом, агентское соглашение следует избегать, насколько это возможно.

6. Если в случае реальной необходимости, банк назначает клиента в качестве агента, чтобы приобрести товар от его имени, следует четко различать действия клиента (то есть в качестве агента и, как конечного покупателя). В качестве агента клиент является попечителем и не ответственен за какие-либо расходы, только если в случае мошенничества с его стороны, поскольку товар находится в его владении в качестве агента финансиста. После того как клиент приобрел товар в качестве агента, то он должен сообщить финансисту, о выполнении своих обязательств в качестве агента, и что он принял доставку приобретенного товара, и теперь он намерен сделать предложение банку о приобретений товара. Когда в ответ на это предложение, финансист дает свое согласие, продажа считается завершенной, и риск, связанный с имуществом передается клиенту в качестве покупателя. С этого времени клиент является заемщиком. Это необходимое требование мурабаха финансирования, которое никогда не может быть отменено. При описании концепций "мурабаха как способ финансирования" мы уже определили пять этапов по агентскому соглашению. Каждый из этих пяти этапов является необходимым и пренебрежение одного из этапов делает всю сделку неприемлемой.

Следует отметить, что мурабаха сделка граничит с кредитами, основанными на проценте и небольшое отступление от установленных процедур, приводит в запретную зону. Поэтому эта операция должна проводиться с соответствующим вниманием и не следует воспринимать требования шариата легкомысленно.

7. Две разные цены за наличный расчет и продажа в кредит допускается при условии, что эти два варианта, специально выбраны клиентом. Так как цена является фиксированной, она не может быть увеличена из-за несвоевременной оплаты, и не может быть уменьшена в случае досрочного погашения кредита.

8. Для того чтобы гарантировать, что покупатель будет выплачивать кредит своевременно, клиент может принять обязательство, что в случае задержки платежей по сделке, он выплатит определенную сумму в благотворительный фонд, утвержденный финансовым учреждением. Эта сумма может быть основана на годовых процентах, но все поступления должна быть израсходованы на благотворительные цели и ни в коем случае не должны составлять часть дохода учреждения.

9. В случае досрочного платежа, клиент не в праве требовать скидку. Однако учреждение, не делая скидку предварительным условием в договоре, по собственному усмотрению может оказать такую услугу.

8. Иджара

8.1. Введение

"Иджара" термин исламского фикха (права). Лексически означает "предоставлять в аренду". В исламской юриспруденции, понятие "иджара" используется для двух различных ситуаций. Во-первых, это означает "пользоваться услугами кого-либо за согласованную оплату, предложенную в качестве вознаграждения за услуги". Работодателя называют " муста`джир", работника "аджир".
Поэтому, если «А» нанял «В» в свой офис в качестве менеджера с ежемесячным окладом, то «А» муста`джир и «В» аджир. Аналогичным образом, если «А» нанял носильщика, чтобы перенести багаж в аэропорту, то «А» это муста джир, а портье - аджир, и в обоих случаях сделка между сторонами называется иджара. Этот тип иджара включает каждую сделку, где услуги кого-либо нанимаются кем-то другим. Это может быть врач, адвокат, учитель, рабочий или любое другое лицо, которое может предоставлять свои услуги. Каждого из них можно назвать «аджиром» в соответствии с терминологией по исламскому праву, и сторона, которая нанимает их услуги, именуется "муста`джиром", тем временем заработная плата аджира называется «уджра».

Ко второму типу иджара договоров относится пользование активом и имуществом, а не услугами человека. «Иджара» в данном смысле означает "передача в пользование того или иного имущества другому лицу в обмен на арендную плату от этой стороны". В данном случае термин «иджара» аналогичен английскому термину «лизинг». При этом лизингодатель именуется «му`джир», а арендатор «муста`джир» и арендная плата выплачиваемая лизингодателю, называется «уджра».

Оба вида «иджара» тщательно рассматриваются в литературе по исламской юриспруденции и каждая из них, имеет свой собственный набор правил. Но для целей настоящей книге, второй тип иджара является более актуальным, поскольку этот тип, в основном используется как форма инвестиций, а также как способ финансирования.

Правила иджара в случае лизинга, в значительной степени аналогичны правилам купли-продажи, поскольку в обоих случаях имеется перевод актива другому лицу за определенную плату. Единственное различие между договорами иджара и купли-продажи является то, что в последнем случае актив переходит в собственность к покупателю, а в случае иджара, имущество остается в собственности лица, передавшего, а лишь право на использование, переходит арендатору.

Таким образом, можно легко увидеть, что по своему происхождению "иджара" не является способом финансирования. Однако в силу определенных причин, и в частности, вследствие некоторых налоговых льгот, эта операция также используется в западных странах в целях финансирования. Вместо того чтобы использовать обычный процентный кредит, финансовые учреждения начали

предоставлять в лизинг некоторые виды оборудования для своих клиентов. Хотя, фиксируя арендную ставку на это оборудование, они рассчитывают общую стоимость на основе понесенных расходов при покупке этих активов и к этому прибавляют предусмотренный процент, который может претендовать на такую сумму в течение срока аренды. Рассчитанная таким образом итоговая сумма делится на общее количество месяцев срока аренды, и ежемесячная арендная плата устанавливается на этой основе.

Вопрос может ли сделка по лизингу использоваться в качестве способа финансирования по шариату, в зависимости от условий контракта. Как упоминалось ранее, лизинг это не способ финансирования. Таким образом, сделка по аренде всегда регулируются правилами шариата предусмотренными для иджара. Поэтому давайте обсудим основные правила, регулирующие арендные сделки, перечисленные в исламском фикхе (праве). После изучения этих правил, мы сможем понять, при каких условиях для целей финансирования используется иджара.

Хотя принципов и правил касательно иджара договора так много, что требуются отдельные тома книг для их всестороннего обсуждения, мы попытаемся в этой главе, обобщить только основные принципы, которые необходимы для правильного понимания характера сделки и, как правило, необходимы в контексте современной экономической практики. Здесь эти принципы отражены в виде кратких заметок, так что читатели могут использовать их для справок.

8.2. Основные правила лизинга

1. Лизинг представляет собой договор в соответствии, с которым владелец имущества при согласованных условиях передает его в пользование другому лицу.

2. Предмет лизинга, должен иметь ценную пригодность. Таким образом, вещи, не имеющие ценную пригодность вообще, не могут передаваться в аренду.

3. Необходимо для действительности договора аренды, чтобы право собственности арендованного имущества оставалось у продавца, и только право пользования переходило арендатору. Таким образом, все, что можно «списать» после использования не возможно передать в аренду. То есть, аренда не осуществляется в отношении денег, съедобных товаров, топливо, боеприпасов и т.п. Если предмет в сделке по аренде имеет такую характеристику, это считаться займом, и соответственно следует применять правила касающиеся сделки по кредиту. Любая арендная плата, взимаемая из недействительного лизинга, является начисленным процентом по кредиту.

4. Так как арендованное имущество остается в собственности лизингодателя, все обязательства по собственности несет арендодатель, а ответственность за пользованием имуществом несет лизингополучатель.
Пример:
«А» сдал в аренду свой дом «В». Налог на имущество оплачивает «А», а счета за воду, электричество и все расходы по эксплуатации дома покрываются «В», арендатором.

5. Срок аренды должен быть четко определен.

6. Арендатор не может использовать арендованное имущество для иных целей, кроме целей, указанных в договоре лизинга. Если в договоре нет пункта использования имущества, арендатор может использовать его для любых предназначенных целей. Однако если арендатор желает использовать объект не по назначению, ему следует получить разрешения арендодателя.

7. Лизингополучатель обязан возмещать лизингодателю ущерб, произошедший вследствие злоупотребления или халатности со стороны лизингополучателя.

8. Риски, связанные с объектом лизинга остаются на ответственности лизингодателя в течение срока аренды в том смысле, что любой ущерб или убыток, причиненный по не зависящим причинам от лизингополучателя, несет арендодатель.

9. Совместная собственность на имущество двух или более лиц может быть передана в аренду, а также доход от арендной платы следует распределять между всеми совладельцами пропорционально к соотношению их долям в собственности.

10. Совладелец собственности может передавать в аренду свою долю от имущества только совладельцам по этому имуществу, а не любому другому лицу.

11. Для действительности лизинга необходимо, чтобы предмет лизинга полностью был определен сторонами.

Пример:
«А» предложил «В», "Я сдаю вам в аренду один из моих двух магазинов". «В» согласился. Договор аренды является недействительным, пока магазин, предназначенный для передачи в лизинг, четко не определен и не идентифицирован.
Определение арендной платы

12. Арендная плата должна быть определена на момент заключения контракта на весь период аренды.
Допустимо, когда различные суммы арендной платы фиксированы на различных этапах в течение срока лизинга, при условии, что сумма арендной платы за каждый этап специально согласована во время осуществления сделки по аренде. Если арендная плата за последующие этапы срока аренды не определена или оставлена на усмотрение арендодателя, договор аренды не действителен.

Пример (1):
«А» сдает в аренду свой дом «В» на 5 лет. Арендная плата за первый год установлена - 20 000 тг. за один месяц, и решено, что аренда каждого последующего года будет увеличена на 10% относительно предыдущего года. Договор аренды является действительным.

Пример (2): В приведенном выше примере, «А» предъявляет условие в договоре, что арендная плата в размере 20 000 тг./месяц действительна только на первый год. Арендная плата за последующие годы, устанавливается ежегодно на усмотрение лизингодателя. Договор аренды является недействительным, поскольку арендная плата не известна.
Определение арендной платы на основе совокупных расходов, понесенных при приобретений актива владельцем как это обычно делается в финансовом лизинге не противоречат правилам шариата, если обе стороны согласны на такой способ расчета, при условии, что иные условия полностью удовлетворяют требования шариата.

14. Лизингодатель не может увеличить арендную плату в одностороннем порядке, и какие-либо соглашения на этот счет, являются недействительными.

15. Арендная плата или ее часть может выплачиваться заблаговременно до передачи актива арендатору, а сумма, оплаченная заранее, переходит в счет погашения арендной платы.

16. Срок аренды начинается с даты, когда предмет лизинга доставлен лизингополучателю, независимо от того, начал ли арендатор использовать имущество или нет.

17. Если предмет лизинга вышел из строя по причине поломки и т.д., и нет возможности восстановить функциональность имущества, договор аренды прекращается в тот день, когда выявлен такой случай. Однако если ущерб причинен из-за халатности арендатора, он обязан возместить лизингодателю остаточную стоимость имущества по состоянию на дату установления поломки.

8.3. Лизинг как способ финансирования

Как и мурабаха, изначально аренда не являлась финансированием. Это сделка предусматривает передачу в пользование имущества одного лица другому в течение согласованного периода на основе согласованных условий. Однако некоторые финансовые учреждения приняли лизинг в качестве способа финансирования вместо долгосрочного кредитования, основанного на проценте. Этот вид лизинга, известен как "финансовый лизинг", и имеет отличия, как от "операционного лизинга" так и множество отличий по сравнению с обычной сделкой по лизингу.
Когда в недалеком прошлом создавались беспроцентные финансовые институты, они обнаружили, что лизинг является признанным способом финансирования во всем мире. С другой стороны, они поняли, что лизинг удовлетворяет требования шариата, и ее можно использовать в качестве беспроцентного способа финансирования. Таким образом, исламскими финансовыми учреждениями лизинг принят в практику, но мало кто из них обращает внимание на тот факт, что "финансовый лизинг" имеет ряд характеристик больше схожих с процентным финансированием, чем с обычной лизинговой сделкой. Поэтому они начали использовать без каких-либо изменений те же типовые договора о лизинге, которые используют обычные финансовые учреждения, в то время как некоторые положения в таких договорах не являются соответствующими принципам шариата.

Как упоминалось ранее, лизинг не является способом финансирования в своем начале. Тем не менее, сделку можно использовать для финансирования, при соблюдении определенных условий. Не достаточно заменить слово "процент" на термин "аренда" или заменить термин "ипотека" на "арендный актива". Должна присутствовать существенная разница между лизингом и займом под проценты. Это возможно осуществить, только последовав за всеми исламскими правилами о лизинге, некоторые из которых уже упоминались в первой части настоящей главы. Чтобы быть более конкретным, некоторые основные различия между современным финансовым лизингом и лизингом, одобренные шариатом указаны ниже.

8.4. Предоставление в лизинг

В отличие от договора купли-продажи, соглашение в договоре иджара осуществляется на будущую дату. Таким образом, хотя форвардная продажа не допускается по шариату, допускается 'иджара' на будущий период, при условии, что арендная плата будет выплачиваться только после того, как лизинговое имущество доставлено арендатору.

В большинстве случаев 'финансового лизинга' арендодатель, т.е. финансовое учреждение, приобретает актив через самого арендатора. Арендатор приобретает актив от имени арендодателя, который выплачивает стоимость актива поставщику непосредственно, либо через арендатора. В некоторых договорах аренды период аренды начинается в тот день, когда арендодатель выплатил стоимость актива, независимо от того доставлен ли актив арендатору или нет. Это означает, что ответственность арендатора касательно арендной платы начинается до того, как арендатору осуществлена доставка актива. Это сделка не дозволена по шариату, поскольку здесь имеет место взимание арендной платы за деньги, предоставленные клиенту которые являются ничем иным как просто начисленным процентом.
Правильный порядок, в соответствии с шариатом, это то, что арендная плата взимается после доставки актива арендатору, а не со дня, когда выплачена стоимость актива. Если поставщик после получения полной стоимости просрочил доставку, арендатор не несет ответственности за арендную выплату в период просрочки.

8.5. Различные отношения сторон

Следует четко понимать, что, когда лизингополучатель вовлечен в приобретение актива предназначенного для сдачи в аренду, имеются два отдельных соглашения между учреждением и клиентом, которые вступают в силу один после другого. В первом случае, клиент является агентом учреждения по приобретению актива от имени последнего. На данном этапе отношения между сторонами, являются не чем иным как отношение принципала и его агента. Отношения в качестве лизингодателя и лизингополучателя еще не вступили в силу.

Второй этап начинается с момента, когда клиент принимает доставку актива от поставщика. На данном этапе вступают в силу отношения арендодателя и арендатора. Эти два этапа не должны смешиваться друг с другом. На первом этапе, клиент не может нести ответственность по обязательствам лизингополучателя. В

этот период, он несет ответственность только за выполнение функций агента. Но когда актив доставлен, он обязан выполнять свои обязательства в качестве лизингополучателя.

Тем не менее, существует разница между договорами по мурабаха и лизингу. В мурабаха, как уже отмечалось ранее, фактическая продажа происходит, после того как клиент примет доставку товара от поставщика, и также первое мурабаха соглашение является не достаточным для осуществления фактической продажи. Таким образом, после вступления во владение активом в качестве агента, он обязан сделать предложение банку о покупке. Продажа происходит, после того как банк примет предложение.

Процедура в лизинг иная, и немного проще. Участникам после осуществления доставки не нужно заключать договор аренды. Если учреждение, при назначении клиента своим агентом, согласовало сдать актив в аренду начиная со времени доставки, период аренды автоматический начинается в согласованный день без каких-либо дополнительных процедур. Есть две причины различного функционирования между договорами по мурабаха и лизингу:

Во-первых, необходимое условие для действительности сделки по купли-продажи, сделка должна быть осуществлена немедленно. Таким образом, продажа, отсроченная на более поздний срок, является недействительной по шариату. Но лизинг, возможно отсрочить на более поздний срок. Таким образом, предыдущее соглашение не является достаточным в случае сделки по мурабаха, но этого вполне достаточно в случае лизинга.

Во-вторых, основным принципом шариата является то, что никто не может претендовать на прибыль или доход, не предпринимая какого-либо риска. Применяя этот принцип к мурабаха договорам, продавец не может претендовать на прибыль по имуществу, за риски которого он ни на минуту не был ответственен. Поэтому, если первое соглашение в сделке по мурабаха считать достаточным для осуществления купли-продажи между клиентом и учреждением, тогда активы передаются клиенту на правах собственности одновременно, и продавец не вступает в риск по этим активам вообще. Именно поэтому в мурабаха договорах одновременная передача невозможна, так как после доставки следует произвести обмен оферты и акцепта.
В лизинге, однако, право собственности на актив остается у арендодателя в течение периода лизинга. Поэтому, если период аренды начинается с момента, когда клиент примет доставку, то это не нарушает принцип, упомянутый выше.

8.6. Расходы, связанные с собственностью

Так как арендодатель является собственником имущества, и он приобретает актив у поставщика через своего агента, он обязан возместить все расходы, понесенные в процессе приобретения и ввоза товаров в страну арендодателя. Следовательно, он несет ответственность за фрахтование и таможенное оформление т.д. Он может, конечно, включить все эти расходы в издержки и может принять эти расходы во внимание при установлении арендной платы, но принципиально, чтобы он был ответственен за эти расходы в качестве владельца активов. Любое соглашение,

противоречащее этому принципу, например обычный финансовый лизинг, не соответствует шариату.
Ответственность сторон в случае потери актива

Как отмечается в основных принципах лизинга, лизингополучатель несет ответственность за любой ущерб, причиненный в следствий его действий. На него также может быть возложена ответственность за амортизацию. Но на лизингополучателя не может быть возложена ответственность за форс-мажор. Соглашение по обычному "финансовому лизингу', как правило, не проводит различия между этими двумя ситуациями. В договоре аренды на основе исламских принципов, каждая ситуация должна рассматриваться отдельно.

8.7. Изменения арендных платежей в долгосрочных договорах

В долгосрочных договорах аренды устанавливается единая сумма арендной платы на весь период аренды, это условие в основном не в пользу арендодателя, так как время от времени ситуация на рынке меняется.
В этом случае лизингодатель имеет два варианта решения:

(a) он может заключить договор аренды с условием, что арендная плата будет увеличиваться в соответствии с определенной пропорцией (например, 5%) после определенного периода (например, одного года).

(b) он может заключить договор аренды на более короткий период, после которого стороны могут продлить договор аренды по взаимному согласию на новых условиях, с правом отказать в продлении срока, в этом случае арендатор обязан вернуть арендованное имущество обратно лизингодателю.

Эти два варианта допустимы для арендодателя в соответствии с классическими правилами исламского фикха. Однако некоторые современные ученые, позволили, в долгосрочной арендной сделке, привязать арендную плату к переменным величинам принятых в качестве ориентира, которые хорошо известны, четко ясны, и не вызывают споров. Например, допустимо в соответствии с этим доводом, что в случае увеличения налогов правительством по отношению к арендодателю, арендная плата будет увеличена в пределах той же суммы. Аналогичным образом одобрено, когда ежегодный прирост по арендной плате привязан к темпам инфляции. Поэтому, если есть увеличение инфляций на 5%, это также приводит к увеличению арендной платы на 5%. Исходя из того же принципа, некоторые исламские банки используют процентную ставку в качестве ориентира для определения суммы арендной платы. Они желают получать тот же доход по лизингу, как и обычные банки, которые выдают кредиты на основе процентов. Таким образом, они хотят связать арендные платежи с процентной ставкой и вместо установления определенной суммы арендных платежей, рассчитывают расходы на приобретение и желают получать арендные платежи равные к процентной ставке. Следовательно, соглашение предусматривает, что арендная плата будет равна процентной ставке или выше процентной ставки. Поскольку процентная ставка является переменной величиной, она не может быть определена на весь период арендной сделки. Таким образом, эти контракты используют

процентную ставку в определенной стране (например, LIBOR) в качестве ориентира для определения периодического увеличения арендной платы.

Эта договоренность подвергается критике по двум причинам:
Первое возражение, возникающее против то, что, сопоставляя арендные платежи с процентными ставками, сделка ни чем не отличается от финансирования основанном на проценте. Этому можно возразить, сказав, что как подробно обсуждалось в случае мурабаха договоров, здесь процентная ставка используется только в качестве ориентира. Как только иные требования шариата для законности арендной сделки должным образом выполнены, в договоре можно использовать любой ориентир для определения суммы арендных платежей. Основное различие между финансированием основанном на проценте и арендой не в сумме, подлежащей выплате банку или арендодателю. Основным отличием является то, что в случае аренды, арендодатель принимает на себя весь риск по предмету лизинга. Если активы повреждены во время периода лизинга, лизингодатель приобретает потери. Аналогичным образом, если лизинговое имущество выходит из строя не по причине лизингополучателя, лизингодатель не может претендовать на арендную плату, а в случае финансирования основанного на проценте, финансист, имеет право на получение процентов, даже если заемщик не получает дохода. Если сохранена эта основная разницу (т.е. арендодатель принимает на себя риск по предмету лизинга) сделку нельзя классифицировать как процентную операцию, даже, несмотря на то, что сумма арендной платы, требуемая от арендатора равна процентной ставке.
Таким образом, ясно, что использование процентной ставки лишь в качестве ориентира не делает договор недействительным. Однако желательно все время, избегать использования процента даже в качестве ориентира, так чтобы сделка, основанная на исламских принципах, полностью отличалась от неисламской сделки.
Второе возражение против этого механизма является то, что вариация процентной ставки неизвестна и арендная плата, связанная с процентной ставкой подпадает под понятие джахала и гарар которые не допускаются по шариату. Это одно из основных требований шариата, чтобы все аспекты в каждом контракте были известны сторонам, когда они заключают контракт. В сделке по аренде арендная плата взимается у арендатора, и поэтому она должна быть известна каждому участнику в самом начале договора аренды. Если мы установим арендную плату в соотношений к будущей процентной ставке, которая в свою очередь не известна, то также сумма арендной платы остается неизвестной. Это – неопределенность, т.е. джахала или гарар, которые делают сделку недействительной.
В ответ на это возражение, можно сказать, что джахала запрещена по двум причинам: Одна из причин это то, что джахала может привести к спору между сторонами. Эта причина в данном случае неприменима, поскольку обе стороны с взаимного согласия определили ориентир, который будет служить в качестве «точки отсчета» для определения арендной платы, и какая-либо сумма не была бы определена она будет приемлема для обеих сторон. Таким образом, нет причин для спора между ними.

Вторая причина запрещения джахалы то, что она ведет к непредвиденным потерям. Вполне возможно, что процентная ставка в конкретный период, увеличится до

неожиданного уровня в этом случае арендатор, несет большие потери. Также возможно, что процентная ставка уменьшится вплоть до неожиданного уровня, и в этом случае может пострадать лизингодатель. В целях снижения риска связанного с такими событиями, некоторыми современными учеными предложено, чтобы соотношение между арендной платой и процентной ставкой подвергалось ограничению. Например, можно предусмотреть в базовом договоре то, что сумма арендной платы по истечению определенного периода, будет изменена в соответствии с изменением процентной ставки, но не выше 15% или ниже чем 5% от предыдущей месячной арендной платы. Это означает, если процентная ставка увеличилась более чем на 15%, тогда арендная плата будет увеличена только на 15%. И наоборот, если уменьшение процентной ставки более чем 5% тогда арендная плата будет уменьшена не более чем на 5%.

8.8. Штраф за просроченные платежи

В некоторых соглашениях по финансовому лизингу, начисляется пеня в случае, если арендатор задерживает оплату арендных платежей. Шариат не оправдывает такие меры, если добавленная сумма переходит в доходы арендодателя. Причина в том, что арендная плата после наступления срока уплаты является долгом оплачиваемый лизингополучателем, и здесь следует соблюдать правила установленные для таких случаев. Денежные взыскания с заемщика за несвоевременные выплаты являются рибой, которая запрещена священным Кораном. Следовательно, арендодатель не может взимать дополнительную сумму в случае задержки арендной платы.

Однако чтобы избежать неблагоприятных последствий в результате неправомерного использования этого запрета, можно использовать другую альтернативу. Арендатора можно обязать, если он просрочит арендные платежи к установленному сроку, он будет обязан выплатить определенную сумму в благотворительных целях. Для этого банк/арендодатель может открыть благотворительный фонд, куда будут направляться эти средства и далее выделятся на благотворительные цели, включая выдачу беспроцентных кредитов нуждающимся лицам. Сумма задолженности лизингополучателя следующая на благотворительные цели может варьироваться в зависимости от периода просрочки платежа и может быть рассчитана на основе годовых процентов. Для этой цели договор аренды может содержать следующее положения:

"Арендатор обязуется, что в случае не выполнения обязательств по арендным платежам в соответствий графику погашения, он обязан выплатить сумму, рассчитанную на основе ...% годовых в благотворительный фонд, утвержденный лизингодателем, который будет использовать эти средства исключительно в благотворительных целях в соответствий с правилами шариата и ни в коем случае не будет рассматривать эти средства как часть дохода лизингодателя."
Эта мера, хотя и не возмещает лизингодателю издержки за просроченный период, но служит сильным сдерживающим фактором для лизингополучателя оперативно выплачивать арендные платежи.

Основание для таких обязательств в отношений лизингополучателя, и невозможность арендодателя выдвигать какие-либо штрафные санкций в своих

собственных интересах детально обсуждаются в полном объеме в главе 'мурабаха' настоящей книги.

8.9. Расторжение арендного договора

Если арендатор не выполняет обязательства по договору, арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако если нет нарушения со стороны арендатора без взаимного согласия, не возможно расторгнуть арендный договор. В некоторых соглашениях по "финансовому лизингу", арендодателю предоставляется неограниченное право расторгнуть договор в одностороннем порядке по его усмотрению. Это также противоречит принципам шариата.

В некоторых соглашениях по "финансовому лизингу" в случае прекращения арендного договора, даже по желанию арендодателя, арендная плата за оставшийся период аренды уплачивается арендатором. Это условие, очевидно, противоречит шариату и принципам равенства и справедливости. Основная причина для вставки таких условий в договор аренды является то, что основополагающая концепция, лежащая в основе договора является предоставление процентного займа в виде лизинга.

Естественно, что такие условия не приемлемы по шариату. Логическим следствием прекращения арендного договора является то, что активы должны быть переданы обратно лизингодателю. Арендатор обязан выплатить арендную плату до даты прекращения арендного договора. Если прекращение осуществлено по причине безответственности арендатора, он обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если таковые имеются. Но не возможно принудить арендатора к оплате арендных платежей по оставшемуся периоду.

8.10. Страхование имущества

Если арендуемое имущество застраховано в соответствии с исламским методом «такафул», этот процесс осуществляться за счет арендодателя, а не за счет арендатора которое практикуется в нынешних договорах по «финансовому лизингу».
Остаточная стоимость лизингового актива

Другая важная особенность современного «финансового лизинга» это то, что после истечения срока аренды, лизинговое имущество обычно передается лизингополучателю. Так как арендодатель уже получил стоимость актива вместе с дополнительной прибылью, которая, как правило, равна сумме процентов, которые обычно начисляются при выдачи кредита за этот же период, то лизингодатель не имеет дальнейшего интереса к предмету лизинга. С другой стороны, лизингополучатель желает получить имущество после истечения срока лизингового периода.

По этим причинам, предмет лизинга, как правило, передается лизингополучателю по окончанию срока аренды, либо бесплатно или по номинальной цене. В целях обеспечения передачи актива арендатору, иногда в договоре аренды на этот счет имеется специальное положение. Иногда это условие не указано в договоре прямо,

однако, между сторонами принято, что право на актив будет передано арендатору в конце периода аренды.

Это условие, будь то прямое или косвенное, не соответствует принципам шариата. Есть хорошо установленная норма исламской юриспруденций, что одна сделка не может быть связана с другой сделкой, так чтобы быть предварительным условием к этой сделке. Здесь условие о передаче имущества в конце периода является необходимым условием для совершения сделки по аренде, которая не позволена по шариату.

Исходное положение в шариате это то, что активы должны оставаться в собственности лизингодателя, а по истечению срока лизинга, лизингодатель имеет право получить активы обратно, или продлить арендный договор или заключить договор аренды с другим участником, либо продать это имущество арендатору или любому другому лицу. Арендатор не может принуждать продать ему актив по номинальной цене, и такое условие не может выдвигаться арендодателю в договоре по лизингу.

Но по истечению периода аренды, арендодатель по собственному желанию может передать актив арендатору в качестве дара или продать. Однако некоторые современные ученые, с учетом потребностей исламских финансовых учреждений предложили альтернативу. Они утверждают, что иджара договор не должен содержать условие дарения или продажи в конце периода аренды. Однако арендодатель вправе в одностороннем порядке принять обязательство о продаже предмета лизинга лизингополучателю в конце периода аренды. Это обязательство является обязательным только по отношению к лизингодателю. Принцип, присутствующий в обязательстве, по их мнению, это то, что одностороннее обещание заключить договор в будущем разрешен в соответствии, с которым обещавший обязан выполнить обещание, но кредитор не должен заключать этот договор в обязательном порядке. Это означает, что арендатор имеет право выкупа, которое он может осуществить. Однако если он хочет воспользоваться своим правом выкупа, то обещавший не может отказать, потому что он обязан своим обещанием. Таким образом, ученые полагают, что лизингодатель, после заключения договора лизинга, может заключить отдельное одностороннее обещание, которым он обязуется, в случае, если арендатор выплатит всю сумму и желает приобрести актив по указанной взаимоприемлемой цене, лизинговое имущество будет передано арендатору.

Так как обещание подписано арендодателем, он обязан его выполнить, и арендатор может воспользоваться своим правом выкупа в конце периода договора, если он выплатил сумму аренды полностью согласно договору аренды. Кроме того, также учеными дозволено, когда вместо договора купли-продажи, лизингодатель подписывает отдельное обещание подарить предмет лизинга лизингополучателю в конце периода аренды, при условии выплаты всех сумм арендных платежей. Этот механизм называется «иджара уа иктина». Он одобрен большим числом современных ученых и широко используется исламскими банками и финансовыми учреждениями. Действительно это соглашение при соблюдении двух основных условий:

Во-первых, договор иджара не должен быть обусловленным подписанием этого обещания по продаже или дарению, но обещание можно оформить отдельным документом.
Во-вторых, обещание должно быть односторонним и обязательным только по отношению обещавшему. Не должно осуществляться двустороннее обещание, обязывающее обе стороны, поскольку в этом случае осуществляется полный договор на более поздний период, который не допускается в случае продажи или дарения.

8.11. Субаренда

Если лизинговое имущество используется отдельно разными лицами, арендатор не может осуществить субаренду арендованного актива, кроме как с прямого разрешения арендодателя. Если арендодатель позволяет арендатору передать актив в субаренду, то он может осуществить эту сделку. Все школы исламской юриспруденции единодушны относительно правомерности субаренды, если арендная плата, требуемая от субарендатора равна или меньше арендной платы выплачиваемой первоначальному лизингодателю. Тем не менее, существуют разные мнения в случае, если арендная плата от суб-арендатора выше первоначальной арендной платы. Имам аш-Шафи'и и некоторые другие ученые позволяют эту операцию и считают, что субарендодатель может использовать излишки полученные от суб-арендатора. Эту точку зрения предпочитает также имам Ханбали. С другой стороны имам Абу Ханифа считает, что этот остаток средств полученные от суб-арендатора в данном случае не является допустимым для суб-арендодателя, и он должен передать излишки на благотворительную деятельность. Однако если суб-лизингодатель к арендованному имуществу, добавил какое-либо имущество или передал в аренду в валюте, отличной от валюты, в которой он выплачивает арендные платежи первоначальному арендодателю, он может требовать более высокую ренту с субарендатора и может использовать полученную в результате прибыль.

Хотя мнение имама Абу Ханифа воплощает в себе больше мер предосторожности, которые должны быть предприняты, в случае необходимости можно следовать мнениям имамов Шафи'и и Ханбали, потому что нет прямого запрета в Священном Коране или сунне.

8.12. Передача лизинга

Арендодатель может продать арендованное имущество третьему лицу в соответствии с которым отношения арендодателя и арендатора устанавливаются между новым владельцем и арендатором. Однако, продажа лизинга (без передачи собственности на предмет лизинга) недопустима.

Разница между двумя ситуациями в том, что в последнем случае право собственности на актив не передается правопреемнику, но он получает право на получение арендных платежей. Такой вид передачи лизинга допускается по шариату только там, где нет денежного взимания с правопреемника для этой цели. Например, лизингодатель может передать свои права требовать арендные платежи у арендатора своему сыну, или своему другу в виде подарка. Кроме того, он может

передать это право своим кредиторам в счет своего долга. Но если арендодатель желает продать это право за фиксированную цену, это не допустимо, так как в этом случае деньги (сумма арендной платы) продаются за деньги. В противном случае это равнозначно сделке по рибе, следовательно, запрещено.

8.13. Секьюритизация иджара

Соглашение иджара имеет хороший потенциал секьюритизаций, который может помочь в создании вторичного рынка для финансистов на основе иджара. Поскольку арендодатель в иджара владеет арендованным имуществом, он может продать актив, полностью или частично, третьей стороне, которые могут приобрести их и могут заменить продавца в отношении прав и обязанностей арендодателя в соответствии с приобретенным активом.

Таким образом, если лизингодатель, после вступления в иджара договор, желает восстановить свои расходы по приобретению активов с прибылью, в этой связи, он может продать предмет лизинга полностью или частично, одному или нескольким лицам. В последнем случае, приобретение долей в активах для каждого человека можно засвидетельствовать сертификатом, который можно назвать иджара сертификат. Этот сертификат представляет долевую собственность владельцев в лизинговом предмете. Поскольку активы уже предоставлены в аренду арендатору, аренда продолжается с новым владельцем, каждый из обладателей данного сертификата имеет право на часть арендной платы в соответствии с его долей в собственности на активы. Таким же образом распределена обязанность арендодателя. В случае полной непригодности имущества, владелец сертификата несет потери в пределах приобретенной собственности. Эти сертификаты, являясь доказательством на долевую собственность в материальных активах, могут свободно торговаться на рынке, и могут служить в качестве легко конвертируемого в реальные деньги инструмента. Таким образом, сертификаты могут помочь в решении проблемы управления ликвидностью, с которыми сталкиваются исламские банки и финансовые учреждения.

Однако следует помнить, что сертификат должен представлять собственность на неделимую часть актива со всеми правами и обязанностями. Недопонимая эту базовую концепцию, некоторые пытаются выдавать иджара сертификаты, которые предоставляют владельцу право требовать определенную сумму только по арендным платежам без передачи прав собственности на эти активы. Это означает, что владелец такого сертификата не имеет никакого отношения к лизинговому имуществу вообще. Его единственное право это доля в арендных платежах, полученная от арендатора. Такой вид секьюритизаций не одобрен по шариату. Как было объяснено ранее в этой главе, арендные платежи это долг оплачиваемый лизингополучателем. Долг или ценная бумага представляющая долг не является оборотным инструментом по шариату, потому что это торговля деньгами или денежными обязательствами, которое не допускается, кроме как на паритетной основе, и если торговля такими инструментами осуществляется на паритетной основе, тогда это противоречит самой цели секьюритизаций. Таким образом, этот тип иджара сертификатов содействует созданию вторичного рынка. Поэтому, необходимо, чтобы иджара сертификаты представляли реальную собственность на лизинговое имущество, а не только право на получение ренты.

8.14. Хэд-лизинг

Другая концепция, разработанная в современном лизинговом бизнесе это "хэд-лизинг". В этом соглашении арендатор субарендует имущество нескольким субарендаторам. Затем он приглашает другие стороны принять участие в его бизнесе, предоставив им долю от арендных платежей, получаемых от субарендаторов. Для принятия участия в получении доли от арендных платежей, арендатор взимает определенную сумму. Этот механизм не соответствует принципам шариата. Причина очевидна. Арендатор не является собственником имущества. Он всего лишь имеет право пользование имуществом. Это право он передает субарендаторам после заключения с ними договора субаренды. В это время ему не принадлежит право пользование этим имуществом. То, что ему принадлежит по праву это получение ренты. Далее он переводит часть этого права другим лицам. Но уже подробно разъяснено, что это право не может быть предметом сделки, потому что здесь имеет место продажи дебиторской задолженности, т.е. не равноценный обмен денег, который запрещен священным Кораном и сунной. Таким образом, эта концепция не является приемлемой.
Таковы некоторые основные черты «финансового лизинга», которые не соответствуют требованиям шариата. При использовании лизинга как исламского способа финансирования, следует избегать этих недостатков.

Список возможных недостатков в договоре аренды не ограничивается тем, что упомянуто выше, это только основные ошибки, обнаруженные в различных соглашениях, и в этой главе обобщены только основные принципы исламского лизинга. Исламский договор аренды должен соответствовать всем этим правилам.

9. Салам и истисна

9.1. Введение

Одно из основных условий для действительности продажи по шариату это то, что товар (предназначенный для продажи) должен находиться в физической или конструктивной собственности продавца. Это условие имеет три составляющих принципа:

Во-первых, товар должен материально существовать, следовательно, товар который не существует материально на момент продажи, не может быть продан.

Во-вторых, продавец должен приобрести товар в собственность. Поэтому, если товар существует материально, но продавец не является собственником, он не может продать его кому-либо.

В-третьих, просто иметь товар в собственности недостаточно. Товар должен войти в физическое или конструктивное владение продавца. Если продавец владеет товаром, но ему еще не доставили товар или пока не передали через его агента, то он не может продать его.
Есть только два исключения от общих принципов шариата. Один из них «салам», а другой «истисна». Оба являются договорами купли-продажи со своей спецификой,

и в настоящей главе разъясняется концепция этих двух видов купли-продажи и как можно использовать их для финансирования.

9.2. Значение салам

Салам является договором купли-продажи, согласно которому продавец обязуется предоставить конкретно определенные товары покупателю в будущем в обмен на полную оплату товаров на месте.

В этой сделке стоимость оплачена наличными, но поставка закупленных товаров отсрочена. Покупателя называют "рабб-ус-салам", продавца "муслам илаих", наличную оплату "ра'с-уль-маль" и приобретенные товары квалифицируются как "муслам фих", но для удобства, позвольте использовать синонимы на русском языке.

Салам разрешен святым пророком,ﷺ при определенных условиях. Основной целью этой сделки являлось удовлетворение потребностей мелких фермеров, которые нуждались в деньгах для выращивания сельскохозяйственных культур и чтобы прокормить свои семьи до уборки урожая. После запрещения рибы они не могли занимать ростовщические кредиты. Таким образом, им было разрешено заранее продавать сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, купцы в Аравии обычно занимались экспортом товаров в другие местности, и импортом некоторых товаров на родину. Им требовались денежные средства для проведения этого вида бизнеса. Они также не могли занимать у ростовщиков после запрещения рибы. Следовательно, им также было позволено реализовывать товары заранее. После получения наличных денежных средств, они легко проводили вышеупомянутый бизнес.

Салам выгодна для продавца, поскольку он получает стоимость заранее и также это выгодно для покупателя, потому что обычно, стоимость товара в договоре салам ниже рыночного. Допустимость договоров салам это исключение из общих правил запрещающие форвардные продажи и, следовательно, такие договора требуют четких условий. Эти условия приводятся ниже:

9.3. Условия салам

1. Прежде всего, необходимо для действительности салам договора, чтобы покупатель выплатил продавцу стоимость товара в полном объеме на момент осуществления продажи. Это правило необходимо потому, что в случае отсутствия полной оплаты, сделка будет равнозначна продаже долговых обязательств в долг, которая запрещена святым пророкомﷺ. Кроме того, основная идея допустимости салам договора это мгновенно удовлетворить потребности продавца. Если стоимость не выплачена в полном объеме, то и не достигнута основная цель сделки. Таким образом, все мусульманские правоведы единодушны в том, что в договорах типа "салам" необходимо полностью выплатить стоимость товара. Однако имам Малик считает, что продавец может предоставить для покупателя уступку в два-три дня, однако уступка не должна быть частью соглашения.

2. Салам соглашение можно заключить только по тем товарам, качество и количество которых указаны точно. Товары, качество или количество которых не возможно определить подробным описанием, не реализуются с помощью договора

"салам". Так, например, драгоценные камни не могут быть предметом договора салам, так как каждое изделие из драгоценных камней, как правило, отличается от другого как по качеству, так и по размеру или весу и обычно невозможно осуществить детальную спецификацию.

3. Салам договор не осуществляется на определенный товар или продукцию определенного участка земли или фермы. Например, если продавец обязуется поставить пшеницу определенного фермерского поля, или плод конкретного дерева, салам не действителен, так как есть вероятность того, что урожай этого конкретного участка земли или плод этого дерева придет в непригодность до доставки, и, учитывая такую возможность, доставка остается неопределенной. То же правило применимо к любому товару поставка, которой не определена.

4. Необходимо, дать детальную характеристику по качеству товаров (предназначенные для приобретения по договору салам) не оставляя двусмысленности которое может привести к спору. Все возможные детали по отношению к этим товарам должны быть четко указаны.

5. Необходимо также, чтобы количество товара, было согласовано ясно. Если товар измеряется с помощью весов то, его вес должен быть определен, и если количество товара определяется с помощью другой единицы измерения, ее точная мера должна быть известна. Так или иначе, товары для определения количества, которых используются весы не возможно использовать иные единицы измерения и наоборот.

6. В договоре следует указать точную дату и место доставки.

7. Салам договор не осуществляется на товары, которые следует предоставить на месте. Например, при покупке золота в обмен на серебро, необходимо, в соответствии с шариатом, доставить оба товара одновременно. В этом случае сделку не возможно провести через договор салам. Аналогичным образом, если пшеница обменивается на ячмень, для действительности сделки необходимо осуществить одновременную доставку. Поэтому договор салам и в этом случае не допускается. Все мусульманские правоведы единодушны по принципу, что салам договор не действителен, если все эти условия не соблюдены полностью, поскольку они основаны на хадисах пророка ﷺ самый известный хадис в этом контексте тот, в котором святой пророк ﷺ сказал:

من اسلف في شيي فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم الى اجل معلوم

"Тот, кто желает вступить в договор салам, должен осуществить салам соглашение, указав меру, указав вес и указав дату доставки" (примерный перевод)

Однако существуют некоторые другие условия, которые выдвинуты различными школами исламской юриспруденции. Некоторые из этих факторов рассматриваются ниже:

(1) необходимо, по школе имама Абу Ханифа, чтобы товар (по которому осуществляется салам договор) был доступен на рынке с самого начало договора до времени поставки. Поэтому, если товар не доступен на рынке в момент заключения договора, салам не может быть осуществлен в отношении этого товара, хотя и ожидается, что товар будет доступен на рынке на момент доставки.

Однако остальные три школы фикха (т.е. имамов аш-Шафи'и, Малик, и Ханбали) считают, что наличие товара на момент заключения договора не является условием для действительности "салам". То, что необходимо, по их мнению, это чтобы товар был доступен в момент доставки. Эту точку зрения можно принять в нынешних обстоятельствах.

(2) необходимо, в соответствии с имамами Абу Ханифа и Ханбали, установить время доставки, по крайней мере, через один месяц от даты соглашения. Если время доставки установлено ранее, чем один месяц, салам договор недопустим. Их аргументом является то, что салам договор разрешен с учетом нужд и потребностей мелких фермеров и торговцев, и им следует предоставить достаточно возможностей для приобретения товаров. Они могут быть не в состоянии предоставить товар до одного месяца. Кроме того, стоимость по договору салам, как правило, ниже, чем рыночная цена на момент заключения договора. Эта скидка в цене может быть оправдана только тем, что товары доставят по истечению определенного периода, который обоснованно влияет на цену. Период менее одного месяца, как правило, не влияет на цену. Таким образом, минимальный срок поставки должен быть не менее одного месяца. Имам Малик поддерживает мнение о том, что в договоре "салам" должен быть минимальный срок. Вместе с тем он считает, что период сделки не должен быть меньше пятнадцати дней, так как рыночные цены могут измениться в течение двух недель. Это мнение, однако, не поддерживается другими правоведами, такими как имам аш-Шафи'и и некоторые правоведы мазхаба имама Абу Ханифа. Они говорят, что святой пророк ﷺ не указывал минимальный срок действия договора "салам". Единственное условие, в соответствии с хадисами, это то, что следует четко определить время доставки. Таким образом, минимальный срок не может быть предписан. Стороны с обоюдного согласия могут установить любую дату доставки. Эта точка зрения представляется предпочтительным в нынешних обстоятельствах, потому что святой пророк ﷺ не рекомендовал минимальный период. Правоведы рекомендуют разные периоды, которые варьируются от одного дня до одного месяца. Очевидно, что они делают это, исходя из целесообразности и с учетом нужд и потребностей несостоятельных продавцов. Кроме того, больше всех нужнее продавцу, устанавливать ранние сроки. То, что касается цен, то это не является необходимым условием по договору салам, чтобы цена была всегда ниже, чем рыночная цена на этот день. Продавец сам является лучшим защитником своих интересов, и если он принимает более раннюю дату доставки по собственному желанию, нет никаких причин запрещать делать этого. Некоторые современные правоведы приняли эту точку зрения, так как это мнение больше подходит для современных операций.

9.4. Салам как способ финансирования

Как видно из выше сказанного салам соглашение допустимо по шариату для удовлетворения потребностей фермеров и торговцев. Поэтому в основном это способ финансирования малых фермеров и торговцев. Этот способ финансирования могут использовать современные банки и финансовые учреждения, особенно для финансирования сельскохозяйственного сектора. Как отмечалось ранее, цена товара в договоре салам может устанавливаться на более низком уровне, чем рыночная цена на тот день. Таким образом, разница между ценами может являться прибылью для банков и финансовых учреждений. В целях обеспечения обязанности продавца доставить товар в согласованный срок, можно также обязать продавца предоставить обеспечение по сделке, которое может быть в виде гарантии или в форме залога. В случае просрочки доставки, гарант обязан доставить тот же товар, или если есть залог в форме имущества, покупатель/банк может продать заложенное имущество и вырученные от продажи средства использовать либо для приобретения необходимых товаров, либо для восстановления заранее выплаченных средств.

Единственная проблема в договоре салам, которая может волновать современные банковские и финансовые учреждения в том, что они будут получать определенные товары от своих клиентов, но не смогут выручить за них свои деньги. Будучи знакомые только с финансовыми операциями, кажется большим делом для них приобретать различные товары от различных клиентов, и продавать их на рынке. Банк не может реализовать эти товары, прежде чем товары фактически не будут доставлены, потому что это запрещено по шариату.
Но когда мы говорим об исламских методах финансирования, следующий базовый момент никогда не следует игнорировать. Дело в том, понятие, что финансовое учреждение занимается только финансовыми вопросами чуждо исламскому шариату. Если эти банки хотят получать халяль прибыль, они должны иметь дело с товарами тем или иным путем, потому что прибыль, полученная только путем предоставления займов, не допускается по шариату. Таким образом, создание исламской экономики требует коренного изменения концепций о финансовых учреждениях. Они должны установить специальное звено, занимающееся товарами. Если будет установлено специальное звено, не будут возникать трудности при приобретении товаров с помощью договора салам и их последующая реализация на спотовых рынках.

Однако есть два способа извлечения выгоды из договора "салам".

Во-первых, после приобретения товара по договору салам, финансовые учреждения могут реализовать товар по параллельному салам договору на аналогичную дату доставки товара. Так как салам период во второй (параллельной) сделке короче, цена может быть немного выше, чем цена в первой сделке, и разница между ценами будет прибылью банка. Чем короче период салам контракта, тем выше цена, тем больше прибыли. Таким образом, банки могут управлять своими портфелями краткосрочного финансирования.

Во-вторых, если параллельный салам договор не представляется возможным осуществить по тем или иным причинам, банк может получить обещание приобрести у третьей стороны. Это обещание следует заключать в одностороннем

порядке. Будучи лишь обещанием, а не фактической продажей, покупателю не придется выплачивать стоимость заранее. Таким образом, можно установить более высокую цену, и как только товар получен банком, он будет продан третьей стороне по заранее оговоренной цене, в соответствии с условиями обещания.

Иногда предлагается третий вариант, на дату поставки товар продается обратно продавцу по более высокой цене. Но это предложение не соответствует требованиям шариата. Никогда не одобрялось шариатом, чтобы купленный товар продавался обратно продавцу до того как покупатель примет доставку этого товара, и если это осуществлено по более высокой цене, то сделка равнозначна рибе, которая полностью запрещена. Даже если он и осуществит обратную продажу после принятия товара, покупатель не может заранее заключить параллельный салам договор с тем же продавцом на момент действия первоначальной продажи. Таким образом, это предложение не приемлемо вообще.

9.5. Некоторые правила параллельного салам договора

Поскольку современные исламские банки и финансовые учреждения используют инструмент параллельный салам, необходимо соблюдать некоторые правила для действительности этого соглашения:

1. В соглашении по параллельному саламу, банк входит в два различных контракта. В одном из них, банк - покупатель, а во втором банк - продавец. Каждый из этих контрактов должен быть независимым. Они не могут быть связаны таким образом, чтобы права и обязанности одного контракта зависели от прав и обязанностей параллельного договора. Каждый договор должен иметь свое собственное действие и осуществление договора не должно зависеть от иного договора.

Например, если «А» приобрел у «В» 1000 мешков пшеницы по договору салам с поставкой на 31 декабря, «А» может заключить параллельный салам контракт с «С» с доставкой 1000 мешков пшеницы на 31 декабря. Но в договоре по параллельному салам контракту поставка пшеницы к «С» не может быть обусловлена с принятием поставки от «В». Поэтому, даже если «В» не управится доставить пшеницу на 31 декабря, «А» обязан доставить 1000 мешков пшеницы к «С». Он может предъявлять любые претензий к «В», но он не может снят ответственность за доставку пшеницы к «С».
Аналогичным образом, если «В» доставил бракованные товары, которые не соответствовали согласованным спецификациям, «А» все же обязан предоставить товар «С» в соответствии с согласованными техническими или иными характеристиками.

2. Параллельный салам договор допускается к заключению только с третьей стороной. Продавец в первом договоре не может быть покупателем в параллельном салам договоре, так как это контракт обратного выкупа, который не допускается шариатом. Даже если покупатель во втором контракте является отдельным юридическим лицом, но полностью принадлежит продавцу первого договора, соглашение не правомерно по шариату, потому что в практическом плане это равнозначно соглашению об обратном выкупе. Например, «А» купил 1000 мешков пшеницы по договору салам от «В» (акционерное общество). «В» имеет дочернее

предприятие «С», которое является отдельным юридическим лицом, однако полностью принадлежит «В». «А» не может заключить параллельный салам контракт с «С». Однако, если «В» только частично владеет компанией «С», то «А» может заключить параллельный салам контракт с компанией «С», даже если между «В» и «С» есть общие акционеры.

9.6. Истисна`

'Истисна`' второй вид договора купли-продажи, где товар передается до его материального происхождения. Это означает, по заказу производителя производство конкретного товара для покупателя. Если завод-изготовитель обязуется произвести товар для покупателя из материалов производителя, осуществляется сделка истисна`. Но необходимо для действительности договора истисна`, чтобы стоимость устанавливалась с согласия сторон, и были определены все необходимые спецификаций по товару (предназначенного для производства).
Договор истисна` создает моральное обязательство на производителя произвести товары, но прежде чем начнутся работы, любая из сторон может расторгнуть договор после предоставления уведомления. Однако после того как производитель приступил к работе, договор не возможно аннулировать в одностороннем порядке.

9.7. Разница между договорами истисна и салам

Принимая во внимание характеристику договора истисна` есть некоторая разницу между договорами "истисна`" и "салам", которые приводятся ниже:

(I) Предметом договора истисна` всегда является товар, который требует его производства, а договор салам можно заключить на любой товар, неважно, есть ли необходимость производства или нет.

(II) Необходимо для договора салам, выплатить полную стоимость товара предварительно, в то время как это условие не является необходимостью в договоре истисна`.

(III) В рамках контракта салам, не возможно аннулировать договор в одностороннем порядке, в то время как в договоре истисна` можно отменить сделку до начала производства заказанного товара.

(IV) время доставки является неотъемлемой частью договора купли-продажи типа салам, в то время как это не является необходимым условием в договоре истисна.

9.8. Разница между договорами истисна` и иджара

Следует также иметь в виду, что производитель, по договору истисна`, обязуется произвести необходимые товары, используя собственные материалы. Таким образом, сделка означает, что изготовитель должен приобрести необходимые материалы для изготовления, заказанного товара. Если материалы предоставляет заказчик, а производитель вкладывает лишь свой труд и навыки то это сделка не относится к типу истисна`. В этом случае это иджара сделка, в соответствии с которым используют услуги кого-либо за согласованную плату, предложенную в качестве вознаграждения за услуги.

Когда необходимые товары уже изготовлены, продавец должен представить их покупателю. Но есть разница во мнениях среди мусульманских правоведов, имеет ли покупатель право отказаться от товара на данном этапе. Имам Абу Ханифа считает, что он может использовать «право предварительного осмотра» (хияр-ур-ру'яах), поскольку истисна` является договором купли-продажи и если кто-либо покупает вещь, которую не видел, он имеет возможность отменить продажу, осмотрев товар. Тот же принцип применяется также к договору истисна`.

Однако имам Абу Юсуф утверждает, что если товар соответствует спецификациям согласованным между сторонами на момент заключения договора, покупатель обязан принять товар и он не может использовать «право предварительного осмотра». Эта точка зрения была предпочтена правоведами Османской империи, и правила школы ханафитов составлены в соответствии с этой точкой зрения, поскольку это ущербно в контексте современной торговли и промышленности, когда производитель использует все свои ресурсы для подготовки необходимых товаров, а покупатель отменяет продажу без объяснения причин, хотя товары находятся в полном соответствии с требуемыми спецификациями.

9.9. Время доставки

Как отмечалось ранее, не является необходимым условием в договоре истисна`, устанавливать сроки доставки. Тем не менее, покупатель может установить максимальные сроки доставки. Это означает, если завод-изготовитель задерживает поставку на назначенное время, покупатель не обязан принимать товар и выплачивать стоимость. Для гарантирования доставки товара в течение указанного периода, некоторые современные соглашения такого рода содержат условие о штрафной неустойке в том случае, если производитель задерживает доставку к установленному сроку, то он обязан выплатить штраф, который рассчитывается на ежедневной основе. Может ли такое условие о неустойке быть включено в договор истисна` в соответствии с шариатом? Хотя классические правоведы, похоже, замалчивают этот вопрос во время обсуждения договора истисна`, они позволяют аналогичные условия в случае иджара. Они утверждают, если кто-либо нанимает услуги по пошиву одежды, то плата может изменяться в зависимости от времени доставки. Наниматель может сказать, что он выплатит 10 000 тг. в случае если портной изготовит одежду в течение одного дня и 8 000 тг. в случае, если он изготовит их через два дня. По той же аналогий, стоимость в договоре истисна` может вирироваться в зависимости от времени доставки, и это будет допустимо, если это согласовано между сторонами, что в случае задержки доставки, то стоимость товара должна быть уменьшена на определенную сумму/сутки.

9.10. Истисна` как способ финансирования

Договор истисна` можно использовать для финансирования в определенных операциях, особенно в секторе финансирования недвижимости. Если клиент имеет собственный участок земли, и ищет финансирование для строительства жилья, банк может предоставить средства на основе истисна` для строительства жилья на этом участке, и если клиент не имеет участка земли, но желает купить его, банк может предоставить ему построенный дом на определенном участке земли.

Поскольку не является необходимым условием по договору истисна`, выплачивать стоимость авансом, также не является необходимым условием выплачивать стоимость товара в момент доставки (расчет может быть произведен в любое время в соответствии с соглашением сторон), поэтому, срок платежа может быть установлен по усмотрению сторон. Также платеж можно осуществить в рассрочку. С другой стороны, не обязательно чтобы сам банк занимался строительством дома. Банк может заключить параллельный договор истисна` с третьей стороной, или прибегнуть к услугам подрядчика (кроме клиента). В обоих случаях банк может рассчитать стоимость и установить приемлемую цену по истисна` договору. Клиент может начать выплачивать рассроченные платежи, в данном случае, со дня заключения договора истисна` сторонами, и может продолжать в ходе строительства, а также после передачи жилья клиенту. В целях обеспечения уплаты рассроченных платежей, право собственности на недвижимость или участок земли, либо любое другое имущество клиента может быть предоставлено банку в качестве обеспечения, пока клиентом не будет выплачен последний взнос.

Банк, в этом случае несет ответственность за строительство дома, в полном соответствии с детализированными спецификациями в соглашении. В случае любых разногласий, банк осуществляет дополнительное строительство дома, которое необходимо для приведения жилья в соответствии с условиями контракта, на собственные расходы.

Инструмент истисна` может также аналогично использоваться для финансирования проектов. Если клиент желает на своем заводе установить производственное помещение с кондиционерами, и помещение следует изготовить, банк может приступить к подготовке помещения по договору истисна` в соответствии с вышеупомянутой процедурой. Аналогичным образом, договор истисна` можно использовать для строительства мостов или дорог.

Современные ПУП (приобретение, управление и передача) соглашения могут также быть формализованы на основе договора истисна`. Если правительство намерено построить автобан, можно заключить договор истисна` со строителем. Стоимость по договору истисна`, в этом случае может быть оплачена в виде предоставления прав для строителя управлять автобаном и взимать плату на определенный период.

10. Исламский инвестиционный фонд

10.1. Введение

Термин "исламский инвестиционный фонд" в этой главе, означает общий пул, где инвесторы вкладывают свободные денежные средства в виде инвестиций с целью получения халяльной прибыли в строгом соответствии с предписаниями шариата. Вкладчики фонда могут получить документ, удостоверяющий вложенные средства и предоставляющий право на фактическую пропорциональную прибыль фонда. Эти документы можно назвать "сертификаты", "акций", "паи", но соответствие шариату, всегда осуществляется с учетом двух основных условий:

Во-первых, вместо фиксированной прибыли, должна начисляться пропорциональная прибыль, фактически полученная фондом. Таким образом, ни основной капитал, ни ставка прибыли (связанная с основным капиталом) не может быть гарантирована. Вкладчики должны инвестировать в фонд с четким пониманием, что доход от вкладов зависит от фактически полученной прибыли или понесенных убытков фондом. Если фонд получает прибыль, то доходность по вкладу возрастет пропорционально. Однако в случае, если фонд понес убытки, вкладчики также должны разделять убытки, только если ущерб не причинен по халатности или из-за неправильного управления, то в этом случае менеджмент, не на средства фонда, обязан возместить ущерб.

Во-вторых, суммы, объединенные в фонд, должны быть инвестированы в бизнес приемлемый по шариату. Это означает, что не только пути инвестирования, но и условия согласованные с этими путями должны соответствовать исламским принципам.
Учитывая в виду эти основные элементы, исламские инвестиционные фонды могут воплощать различные модели инвестирования, которые кратко рассматриваются в нижеследующих разделах.

10.2. Акционерный фонд

В акционерном фонде средства инвестированы в акции акционерных обществ. Прибыль в основном определяется на основе дохода от прироста капитала путем приобретения акций и ее продажи при увеличении цены. Прибыль также определяется путем начисления дивидендов соответствующими компаниями.

Очевидно, что если основная часть деятельности компании не является законной с точки зрения шариата, не допускается исламскому фонду приобретать, владеть или продавать акции этой компании, поскольку это повлечет за собой прямое участие в качестве акционера в этом запрещенном бизнесе.

Аналогично, современные правоведы по шариату почти единодушны в том, что если все операции компании находятся в полном соответствии шариату, которые заключаются в том, что компания не занимает деньги под проценты, не хранит излишки на процентном депозите, то акции этой компаний можно приобретать, владеть и продавать без каких-либо препятствий со стороны шариата. Но очевидно, такие компании очень редко встречаются на современных фондовых рынках. Почти все компании, котирующиеся в настоящее время на фондовых рынках, так или иначе, вовлечены в деятельность, которая нарушает предписания шариата. Даже если основная деятельность компании халяль, заимствования этой компании основаны на процентах. С другой стороны, они вкладывают свободные денежные средства на депозит под проценты или приобретают облигаций с фиксированным процентным доходом либо ценные бумаги.

Такие компании были предметом дискуссии между правоведами по шариату в нынешнем столетии. Группа правоведов по шариату не разрешает мусульманам иметь дело с акциями таких компании, даже если основная деятельность компании определена как халяль. Их основным аргументом является то, что каждый акционер компании шари`к (партнер) компании, и каждый шари`к, в соответствии

с исламской юриспруденцией, является агентом для других партнеров в вопросах совместного бизнеса. Таким образом, простое приобретение акций компании воплощает в себе предоставление полномочий держателями акции к компании, вести бизнес в любой форме на усмотрение менеджмента. Если акция держателю известно, что компания участвует в неисламской сделке, и по-прежнему держит акции этой компании, то это означает, что держатель предоставил полномочия менеджменту осуществить неисламскую сделку. В этом случае держатель акции не только ответственен за свое согласие на неисламскую сделку, но и справедливо будет также приписать ему эту сделку, потому, что менеджмент компании работает под его молчаливым разрешением.
Более того, когда компания финансируется на процентной основе, денежные средства, занятые в бизнесе являются нечистыми. Аналогичным образом, когда компания получает проценты по депозитам, эта прибыль обязательно включена в доход, который распределяется между акционерами в форме дивидендов.

Тем не менее, большое количество ученых нашего времени не поддерживают эту точку зрения. Они утверждают, что акционерное общество принципиально отличается от простого товарищества. В товариществе, все решения принимаются путем консенсуса всеми партнерами, и каждый из них имеет право вето в соответствии с политикой компании. Таким образом, все действия товарищества по праву отнесены каждому партнеру. С другой стороны, важнейшие решения в акционерном обществе принимаются большинством голосов. Будучи в составе большого числа акционеров, компания не может предоставить право вето для каждого акционера. Мнение индивидуального акционера может быть отменено по решению большинства. Таким образом, каждое действие, принимаемое компанией, не может быть отнесено к каждому акционеру. Если акционер возражает против той или иной сделки на годовом общем собрании, но его возражение отменено большинством голосов, не справедливо утверждать что он дал свое согласие на сделку, особенно когда он намерен воздержаться от дохода в результате этой сделки.
Поэтому, если компания занимается халяль бизнесом, но хранит свободные денежные средства на процентном депозите, откуда и получен несущественный процентный доход, то это не делает весь бизнес компании незаконным. Теперь, если человек приобретает акции такой компании с четким намерением, что он возражает против таких сделок и, что не будет использовать ту долю дивидендов на свои нужды, то, как можно говорить о том, что он одобрил сделку, основанную на процентах и каким образом сделку можно приписывать этому акционеру?

Иной аспект в деятельности таких компаний это то, что организаций иногда занимают денежные средства у финансовых учреждений. Эти заимствования в основном базируются на процентах. Здесь опять уместен тот же принцип. Если акционер лично не согласен с такими видами займов, но его мнение отвергнуто большинством то операций по заимствованию не могут быть приписаны ему.

Более того, хотя в соответствии с принципами исламского права заимствования под проценты представляет собой серьезный грех, за который заемщик несет ответственность в будущем, но это греховное деяние не определяет весь бизнес заемщика как харам или недопустимый с точки зрения шариата. Заимствованная

сумма, будучи определенная в качестве суммы принадлежащей заемщику и все что приобретено в обмен на эти деньги, не являются незаконными по шариату. Таким образом, ответственность за совершения греховного деяния (заимствования под проценты) лежит на лице, который умышленно решился на процентную сделку, но этот факт не определяет весь бизнес компании незаконным по шариату.

10.3. Условия при инвестировании в акций

В свете вышеизложенного обсуждения акции компаний могут быть приемлемы по шариату при соблюдении следующих условий:

1. Основная деятельность компании не нарушает принципы шариата. Таким образом, не допустимо, приобретение акций компаний, предоставляющие финансовые услуги под проценты, традиционные банки, страховые компаний или компаний, вовлеченные в бизнес, не одобренный по шариату, такие как компаний занимающиеся сбытом или производством спиртных напитков, свинины, мясо животного заколотого не по канонам ислама, или участвующие в игорном бизнесе, в деятельности ночных клубов, порнографии т.д.

2. Если основная деятельность компании халяль, как например автомобильная, текстильная промышленности и эти компаний хранят свои свободные денежные средства на процентном депозите или заимствуют средства под проценты, акционер должен выразить свое неодобрение в отношении таких сделок, предпочтительно путем голосования против такой деятельности на ежегодном общем собрании акционеров компании.

3. Если какой-то доход по процентным депозитам включен в доход предприятия, доля такого дохода, пропорционально выплаченная в дивидендах акционеру, следует потратить на благотворительные цели. Например, если 5% от всего дохода компании произошел от процентных вкладов, то 5% от дивидендов следует потратить на благотворительную деятельность.

4. Акций компании являются оборотными инструментами, только если компания владеет некоторыми неликвидными активами. Если все активы компании находятся в ликвидной форме, т.е. в денежной форме их не возможно купить или продать за исключением, если только по номинальной стоимости, поскольку в этом случае акция представляет только деньги, а деньги не могут быть проданы за исключением равноценного бартера.

Какой должна быть точная доля не ликвидных активов компании? Современные ученые имеют различные взгляды на этот вопрос. Некоторые ученые считают, что отношения неликвидных активов должна составлять не менее 51%. Они утверждают, что если такие активы составляют менее 50%, то большая часть активов находится в ликвидном виде и, следовательно, все активы рассматриваются как ликвидные на основе юридического принципа:

للاكثر حكم الكل

Большинство заслуживает того, чтобы рассматривать его в качестве цельного предмета (примерный перевод)

Некоторые ученые высказали мнение, что даже если неликвидные активы компании на уровне 33%, его акций можно рассматривать в качестве оборотного инструмента.

Третья точка зрения основывается на учениях имама Абу Ханифа. Принцип правовой школы ханафитов в том, что всякий раз, когда активы представляют собой сочетания ликвидных и неликвидных активов, они могут представлять оборотные инструменты, независимо от доли ее ликвидной части. Однако этот принцип требует соблюдения двух условий:

Во-первых, неликвидная часть сочетания не должна пренебрегать количеством. Это означает, что неликвидная часть должна представлять значительную долю.

Во-вторых, стоимость сочетания должна быть больше чем стоимость количества ликвидных активов содержащихся в нем. Например, если акция в 100 долл. США представляет 75 долларов плюс некоторые фиксированные активы, то стоимость акции должна превышать 75 долларов. В этом случае, если цена акции фиксирована на уровне 105, то это означает, что 75 долларов в обмен на 75 долларов составляющие акцию, а остаток в 30 долларов в обмен на фиксированные активы. И наоборот, если цена акции установлена на уровне 70 долларов, то это сделка не одобряется, потому что 75 долларов составляющие акцию в этом случае не обменены равноценно. Такой обмен подпадает под определение "риба" и не допускается. Аналогичным образом, если цена на акцию, в приведенном выше примере, фиксируется на уровне 75 долларов, то это не допустимо, потому что если мы исходим из того, что 75 долларов это стоимость от 75 долларов составляющие акцию, то не имеется остальной части выкупающие фиксированные активы, составляющие акцию. Таким образом, некоторая часть от стоимости (75 долларов) должна восприниматься как обменивающиеся на фиксированные активы акции. В этом случае оставшаяся сумма недостаточна. По этой причине сделка не действительна. Однако с практической точки зрения, это лишь теоретическая возможность, поскольку трудно представить себе ситуацию, когда стоимость акции опускается ниже, чем стоимость ликвидных активов.

Покупка и продажа акций допускается по шариату, с учетом этих условий. Исламский акционерный фонд может осуществлять свою деятельность на этой основе. Вкладчики фонда рассматриваются по шариату в качестве партнеров между собой. Все вложенные суммы формируют общий пул и инвестируются в акций различных компаний. Прибыль определяется путем начисления дивидендов соответствующими компаниями или за счет увеличения стоимости акций. В первом случае, когда прибыль представляет начисленные дивиденды, определенная часть дивидендов компаний имеющие происхождения от запрещенных сделок (процентный депозит) должна быть израсходована на благотворительную деятельность. Современные исламские фонды называют этот процесс "очисткой".

Ученые по шариату имеют различные мнения о том, является ли 'очистка' необходимостью, когда прибыль осуществляется путем прироста капитала (т.е.

когда покупают акций по более низкой цене и продают по более высокой цене). Некоторые ученые считают, что даже в случае прироста капитала, необходим процесс "очистки", поскольку рыночная цена акций может отражать элемент в виде процентного дохода включенного в активы компаний. Другая точка зрения в том, что очистка не требуется после продажи акций, даже если это происходит в результате прироста капитала. Причина в том, что нет определенной суммы от стоимости, которые можно выделить в качестве процентного дохода полученного компанией. Очевидно, что если соблюдены все вышеуказанные требования для халяль акций, то большая часть активов компании являются халяльными, и незначительная часть активов может образоваться за счет доходов от процентов. Эта небольшая доля не только неизвестна, но также пренебрегает возможностями основной части активов компании. Таким образом, цена акций, по сути, формируется в зависимости от основной части активов, а не от небольшой доли. Полная стоимость акций, таким образом, может рассматриваться только как стоимость халяль активов.

Хотя вторая точка зрения имеет силу, однако первый взгляд более предусмотрителен и далек от сомнительности. В частности, это мнение более справедливо в открытых акционерных фондах, потому что если очистка для присвоения активам статуса халяль не проведена а клиент выкупает пай в фонде на тот момент когда дивиденды не получены фондом, сумма очистки не вычтена из стоимости, хотя цена за пай может увеличиться в связи с переоценкой стоимости акций принадлежащих фонду. И наоборот, когда клиент выкупает пай, после того как некоторая часть дивидендов получена фондом и сумма очистки вычислена из дивидендов, уменьшая стоимость чистых активов на пай, то клиент получает менее низкую цену по сравнению с первым клиентом.

Напротив, если очистка осуществляется как на дивиденды, так и на прирост капитала, с учетом вычета сумм очистки все владельцы паев фонда рассматриваются на равных началах. Таким образом, сделка не только свободна от каких-либо сомнений, но и более справедливо для всех владельцев паев фонда. Очистка может осуществляться на основе среднего процента, начисленного и включенного в портфель компаний.

Менеджмент фонда может осуществлять свою деятельность двумя альтернативными способами. Управляющие фонда для вкладчиков могут выступать в качестве мудариба. В этом случае определенный процент, от годовой прибыли начисленный фондом может быть определен в качестве вознаграждения менеджменту, означая тем самым, что менеджмент получит определенную долю, только если фонд приобретет какую-либо прибыль. Если фонд не начислил прибыли, менеджмент ничего не заслуживает. Доля вознаграждения определенная для менеджмента возрастает пропорционально с увеличением прибыли.

Второй вариант для менеджмента это действовать в качестве агента для вкладчиков. В этом случае менеджменту может быть предоставлена заранее согласованная плата за услуги. Плата может быть фиксирована в виде единовременной суммы или в виде ежемесячного либо годового вознаграждения. По мнению современных ученых, плата может выражаться в виде процента от

нетто стоимости активов фонда. Например, может быть решено, что менеджмент будет получать 2% или 3% от стоимости нетто активов фонда 1 раз в конце каждого финансового года.

Тем не менее, необходимо по шариату определиться на одном из вышеперечисленных способов до начала работы фонда. Практический путь для этого, указывать в проспекте эмиссии фонда основу, по которой предоставляется вознаграждение менеджменту. В целом предполагается, что тот, кто присоединяется к фонду, соглашается с условиями, указанные в проспекте эмиссии. Таким образом, порядок уплаты вознаграждения менеджменту считается согласованным всеми вкладчиками.

10.4. Фондирование на основе иджара

Другой тип исламского фондирования - иджара фондирование. Иджара означает лизинг подробные правила, которого уже обсуждались в восьмой главе настоящей книги. В этот фонд суммы взносов используются для приобретения таких активов, как недвижимость, транспортные средства или другое оборудование в целях передачи в лизинг конечным потребителям. Право собственности на эти активы остается у Фонда, а арендная плата взимается у потребителей. Арендная плата формирует доход фонда, который распределяется на пропорциональной основе среди вкладчиков.

Каждому вкладчику выдается сертификат, подтверждающий его пропорциональную собственность в активе, и гарантирует право на пропорциональную долю в доходе. Сертификаты предпочтено называть "сукук" - термин, общепризнанный в традиционной исламской юриспруденции. Поскольку сукук это пропорциональная собственность их владельцев на реальные активы фонда, а не сумма ликвидных активов или долговых обязательств, они являются оборотными средствами и могут быть куплены или проданы на вторичном рынке. Тот, кто приобрел, сертификаты сукук заменяет продавца в пропорциональной собственности на соответствующие активы и все права и обязанности первоначального вкладчика передаются покупателю. Стоимость сертификатов сукук определяются на основе рыночных цен и, как правило, основаны на их рентабельности.

Однако следует иметь в виду, что договоры по лизингу должны соответствовать принципам шариата, которые существенно отличаются от договоров используемых в обычном финансовом лизинге. Расхождения подробно рассмотрены в восьмой главе настоящей книги. Тем не менее, некоторые базовые принципы кратко описаны ниже:

1. Арендованное имущество должно иметь узуфрукт (право пользования), а также арендная плата должна взиматься только с того момента времени, когда право пользования передано лизингополучателю.

2. Арендованное имущество должно иметь основное свойство, которое возможно использовать для халяль (дозволенное) целей.

3. Арендодатель должен нести все обязательства, вытекающие из права собственности на активы.

4. Арендная плата должна быть фиксирована и известна сторонам с самого начала договора.

В этом типе фондирования, менеджменту следует выступать в качестве агента вкладчиков. Выплачиваемое менеджменту вознаграждение может быть в виде фиксированной суммы или пропорционально к полученным арендным платежам. Большинство мусульманских правоведов считают, что такой фонд не может быть создан на основе мудараба, потому что мудараба, по их мнению, ограничивается продажей товаров и не распространяется на сферы услуг и лизинга. Тем не менее, по школе имама Ханбали, мудараба также может осуществляться на сферы услуг и лизинга. Этой точке зрения отдают предпочтения ряд современных ученых.

10.5. Фондирование товаров

Другой возможный вид исламского фондирования это фондирование товаров. В фонде этого вида привлеченные денежные средства используются для приобретения различных товаров с целью их перепродажи. Доход от продажи является прибылью фонда, который распределяется на пропорциональной основе среди вкладчиков.

Для того чтобы фонд соответствовал шариату, необходимо, чтобы все правила, регулирующие операции по купли-продажи были полностью соблюдены. Например:

1. Товар должен находиться в собственности продавца на момент продажи, так как кратковременная продажа, при котором человек продает товар без право владения на товар, не допускается по шариату.

2. Форвардные продажи не допустимы за исключением случаев салам и истисна (для полной информации см. предыдущую главу настоящей книги).

3. Товары должны соответствовать халяль требованиям. Таким образом, не позволено рассматривать в качестве предмета сделки вино, свинину или другие запрещенные материалы.

4. Продавец должен принять физическое или конструктивное владение товаром, который желает продать. (Конструктивное владение подразумевает любое действие, при котором риск по товару переходит к покупателю).

5. Цена на товар должна быть фиксированной и известной обеим сторонам. Если цена не определена или зависит от неопределенного события, то договор купли-продажи недействителен.

В свете вышесказанного, более подробно описано во второй главе настоящей книги, можно легко понять, что сделки распространенные на современных сырьевых рынках, особенно на фьючерсных товарных рынках не соответствуют этим условиям. Таким образом, исламский способ фондирования товаров не может вступить в такие операции. Однако если присутствуют реальные сделки по товару

и соблюдены все требования шариата, в том числе выше указанные условия, то в этом случае товары можно профинансировать. Паи такого фонда также можно продавать на вторичном рынке.

10.6. Фондирование мурабаха

'Мурабаха' представляет специфический вид продажи, где товары продаются по принципу основная сумма плюс наценка. Такая продажа принята современными исламскими банками и финансовыми учреждениями, в качестве способа финансирования. Банк закупает товары для клиентов, затем реализует им товары на основе отсроченного платежа, по заранее согласованной цене, в которую включена ставка прибыли. Если фонд создан для осуществления этого вида купли-продажи, фонд должен быть закрытого типа и его паи не могут выступать в качестве оборотного инструмента на вторичном рынке. Причина в том, что в случае мурабаха сделки, современные финансовые учреждения реализуют клиентам товары незамедлительно после закупа от первоначального поставщика, в то время как стоимость товара выплачивается по системе отсроченного платежа, тем самым является долговым обязательством, оплачиваемый клиентом. Таким образом, мурабаха портфель не обеспечен никаким материальным имуществом. Фонд обеспечен лишь наличными или дебиторской задолженностью, следовательно, паи фонда представляют собой либо деньги или долговые обязательства и эти средства как описано выше не являются оборотными инструментами. Если они обмениваются на деньги, то только по номинальной стоимости.

10.7. Баи'-аль-даин

Здесь уместен вопрос разрешает ли шариат осуществлять баи'-аль-даин. Даин означает "долг" а баи означает продажу. Баи'-аль-даин, следовательно, означает продажу долга. Если человек имеет дебиторскую задолженность от кого-либо, и желает продать ее по заниженной цене, как это обычно происходит в случае векселя, то по шариату это называется баи'-аль-даин. Традиционные мусульманские правоведы (фукаха') едины в том, что баи'-аль-даин со скидкой не позволительно по шариату. Подавляющее большинство современных мусульманских ученых такого же мнения. Однако некоторые ученые Малайзии разрешают такую продажу. Как правило, они ссылаются на правовые нормы шафиитов, в котором они допускают продажу долговых обязательств, но они не замечают того факта, что правоведы-шафииты позволили проводить такие сделки только в том случае, если задолженность продается по номинальной стоимости.

На самом деле запрет на баи'-аль-даин является логическим следствием запрещения 'рибы' или процента. «Дебиторская задолженность» монетарное выражение, которого подразумевает реальные деньги, и каждая сделка, при которой деньги обмениваются на денежные средства той же стоимости, должна осуществляться по номинальной стоимости. Любое увеличение или сокращение одной стороны равносильно 'рибе' и это никогда не будет дозволено по шариату.

Некоторые ученые утверждают, что допустимость баи'-аль-даин распространяется и на сделки когда задолженность образовалась за счет продажи товара. В этом случае они утверждают, задолженность представляет проданный товар и продажу

долга можно рассматривать как продажу товара. Аргумент, однако, не имеет силы. Ибо, как только товар продан, право собственности переходит покупателю, и товар уже не принадлежит продавцу. То, что продавец имеет, это только вырученные деньги. Поэтому, если он продает долг, то это не более чем продажа денег и эту сделку не возможно назвать сделкой по продаже товара.

Вот почему эта точка зрения не была принята подавляющим большинством современных ученых. Академия Исламского Фикха г. Джидда, крупнейшее объединение ученых, и где представлены все мусульманские страны, включая Малайзию, одобрил запрещение баи'-аль-даин единогласно, без единого расхождения во мнениях.

10.8. Смешанное фондирование

Другой тип исламского фонда это где вложенные суммы используются на различные виды инвестирования, например ценные бумаги, лизинг, товары и т.д. Это можно называть смешанным исламским фондом. В этом случае, если материальные активы фонда более 51%, а ликвидные активы и долговые обязательства составляют менее 50%, то паи фонда можно использовать в качестве оборотного инструмента. Однако, если доля ликвидных активов и долговых обязательств превышает 50%, то, по мнению большинства, современных ученых его паи не могут быть проданы. В этом случае фонд должен быть закрытого типа.

11. Концепция ограниченной ответственности

11.1. Введение

Концепция "товарищества с ограниченной ответственностью" на сегодня стала неотъемлемой частью огромного количества предприятий в промышленности и торговле в современном мире, в том числе и в мусульманских странах. Цель настоящей главы разъяснить концепцию и оценить ее с точки зрения шариата, чтобы определить является ли этот принцип приемлемым в чисто исламской экономике. "Товарищество с ограниченной ответственностью" в современной экономической и юридической терминологии означает состояние, при котором партнер или акционер бизнеса предостерегает себя от приобретения убытков на сумму не более чем вложенные им средства в компанию или в товарищество с ограниченной ответственностью. Если бизнес несет убытки, максимальные потери акционера могут составить все его первоначальные инвестиций. Но убытки не распространяются на его личные активы, и, если активы компании не являются достаточными для покрытия всех обязательств, кредиторы не могут претендовать на личное имущество акционеров в счет оставшейся части дебиторской задолженности компании.

Хотя понятие "товарищество с ограниченной ответственностью" в некоторых странах применяют и к партнерству, однако, термин наиболее широко применяем к компаниям и органам управления. Скорее всего, более справедливо, пожалуй, сказать, что понятие "товарищество с ограниченной ответственностью" первоначально возникло с появлением органов управления и акционерных обществ. Основная цель введения этого принципа привлечь максимальное количество инвесторов в крупномасштабные совместные предприятия и заверить

их, если они инвестируют свои сбережения в такое совместное предприятие, то их личное состояние не будет подвержено какому-либо риску. В практике современной торговли, концепция доказала свои возможности мобилизации значительных сумм капитала от широкого круга инвесторов.

Несомненно, концепция "ограниченной ответственности" выгодна акционерам компании. Но в то же время, может иметь место несправедливости по отношению к кредиторам. Если обязательства товарищества с ограниченной ответственности превышают его активы, предприятие становится неплатежеспособным и в случае процесса банкротства кредиторы могут потерять значительные суммы, поскольку они могут выручить лишь стоимость ликвидированных активов компании, и не могут претендовать на какие-либо выплаты от учредителя. Даже руководство товарищества, которое возможно несет ответственность за такое положение, не несет ответственности за погашение долгов перед кредиторами. Именно этот аспект концепции "ограниченной ответственности", требует рассмотрения и исследования с точки зрения шариата.

Хотя понятие "товарищество с ограниченной ответственностью" в контексте современной коммерческой практики новая концепция, и нет четкого упоминания концепции из первоначальных источников исламского фикха, но точку зрения шариата по этому вопросу можно искать в принципах изложенных в священном Коране, сунне пророка (с.а.с.) и исламской юриспруденции. Эта задача требует иджтихада осуществленного уполномоченными лицами. Иджтихад желательно должен быть предпринят учеными шариата на коллективном уровне, но в качестве предпосылки следует провести отдельные усилия, которые будут служить основой для коллективного решения задачи.

Как скромный ученый по шариату, автор рассматривал этот вопрос на протяжении долгого периода, и представленное мнение в данной статье не должно рассматриваться как окончательный вердикт по этому вопросу или абсолютное мнение по этому поводу. Это является результатом первоначального размышления по этому вопросу, и цель этой статьи заключается в создании основы для дальнейших исследований.
Вопрос об "ограниченной ответственности", можно сказать, тесно связан с концепцией правосубъектности современных органов управления. В соответствии с этой концепцией, акционерное общество само по себе имеет статус самостоятельного подразделения, в отличие от физических лиц, т.е. акционеров. Самостоятельное подразделение как фиктивный субъект представляет юридическое лицо и таким образом может быть истцом и ответчиком в суде, заключать контракты, владеть собственностью от своего имени, и имеет правовой статус физического лица во всех его сделках, заключенных в качестве юридического лица.

Основным вопросом, как полагают, является ли понятие "юридическое лицо" приемлемым по шариату или нет. После того как концепция "юридического лица" была принята, и признано что, несмотря на фиктивный характер, юридическое лицо может рассматриваться в качестве физического лица в отношении правовых последствий сделок совершаемые от его имени, мы вынуждены принять

концепцию "товарищества с ограниченной ответственностью", которая следует в качестве логического результата предыдущей концепций. Причина очевидна. Если человек умирает, человек неплатежеспособен, его кредиторы не имеют возможности взыскания долга за исключением оставленного имущества. Если его обязательства превышают его активы, кредиторы, безусловно, пострадают, так как нет определенного средства правовой защиты для них после смерти задолжавшего человека.

Теперь, если мы признаем, что компания, в качестве юридического лица, имеет права и обязанности, аналогичные с физическим лицом, этот же принцип будет применяться к несостоятельному предприятию. Компания определенная как неплатежеспособная, обязательно будет ликвидирована и ликвидация предприятия аналогично смерти человека, потому что компании после ее ликвидации не существует. Если кредиторы какого-либо человека могут пострадать, в случае смерти этого человека, то также могут пострадать кредиторы юридического лица, когда правовое функционирование предприятия сойдет на нет по причине ее ликвидации.

Таким образом, основной вопрос, является ли концепция "юридического лица" приемлемой по шариату. Хотя предусмотренная в современной экономической и правовой системах идея юридического лица, не рассмотрены в исламском праве, но есть определенные прецеденты, откуда можно получить основу концепций юридического лица путем логических выводов.

11.2. Вакф

Первый прецедент - вакф. Вакф юридическое и религиозное учреждение, куда кто-либо посвящает часть своей собственности на религиозные или благотворительные цели. Имущество объявленное вакфом, уже не является собственностью дарителя. Бенефициары вакфа могут иметь доход от посвященной собственности, но не являются владельцами имущества. Владение этим имуществом принадлежит только Аллаху Всемогущему.
Мусульманские правоведы рассматривали вакф в качестве отдельного юридического лица и приписывали ему некоторые характеристики, сходны с физическим лицом. Это становится ясно из двух постановлений выданного фукаха (мусульманские правоведы) в отношении вакфа.

Во-первых, если имущество приобретается от доходов вакфа, приобретенное имущество не становится частью вакфа автоматически. Скорее правоведы говорят, такое имущество рассматривается как имущество, принадлежащее вакфу. Это явно означает, что вакф, как и физическое лицо, может владеть собственностью.

Во-вторых, правоведы четко упомянули, что средства выделенные мечети в качестве пожертвования не являются частью вакфа, но переходят в собственность мечети.
Здесь опять же мечеть рассматривается в качестве владельца денег. Этот принцип также четко указан некоторыми правоведами маликитской правовой школы. Они заявили, что мечеть может являться владельцем чего-нибудь. Эта способность

мечети, по их мнению, носит конструктивный характер, в то время как способность, которой пользуется человек - физическое.

Другой известный правовед-маликит, в частности, Ахмад аль-Дардир, придал юридическую силу сделанному завещанию чего-либо в пользу мечети, и выдвинул аргумент, что мечеть может владеть имуществом. Не только это, также он распространил этот принцип на постоялый двор и мост при условии, что это вакф.
Как видно из этих примеров, мусульманские правоведы признали, что вакф может владеть имуществом. Очевидно, что вакф не является человеком, но в вопросах собственности распространяются правила, применяемые людям. Логически вытекает, что вакф может продавать и покупать, стать должником и кредитором, и выступать истцом и ответчиком в суде и, следовательно, можно отнести к нему все характеристики 'юридические лица'.

11.3. Байтул-маль

Другой пример "юридического лица", байтул-маль (казначейство исламского государства), найден в классической литературе по фикху. Будучи общественной собственностью, все граждане исламского государства имеют определенное право бенефициария над байтул-маль, однако никто не может стать его владельцем. Тем не менее, байтул-маль имеет некоторые права и обязанности. Имам аль-Сарахси, известный ханафитский правовед, утверждает в своем труде "Аль-Мабсут":
"Байтул-маль имеет некоторые права и обязанности, которые возможно не определены".

В другом месте тот же автор предполагает: **"Если главе исламского государства требуются денежные средства чтобы выдать зарплату армий но он не находит деньги в харадж департаменте при байтул-маль (откуда обычно выдают зарплату) он может выдать зарплату из фонда садака (закят), но сумма приобретенная таким образом будет считаться задолженностью харадж департамента перед фондом садака".**

Из этого следует, что не только байтул-маль, а также различные присутствующие в нем ведомства могут брать и выдавать кредиты друг другу. Ответственность по этим кредитам лежит не на главе государства, а на соответствующем ведомстве байтул-маль. Это означает, что каждый департамент байтул-маль отдельное ответственное лицо и в этом качестве может выдавать и занимать деньги, может рассматриваться в качестве заемщика или кредитора, следовательно, может выступать истцом и ответчиком в том же порядке, как и юридическое лицо. Это означает, что исламская фукаха переняла концепцию юридического лица от байтул-маль.

11.4. Акционерное общество

Другой пример, акционерное общество, очень близок к "юридическому лицу", найден в фикхе имама аш-Шафи’и. В соответствии с принципом школы имама аш-Шафи'и, если два и более лиц управляют бизнесом на основе партнерства, где их активы смешиваются друг с другом, закят (налог) взимается с каждого из них по отдельности, но будет выплачиваться как единое от имени акционерного общества, причем таким образом, что даже если один из них не владеет суммой нисаба

(минимальна сумма обложения закят налогом), а общая стоимость всех активов превышает установленный предел нисаба, закят подлежит выплате от имени всего акционерного общества, включая долю предыдущего, следовательно, лица, доля которых менее установленного нисаба, должны также внести свой вклад в облагаемую сумму закята в пропорции к своей доли от общего объема активов, в то время как он не подлежит обложению закятом, если бы закят взимался по каждому лицу в индивидуальном порядке.

Тот же самый принцип, называется принципом "хултах-аль-шуйу" и более активно применяется к сумме обложения закятом на домашний скот. Следовательно, человек иногда должен выплатить больше закята, чем он обязан выплачивать в индивидуальном порядке, и иногда должен выплатить меньше.

Поэтому святой пророк ﷺ сказал:

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة اصدقه

“Не следует объединять (имущество, принадлежащее) разным людям, как не следует и разделять то, что находится в совместном владении из опасений (перед тем, что иначе придётся заплатить больше) закята”

Принцип "хултах-аль-шуйу" в некоторой степени также принят с некоторыми различиями в деталях правовыми школами Ханбали и Малик и имеет основу концепций юридического лица. Согласно этому принципу, не индивидуум несет ответственность за закят, а "акционерный капитал" является объектом обложения закятом. Это означает, что "акционерный капитал" рассматривался, как отдельное лицо и обязательство по закяту переключено на этот субъект, который очень близок к концепции "юридического лица", хотя это не совсем то же самое.

11.5. Наследство с долговыми обязательствами

Четвертый пример это имущество оставленное после смерти собственника, и у которого обязательства превышают стоимость оставленного имущества. Для краткости мы можем именовать эту ситуацию "наследство с долговыми обязательствами".

По словам правоведов, это имущество уже не принадлежит покойному, так как его нет в живых, и не принадлежит наследникам, поскольку долги усопшего имеют преимущественное право на имущество по сравнению с правами наследников. Имущество даже не принадлежит кредиторам, поскольку погашение долгов этим имуществом еще не произошло. Они имеют право на имущество, но оно не является их собственностью, пока фактически наследство не распределено между ними. Являясь ничьей собственностью, имущество имеет свое собственное юридическое функционирование и наследство можно назвать юридическим лицом. Наследники умершего или назначенный исполнитель завещания ответственен за имущество в качестве руководителя, но не является собственником. Если в процессе погашения долгов требуются расходы, то они будут покрываться за счет самого имущества.

Если смотреть с этой точки зрения, "наследство с долговыми обязательствами" имеет права и обязанности, которые позволяют продавать и покупать, становится

заемщиком и кредитором, и имеет все характеристики сходные с 'юридическим лицом'. Ответственность "юридического лица" такого типа, безусловно, ограничена существующими активами. Если при выплате задолженности не хватает активов, то для кредиторов не существует иного рычага возврата остальной суммы.

Есть несколько случаев, когда мусульманские правоведы подтверждают сходство правового субъекта с юридическим лицом. Эти примеры показывают, что понятие "юридическое лицо" не совсем чуждо исламской юриспруденции, и, если юрисдикция акционерного общества принята на основе этих прецедентов, то и не должно возникать никаких серьезных возражений по этому поводу.

Как отмечалось ранее, вопрос об ограниченной ответственности компании тесно связан с концепцией 'юридического лица'. Если права и обязательства 'юридического лица' такие же, как и у физического лица то в этом случае каждый человек несет ответственность лишь в пределах активов, которыми он владеет, и в случае его смерти иное лицо не может нести бремя обязательств. Ограниченная ответственность акционерного общества может быть оправдана по этой аналогии.

Ограниченная ответственность рабовладельца здесь я хотел бы привести еще один пример, который очень близок к ограниченной ответственности акционерного общества. Пример относится к периоду нашей прошлой истории, когда рабовладение было популярным делом, рабы были собственностью хозяев и свободно торговались. Хотя институт рабовладения по отношению к нашему веку это что-то далекое и закрытое, но правовые принципы, заложенные нашими правоведами при работе с различным вопросами, связанные с торговлей рабами по-прежнему полезны для студентов исламского права, и мы можем использовать эти принципы при поиске решения на наши современные проблемы и в этой связи этот пример является наиболее актуальным. В те дни невольники были двух видов. К первому типу относились те, которым хозяин запрещал вступать в какие-либо коммерческие сделки. Невольник этого вида назывался "кинн". Но был и иной тип рабов, которым хозяин позволял вступать в торговлю. Этот невольник именовался العبد الماذون, первоначальный капитал таким рабам для ведения торговли, предоставлял хозяин, но он свободно проводил все коммерческие операции. Капитальные вложения полностью принадлежали хозяину. Доход от сделок и все что заработал невольник, переходило хозяину в качестве исключительной собственности. Если в ходе торговли невольник приобретал задолженность, то долг будет выплачиваться за счет денежных средств и материальной базы присутствующие у раба. Но, если сумма денежных средств и материальной базы недостаточна для выплаты долга, кредиторы имеют право на продажу раба, с целью возврата средств. Однако если даже после продажи раба требования кредиторов не удовлетворены и раб умрет в состоянии задолженности, кредиторы не могут требовать от хозяина раба выплаты, не достающей части задолженности.

Рабовладелец фактически владелец всего бизнеса, раб посреднический инструмент для ведения бизнеса. Невольник ничего не имеет от бизнеса. Тем не менее, ответственность хозяина ограничена инвестированным капиталом, в том числе

стоимость самого невольника. После смерти невольника, кредиторы не могли претендовать на личные активы хозяина.

Это самый близкий пример найденный в исламском праве, который очень схож с ограниченной ответственностью акционеров компаний, который может быть приспособлен по той же аналогии. На основе этих пяти прецедентов, кажется, что концепция юридического лица, и ограниченная ответственность не противоречат запретам ислама. Но в то же время, следует подчеркнуть, что концепция "ограниченной ответственности" не должна допускаться с целью обмана людей и уклонения от естественного обязательства являющийся результатом рентабельной торговли. Таким образом, концепция может ограничиваться только публичными компаниями, которые выпускают акций для всех заинтересованных лиц и число акционеров которых является настолько многочисленным, что каждый из них не может быть ответственен за ежедневную деятельность и за долги, превышающие активы.

Что касается частных компании или товариществ концепция ограниченной ответственности не должна применяться к этим субъектам права, так как в этой форме каждый соучредитель и партнер должен нести полную ответственность. Здесь можно сделать исключение для партнеров или акционеров частной компании, не принимающих участия в деловой практике и их ответственность можно ограничить в соответствии с соглашением между партнерами. Если ответственность таковых партнеров ограничена в соответствии с настоящим соглашением, с точки зрения исламского права это значит, что они не одобряют приобретение долгов превышающих стоимость активов предприятия. В этом случае если долги предприятия увеличились сверх указанного предела то единственный ответственный это управляющий бизнесом партнер, который превысил лимит.

Результатом вышеизложенного обсуждения является то, что концепция ограниченной ответственности может быть оправдана с точки зрения шариата, в случае публичных акционерных обществ и тех юридических лиц, которые выпускают свои акций для всех заинтересованных вкладчиков. Концепция также может быть применена к партнерам и акционерам частных компаний, которые не принимают активного участия в управлении бизнесом. Но ответственность активных соучредителей в товариществе и акционеров частной компании всегда должна быть полной.
В конце концов, мы должны вновь напомнить, что указано в самом начале. Вопрос об ограниченной ответственности, являясь современным вопросом, который требует коллективного усилия, чтобы найти окончательное решение в свете шариата, вышеизложенная дискуссия не окончательный ответ на данный вопрос. Это только результат первоначального размышления, который всегда остается предметом дальнейшего изучения и исследования.

Эффективность исламских банков - реалистичные оценки

Исламский банкинг на сегодня становится неоспоримой реальностью. Число исламских банков и финансовых учреждений постоянно возрастает. Создаются новые исламские банки с огромным капиталом. Обычные банки открывают

исламские окна или исламские дочерние организаций. Даже немусульманские финансовые учреждения входят в эту сферу и пытаются конкурировать друг с другом, чтобы привлечь как можно больше мусульманских клиентов. Кажется, что размеры исламского банкинга, по меньшей мере, увеличатся кратно на протяжении следующего десятилетия и исламские банки, как ожидается, будут отражать огромный удельный вес в финансовых операциях в мире. Но прежде, чем исламские финансовые учреждения расширят свой бизнес, они должны оценить эффективность, приобретенную на протяжении двух последних десятилетий, поскольку каждая новая система должна извлекать уроки из прошлого, пересмотреть свою деятельность и реалистично анализировать недостатки. Если мы не проанализируем наши преимущества и недостатки мы не сможем рассчитывать на продвижение к полному успеху. Именно с этой перспективы мы должны стремиться к анализу операции исламских банков и финансовых учреждений в свете шариата и подчеркнуть то, что уже достигли, и то, что упустили.

Однажды во время пресс-конференции в Малайзии, автору задали вопрос о вкладе исламских банков в развитие исламской экономики. Мой ответ на этот вопрос был явно противоречивым, я сказал, что они внесли большой вклад, и они не внесли ничего. В настоящей главе предпринята попытка разработать ответ на этот вопрос. Когда было сказано, что они внесли большой вклад, имелось в виду, что это было замечательным достижение исламских банков, которые внесли большой прорыв в современную банковскую систему путем создания исламских финансовых учреждений посредством следования шариату. Заветная мечта мусульманской уммы – это беспроцентная экономика, но концепция исламского банкинга была лишь теорией обсуждаемая в научных статьях, и не имеющая практического примера. Исламские банки и финансовые учреждения перевели теорию в практику и презентовали живой и практический пример теоретической концепции в среде, в которой утверждалось, что финансовое учреждение не может функционировать без процентов. Это было поистине мужественным решением со стороны исламских банков выступить с твердым решением, что все их операций будут соответствовать шариату и вся их деятельность будет свободна от сделок связанных с процентами.

Еще один важный вклад исламских банков это то, что, находясь под наблюдением совета по надзору на соответствие шариату они представили ученым по шариату широкий спектр вопросов связанных с современным бизнесом тем самым, предоставляя им возможность не только разобраться в современной практике бизнеса и торговли, но также оценить их в свете шариата и разработать другие альтернативные схемы, которые соответствуют исламским принципам.

Следует понимать, что когда мы утверждаем что ислам имеет решения любой проблемы, возникающей в любой ситуаций и в любое время, мы не подразумеваем что священный Коран и сунна пророка (с.а.с.) или постановления исламских ученых предоставляют конкретные детально отработанные ответы о социально-экономической жизни. Подразумевается, что в священный Коран и сунна святого пророка ﷺ заложили общие принципы, в свете которых ученые делают вывод и предоставляют конкретный ответ на возникшую новую ситуацию. Таким образом, в целях достижения определенного ответа на новый вопрос ученые по шариату

должны играть очень важную роль. Они должны анализировать каждый новый вопрос в свете принципов изложенных в священном Коране и сунне, а также в свете стандартов установленных более ранними правоведами, перечисленные в книгах по исламскому праву. Поиск консенсуса на вопрос, называется истинбат или иджтихад. Именно истинбат обогатил исламское право знаниями и мудростью. В обществе, где шариат влияет на все сферы жизни, текущий процесс истинбата является инъекцией новых идей, концепций и правил в наследие исламскому праву, и позволяет выяснить конкретные ответы почти на каждую ситуацию. Но в течение последних нескольких столетий политический спад мусульман остановил этот процесс. Большинство исламских стран были захвачены и правители не мусульмане путем применения силы устанавливали светскую систему управления, социально-экономическую жизнь отделили от шариата, и исламское учение было ограничено поклонением, религиозным образованием, а в некоторых странах бракоразводным процессом и наследованием имущества. Что касается политической и экономической деятельности, то шариат из этих сфер был отвергнут полностью.

Поскольку эволюция любой правовой системы зависит от практической составляющей, эволюция исламского права в отношении бизнеса и торговли практический не развивалась. Почти все операции на рынке, будучи основанные на светской концепции редко доводятся до ученых по шариату для их изучения в свете шариата. Даже в эти дни некоторые практикующие мусульмане приносят практические вопросы ученым по шариату, для которых ученые выдают свои решения в форме фатуа, большое собрание которых все еще доступны. Однако все фатуа связаны главным образом с отдельными проблемами соответствующих лиц и адресованы для решения индивидуальных потребностей.
Огромный вклад исламских банков это то, что они вступили в сферу крупного бизнеса и колесо эволюций исламской правовой системы, было возобновлено. Большинство исламских банков работают под руководством совета по надзору на соответствие шариату. Они приносят свои повседневные проблемы ученым по шариату, которые рассматривают вопрос в свете исламских норм и принципов и выдают конкретные постановления. Эта процедура не только предоставляет возможность ученым по шариату подробно ознакомиться с новой ситуацией на рынке, но и через осуществление истинбата вносить свой вклад в эволюцию исламского права. Таким образом, если практика не соответствует принципам шариата подходящее альтернативное решение, будет найдено путем совместных усилий ученых по шариату и менеджмента исламского банка. Постановления советов по надзору на соответствие шариату уже насчитывают десятки томов - вклад, который невозможно недооценить.

Еще одним важным вкладом исламских банков является то, что они уже заявили о себе на международном рынке, и исламский банкинг имеющий отличия от обычного банкинга постепенно признается во всем мире. Вот что и имелось в виду когда я сказал что они внесли большой вклад. С другой стороны, имеется ряд недостатков в деятельности сегодняшних исламских банков, которые должны быть проанализированы со всей серьезностью.
Прежде всего, концепция исламского банкинга основана на экономической философии произошедшая из норм и принципов шариата. В контексте

беспроцентного банкинга, философия направлена на установления свободной от всех видов эксплуатации справедливого распределения. Как я уже объяснял в ряде статей инструменты, основанные на проценте, имеют не прерывную тенденцию в пользу богатых и против интересов простых людей. Богатые промышленники путем заимствования огромных сумм используют деньги вкладчиков банка в масштабные прибыльные проекты. После получения прибыли, вкладчикам выплачивается скудная процентная ставка, которая едва покрывает фактическую инфляцию цен на товары. Таким образом, на макроуровне, вкладчикам ничего не выплачивается. Процентное финансирование создает неравенство и дисбаланс в распределении богатства.

Исламское финансирование противоположно этим принципам. Идеальный инструмент финансирования в соответствии с шариатом - мушарака, где прибыль и убыток разделяют обе стороны пропорционально. Мушарака предоставляет более широкие возможности для вкладчиков на участие в фактической прибыли, полученной от бизнеса, который в обычных случаях может быть гораздо выше, чем процентная ставка. Поскольку прибыль не возможно определить пока соответствующие товары не реализованы полностью, прибыль, выделяемая вкладчикам, не может быть добавлена к себестоимости, поэтому, в отличие от процентного финансирования сумма, выплачиваемая вкладчикам не поглощается инфляцией, т.е. путем увеличения цен.
Эту философию не возможно претворить в жизнь, если исламские банки не расширят использования мушарака. Правда, существуют практические проблемы в использовании метода мушарака как способа финансирования, особенно в нынешней атмосфере, где исламские банки работают в изоляции и, в основном без поддержки со стороны правительств. Исламские банки должны двигаться к развитию финансирования на основе мушарака постепенно и следует увеличивать объем финансирования на основе мушарака. К сожалению, исламские банки не обращают внимания на эту основную черту исламского банкинга, и нет никаких видимых усилий по продвижению этого инструмента постепенно или на выборочной основе. Эта ситуация привела к ряду негативных факторов:

Во-первых, полностью игнорируется основная философия.

Во-вторых, игнорируя инструмент мушарака, исламские банки вынуждены использовать инструмент мурабаха и иджара, в рамках обычных критериев, например Libor и т.д., где окончательный результат не отличается от сделок основанных на процентах. Я не разделяю мнения тех людей, которые не нашли никакой разницы между обычными банковскими операциями и мурабаха, иджара и кто обвиняет инструменты мурабаха и иджара заменой одной и то же операций другим именем, потому что если мушарака и иджара методы осуществляются при необходимых условиях, они во многом отличаются от сделок основанных на проценте. Тем не менее, нельзя отрицать, что эти две операций первоначально не были способом финансирования по шариату. Ученые по шариату позволили использовать их в целях финансирования при определенных условиях, только в сферах, где не возможно осуществить мушарака договор. Это разрешение не должно рассматриваться как постоянно действующее правило для всех видов

операции и вся деятельность исламских банков не должна вращаться вокруг этих сделок.

В-третьих, когда люди осознают, что доходы исламских банков от операции, подозрительно схожи на обычные операций банков, они скептически относятся к функционированию исламских банков.

В-четвертых, если все операций исламских банков основаны на вышеназванных способах то очень трудно доказать оригинальность исламского банкинга перед массами, особенно, перед не мусульманским населением, которые считают, что это ничто иное, как просто замена наименования банковских продуктов.
В ряде исламских банках мурабаха и иджара не осуществляются в соответствии с процедурой требуемой шариатом. Основная концепция мурабаха в том, что банк обязан сначала купить товар и затем продавать товар клиенту на основе отсроченных платежей с наценкой. С точки зрения шариата необходимо вступление в права собственности по данному товару или, по крайней мере, вступить в конструктивное владение до реализаций. Банк должен нести риски по товару в течение периода собственности и владения товаром. Отмечено что многие исламские банки и финансовые учреждения совершают ряд ошибок в связи с этой сделкой:

Некоторые финансовые учреждения считают, что мурабаха является заменой процента для всех практических целей. Таким образом, договор мурабаха используется даже тогда, когда клиенту требуются средства на накладные расходы, такие как выплата заработной платы и оплата счетов за уже приобретенные товары и услуги. Очевидно, мурабаха не может быть использована в данном случае, поскольку ни один товар не приобретается банком.

В некоторых случаях клиент покупает товар предварительно до какого-либо соглашения с исламским банком и мурабаха осуществляется на основе выкупа. Это сделка снова противоречит исламским принципам, потому что договоренность о выкупе единогласно запрещена шариатом.

В некоторых случаях клиент является агентом банка в целях покупки товара и сразу же после приобретения продает товар себе. Это не соответствует основным условиям допустимости мурабаха. Если клиент является агентом по приобретению товара, то после покупки товара от имени банка он должен сообщить банку, что он произвел покупку от его имени и затем товар должен быть продан клиенту банком путем обмена оферты и акцепта, которую можно осуществить с помощью факса.

Как было объяснено ранее мурабаха, является договором купли-продажи со своей спецификой и требуемый принцип шариата, чтобы цена была определена на момент продажи. После согласования обеими сторонами эту цену не возможно увеличить или уменьшить в одностороннем порядке. Отмечено что некоторые финансовые учреждения в случае задержки платежа увеличивают цену товара по договору мурабаха, эта ситуация не допускается по шариату. Некоторые финансовые учреждения используют рефинансирования по отношению мурабаха договорам в случае невыполнения клиентом обязательств. Очевидно, что эта

практика не оправдана шариатом, поскольку если товар продан клиенту, товар не может быть предметом еще одной продажи с тем же клиентом.

Также в операции иджара часто игнорируются некоторые требования шариата. Необходимое условие для действительности иджара чтобы лизингодатель нес риски, связанные с правом собственности на предмет лизинга, а право пользование предметом лизинга должно быть доступно арендатору, за которое он выплачивает арендную плату. Наблюдается что в ряде иджара договорах, пренебрегается это правило. Даже в случае уничтожения активов вследствие форс-мажорных обстоятельств, арендатор обязан продолжать выплачивать арендную плату, означая тем самым, что арендодатель не принимает на себя ответственность в качестве собственника и не предоставляет право пользования лизингополучателю. Этот тип иджара противоречит основным принципам шариата.

Исламский банкинг базируется на принципах отличных от обычной банковской системы. Поэтому вполне логично, что результат деятельности не обязательно совпадает с термином рентабельность. Исламский банк может заработать больше в некоторых случаях и может зарабатывать менее в других. Если наша цель это всегда соответствовать по прибыльности обычным банкам, мы вряд ли сможем развить наши собственные продукты, основанные на чисто исламских принципах. Пока инвесторы банка, а также менеджмент и клиентура не осознают этого факта и не будут готовы принять эту разницу, исламские банки будут продолжать использовать искусственные способы и истинно исламская система не наступит.

В соответствии с исламскими принципами, деловые операций не могут быть отделены от моральной цели общества. Таким образом, исламские банки должны принимать новую политику финансирования и изучать новые каналы инвестирования, которые могут способствовать развитию и поддержке малого бизнеса и улучшить их экономическое состояние. Очень немногие исламские банки и финансовые учреждения обратили внимание на этот аспект. В отличие от традиционных финансовых учреждений, которые стремятся только к увеличению прибыли, исламские банки должны способствовать выполнению потребностей общества в качестве одной из своих основных целей и должны отдавать предпочтение к продуктам которые смогут помочь простым людям повысить их жизненный уровень. Банкам следует разработать новые схемы для целей финансирования недвижимости, транспортного средства и восстановительное финансирование для малых предпринимателей. Эти сферы по-прежнему ожидает внимания исламских банков.

Исламский банкинг не продвинется, пока не будет разработана эффективная система межбанковских операций на основе исламских принципов. Отсутствие такой системы заставляет исламские банки обращаться к обычным банкам для краткосрочных потребностей в ликвидности, которые не предоставляют средства без начисления фактического или скрытого процента. Создание межбанковских отношений основанных на исламских принципах больше не считается сложным делом. Число исламских финансовых учреждений сегодня достигла около двух сотен. Они могут создать фонд, совместив мурабаха и иджара инструменты, паи

которого можно использовать даже на операций со сроком на 1 сутки. Если разработать такой фонд можно решить целый ряд проблем.

И наконец, исламские банки должны разработать собственную культуру. Очевидно, что ислам не ограничивается банковскими операциями. Ислам представляет собой набор правил и принципов, регулирующих всю жизнедеятельность человека. Таким образом, просто быть "исламским" не достаточно. Необходимо также, чтобы вид учреждения и сотрудники отражали исламскую идентичность весьма отличающей ее от обычного учреждения. Это та область, в которой некоторые исламские учреждения на Ближнем Востоке добились определенного прогресса. Тем не менее, это должно быть отличительной чертой всех исламских банков и финансовых учреждений во всем мире. Совету по надзору на соответствие шариату следует обращать внимание также и на этот аспект.

Цель этого обсуждения, как сказано в самом начале, никоим образом не препятствовать исламским банкам или искать ошибки. А только в том, чтобы убедить оценить собственную деятельность с точки зрения шариата и принять реалистичный подход при разработке процедур и определении политики банка.